

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO DO CONSUMIDOR

Autor:

João Gabriel Ribeiro Pereira Silva



Organizado por CP Iuris
ISBN 978-85-5805-033-3

DIREITO DO CONSUMIDOR

1ª edição
Brasília
CP Iuris
2020

JOÃO GABRIEL. Juiz do TJDFT. Aprovado no concurso público para Procurador da República.

Capítulo 1 — Contextualizando o CDC.....	13
1. Conceito	13
2. Inspiração constitucional	13
3. Natureza jurídica	13
4. Microssistema legislativo	14
5. Normas de caráter principiológico.....	14
6. Normas de “ordem pública e de interesse social”	14
7. CDC como lei “de função social”	15
8. Aplicação do CDC no tempo	16
9. Teoria do Diálogo das Fontes	16
Questões	18
Comentários.....	18
Capítulo 2 — Princípios do CDC.....	20
1. Princípio da vulnerabilidade do consumidor	20
2. Princípio da defesa do consumidor pelo Estado	21
3. Princípio da harmonização	22
4. Princípio da boa-fé objetiva	22
4.1. Função Interpretativa.....	23
4.2. Função Integrativa	23
4.3. Função de limite ao exercício de direitos subjetivos	24
4.3.1. Desleal exercício de um direito	24
4.3.2. Desleal não exercício de direitos	25

4.3.3. Desleal constituição de direitos.....	25
5. Princípio da transparência	25
6. Princípio da informação	26
7. Princípio da segurança	27
8. Princípio do equilíbrio nas prestações	28
9. Princípio da reparação integral.....	29
10. Princípio da solidariedade (responsabilidade solidária)	30
11. Princípio da interpretação mais favorável ao consumidor	30
12. Princípio da reparação objetiva	31
13. Princípio da conservação do contrato	31
14. Princípio da obrigatoriedade dos contratos ou da intangibilidade contratual (<i>pacta sunt servanda</i>)	31
Questões	32
Comentários	32
Capítulo 3 — Relação jurídica de consumo	34
1. Conceito	34
2. Sujeitos	34
2.1. Consumidor	34
2.1.1. Teoria finalista clássica (também chamada de subjetiva ou minimalista).....	34
2.1.2. Teoria objetiva (também chamada de maximalista).....	34
2.1.3. Teoria finalista mitigada ou temperada ou aprofundada	34
2.2. Fornecedor	35
2.3. Internet e relações de consumo	36
2.4. Profissionais liberais são fornecedores de serviços?	36

2.5. Consumidor por equiparação.....	37
3. Objeto.....	37
4. Aplicação Jurisprudencial.....	37
Questões.....	39
Comentários.....	40
Capítulo 4 — Teoria da Qualidade	42
1. Peculiaridades do Regime Consumerista	42
1.1. Caráter Solidário	43
1.2. Vício no produto ou serviço e fato do produto ou serviço.....	43
1.2.1. Vício do produto.....	44
1.2.2. Vício de Quantidade	45
1.2.3. Vício do serviço	46
1.3. Fato do produto ou serviço	47
1.3.1. Fato do produto.....	48
1.3.2. Fato do serviço	49
1.4. Excludentes de Nexo de Causalidade	49
1.4.1. Caso Fortuito e Força Maior	51
a) Fortuito interno.....	51
b) Fortuito externo	51
1.4.2. Teoria do risco do desenvolvimento	51
2. Situações específicas do Regime de Responsabilidade do CDC	52
2.1. Danos ao Tempo Como Bem Jurídico Autônomo	52
2.2. Responsabilidade do profissional médico.....	52
3. Jurisprudência Sobre a Teoria da Qualidade	53

3.1. Danos considerados <i>in re ipsa</i>	53
3.2. Danos que Não São Considerados <i>in re ipsa</i>	53
Questões	53
Comentários	54
Capítulo 5 — Prescrição e decadência no CDC	56
1. Aplicação Restrita dos Prazos Extintivos do CDC	56
2. Início da Contagem do Prazo Prescricional	57
3. Causas que suspendem a decadência	57
Questões comentadas.....	58
Capítulo 6 — Desconsideração da personalidade jurídica	61
1. Teoria maior e teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica	61
1.1. Teoria maior	61
1.1.1. Desvio de finalidade	61
1.1.2. Confusão patrimonial	61
1.2. Teoria menor	61
2. Sociedades integrantes de grupos societários, sociedades controladas, sociedades consorciadas e sociedades coligadas	62
Questões comentadas.....	62
Capítulo 7 — Práticas comerciais	64
1. Disposições Gerais	64
2. Oferta	64
2.1. Efeito vinculante da oferta publicitária	64
2.2. Dever de prestar informações corretas e precisas	65
2.3. Ofertas de peças de reposição	65

2.4. Venda por telefone e reembolso postal	66
2.5. Solidariedade do fornecedor pelos atos dos prepostos ou representantes autônomos	66
Questões comentadas.....	67
Capítulo 8 — Publicidade nas relações de consumo.....	68
1. Princípios da Publicidade	68
1.1. princípio da identificação	68
1.2. Princípio da vinculação contratual	69
1.3. Princípio da veracidade	69
1.4. Princípio da não abusividade	69
1.5. Princípio da transparência da fundamentação.....	69
1.6. Princípio da Lealdade Publicitária	69
2. Publicidade abusiva e enganosa	69
3. Ônus da prova na comunicação publicitária.....	70
4. Sanções	70
Questões comentadas.....	71
Capítulo 9 — Práticas abusivas	73
1. Práticas abusivas em espécie	73
1.1. Venda casada ou imposição de limites quantitativos pelo fornecedor.....	73
1.2. Recusa de contratar pelo fornecedor	74
1.3. Produtos enviados sem solicitação prévia	74
1.4. Hipervulnerabilidade.....	74
1.5. Exigência de vantagens excessivas	75
1.6. Execução de serviço sem orçamento prévio	75
1.7. Repasse de informações depreciativas relacionadas a consumidor	75

1.8. Inserção no mercado de produto em desacordo com as normas técnicas.....	76
1.9. Recusa de venda direta de bens e serviços	76
1.10. Elevação de preço sem justa causa.....	76
1.11. Ausência de prazo para cumprimento de obrigação pelo fornecedor	76
1.12. Aplicação de fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido	77
1.13. Superlotação de Estabelecimento	77
2. Produtos ou serviços sujeitos ao regime de controle de preços	77
3. Cobrança de dívidas.....	77
4. Repetição de Indébito no CDC.....	78
Questões comentadas.....	79
Capítulo 10 — Banco de dados e cadastro de consumidores	81
1. Direito a ser comunicado previamente	81
2. Direito de acessar a informação	81
3. Direito à correção das informações	81
Questões comentadas.....	83
Capítulo 11 — Proteção contratual	86
1. Disposições Gerais	86
1.1. Princípio da Transparência e Vinculação Contratual	86
1.2. Princípio da interpretação mais favorável	86
1.3. Princípio da vinculação do fornecedor	86
2. Direito de Reflexão ou de Arrependimento	87
3. Garantia contratual	87
4. Cláusulas Abusivas.....	88
4.1. Inciso I	88

4.2. Inciso II	89
4.3. Inciso III	89
4.4. Inciso IV	89
4.5. Inciso VI	91
4.6. Inciso VII	91
4.7. Inciso VIII	91
4.8. Inciso IX	91
4.9. Inciso X	92
4.10. Inciso XI	92
4.11. Inciso XIII	92
4.12. Inciso XIII	93
4.13. Inciso XIV	93
4.12. Inciso XV	93
5. Controle das cláusulas abusivas	93
6. Contratos que envolvam outorga de crédito ou financiamento	94
6.1. Capitalização dos juros	95
6.2. Comissão de permanência	95
6.3. Juros: Nos termos da súmula 382 do STJ	96
6.4. Cobrança indevida pela emissão de boletos bancários.....	96
6.5. Repasse de encargos tributários	96
6.6. Retenção salarial.....	97
6.7. Exclusão de mora e questionamento judicial.....	97
6.8. Instituições equiparadas.....	97
7. Cláusulas de decaimento e contratos de compra e venda de imóveis	97

8. Contratos de consórcio	99
9. Contratos de adesão	100
Questões comentadas.....	100
Capítulo 12 — Sanções administrativas.....	103
1. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	103
2. Competência legislativa e material em matéria consumerista	103
3. Sanções administrativas em espécie.....	104
3.1. Pena de multa.....	106
3.2. Penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso	106
3.3. Penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa	107
3.4. Imposição de contrapropaganda.....	107
Questões comentadas.....	107
Capítulo 13 — Infrações Penais.....	110
Questões comentadas.....	111
Capítulo 14 — Defesa do consumidor em juízo.....	113
1. Introdução.....	113
2. Direitos Coletivos <i>Lato Sensu</i>	113
3. Legitimados	114
4. Estímulo à efetividade	116
5. Custas, emolumentos, despesas e honorários.....	117
6. Ação de regresso do comerciante.....	117
7. Aplicação das regras do CPC e da Lei da Ação Civil Pública	117

8. Competência	118
9. Princípio da Publicidade e <i>Right to Opt In</i>	118
10. Sentença no Processo Coletivo	118
11. Coisa julgada.....	120
12. Prescrição	121
13. Disposições processuais específicas do Microssistema Consumerista.....	121
Questões comentadas.....	122

CAPÍTULO 1 — CONTEXTUALIZANDO O CDC

1. CONCEITO

A elaboração de um **conceito** sobre o Direito do Consumidor não pode deixar de abordar os seguintes fatores fundamentais:

- 1) Composição: normas e princípios;
- 2) Objeto de preocupação: sociedade de consumo¹;
- 3) Objetivo: “tutela integral, sistemática e dinâmica”² da parte vulnerável na relação consumerista, qual seja, o consumidor.

Assim, o Direito do Consumidor seria conceituado como o conjunto de normas e princípios que tratam da sociedade de consumo em busca da promoção da “tutela integral, sistemática e dinâmica” da parte vulnerável na relação consumerista (consumidor).

2. INSPIRAÇÃO CONSTITUCIONAL

Qualquer análise sobre o CDC deve ter como ponto de partida o fato de que se trata de **diploma com expressa origem constitucional**, em virtude dos seguintes aspectos:

- 1) É direito fundamental (art. 5º, XXXII da Constituição Federal de 1988); e
- 2) É princípio geral da atividade econômica brasileira (art. 170, V da CRFB/88).

Não por outra razão, dada a sua relevância, o constituinte estabeleceu o prazo de cento e vinte dias para a sua edição (art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB/88).

Ademais, o alto grau de mutabilidade das relações consumeristas e a sujeição de tais relações a regionalidades conduziu o constituinte a estabelecer a edição de normas consumeristas como hipótese de competência legislativa concorrente (art. 24, VIII da CRFB/88).

3. NATUREZA JURÍDICA

Atualmente, há consenso sobre a autonomia do Direito do Consumidor como disciplina jurídica, dada a existência de princípios e normas próprios que lhe caracterizam como tal. A divergência básica verificada diz respeito a seu posicionamento como³:

- 1) Ramo autônomo do direito privado, que se soma ao Direito Civil e ao Direito Empresarial (Cláudia Lima Marques);
- 2) Ramo autônomo de um novo direito, denominado difuso (Rizzato Nunes e Nelson Nery Júnior).

No particular, embora de valia para a inserção do estudo na amplamente difundida Teoria Geral do Direito, merece menção a crítica realizada a essa teoria por autorizada doutrina, diante dos indesejados efeitos de excessiva formalização, fechamento à interdisciplinaridade e à pesquisa empírica que dela advém⁴.

¹ “caracterizada por um número crescente de produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do *marketing*, assim como pelas dificuldades de acesso à justiça.” (GRINOVER, Ada Pellegrini, e Brazil, organizadores. **Código brasileiro de defesa do consumidor**. 12a. ed. rev., atualizada e reformulada. Gen, Editora Forense, 2019. p. 4)

² Ibidem.

³ ANDRADE, Adriano et al. **Interesses Difusos e Coletivos**. Vol. 1. 9ª ed. Editora Método, 2019. p. 450.

⁴ CASTRO, Marcus Faro de. **Formas jurídicas e mudança social: interações entre o direito, a filosofia, a política e a economia**. São Paulo: Saraiva, 2012.



4. MICROSSISTEMA LEGISLATIVO

O CDC é um **microsistema legislativo** porque:

- 1) Possui normas de direito público e privado; de direito material e processual; e de várias áreas do direito (civil, penal, processual, administrativo etc.);
- 2) Preocupa-se menos com a subdivisão técnica e formal e mais com a efetividade e a interpretação constitucional de suas disposições em favor da parte vulnerável da relação consumerista.

5. NORMAS DE CARÁTER PRINCIPIOLÓGICO

As normas contidas no CDC possuem dicção aberta e procuram estabelecer parâmetros aptos a incidir com a maior amplitude possível nas relações jurídicas que contêm a presença de parte vulnerável identificada como consumidor.

Essa característica, aliada ao reconhecimento do CDC como microsistema, demanda que a interpretação de qualquer lei que afete a relação consumerista seja feita sob a óptica do CDC; e passa a ser ressaltada quando se tem em vista a influência exercida pela adoção da teoria do diálogo das fontes, que será estudada adiante.

6. NORMAS DE “ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL”

De acordo com o art. 1º, o CDC estabelece “normas de proteção e defesa do consumidor, **de ordem pública e interesse social**, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.”

Do fato de serem normas de ordem pública e de interesse social decorre que as normas do CDC:

- 1) são cogentes, obrigatórias e **não admitem renúncia** prévia em prejuízo do consumidor⁵;

Isso não significa que, no caso concreto, o consumidor encontra-se impedido de transacionar judicial ou extrajudicialmente a respeito de direitos disponíveis. O que se veda é a renúncia prévia a direitos, ressaltando-se que ao consumidor pessoa jurídica, excepcionalmente, mostra-se viável a pactuação de limitações à extensão da responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 51, I do CDC.

- 2) o juiz está autorizado a conhecer dessas normas independentemente de provocação das partes, ou seja, **de ofício**.

A cognoscibilidade de ofício da abusividade de cláusulas não se estende à seara bancária, nos termos do enunciado 381 da Súmula do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Independentemente das exceções, as duas características acima elencadas evidenciam a extensão do rompimento da lógica contratualista liberal promovido pelo CDC. O código consumerista é exemplo típico do fenômeno conhecido como “constitucionalização do direito privado”, na medida em que representa evidente intervenção do Estado, através das leis por ele publicadas, no espaço usualmente reservado à autonomia da vontade.

A intervenção imposta pelo Estado nos negócios jurídicos através de leis é denominada **heteronomia**, aqui oposta ao conceito de **autonomia**, ligado ao poder conferido às partes de livremente disporem sobre suas obrigações em relações contratuais e usualmente prestigiado

⁵ Elucidativas as palavras do Ministro Herman Benjamin quando do julgamento do REsp nº 586316 / MG: “As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão *ex ante* e no atacado.”



pelos princípios da autonomia da vontade e do “pacta sunt servanda”, também denominado princípio da força obrigatória dos contratos.

Entretanto, o advento do fenômeno da constitucionalização do direito privado e da viabilização da intervenção do ente público nas relações contratuais **não significa o afastamento total do princípio “pacta sunt servanda”** das relações jurídicas travadas sob a égide do CDC. O que ocorre é a mitigação dos efeitos dos princípios da força, de modo que o conteúdo dos contratos não pode mais corresponder simplesmente à vontade das partes, seja ela qual for. É preciso que o contrato observe padrões mínimos, a boa-fé objetiva, necessidade de equilíbrio material, vedação do abuso de direito etc.

Tais limites, já presentes nos arts. 421 e 2.035 do Código Civil brasileiro (CCB), derivam não só do caráter de ordem pública e interesse social conferido às normas consumeristas pelo art. 1º do CDC, mas também das menções à boa-fé objetiva presentes nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Exemplo de aplicação prática das limitações que se originam do caráter de ordem pública das normas consumeristas e do princípio da boa-fé objetiva é o enunciado nº 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, o qual evidencia que na área consumerista a autonomia da vontade e o princípio “pacta sunt servanda” se submetem aos limites de ordem pública estabelecidos pelo CDC.

Outro exemplo relevante sobre o tema diz respeito ao reconhecimento da existência de **contratos relacionais ou cativos de longa duração**, definidos pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp nº 1073595/MG como os contratos em que “para além das cláusulas e disposições expressamente convencionadas pelas partes e introduzidas no instrumento contratual, também é fundamental reconhecer a existência de deveres anexos, que não se encontram expressamente previstos mas que igualmente vinculam as partes e devem ser observados. Trata-se da necessidade de observância dos postulados da cooperação, solidariedade, boa-fé objetiva e proteção da confiança, que deve estar presente, não apenas durante período de desenvolvimento da relação contratual, mas também na fase pré-contratual e após a rescisão da avença”.

Nesses contratos — dentre os quais se destaca o de seguro — a influência do CDC, aliada ao princípio da boa-fé objetiva, inviabiliza o acolhimento de condutas que, embora contratualmente previstas, encontrem-se descompassadas com a duração da relação ali estabelecida e os padrões de conduta que razoavelmente são esperados entre as partes à luz dos deveres anexos de conduta que advêm do CDC. Isso impede, por exemplo, que a seguradora, após vigência contratual de décadas, simplesmente se recuse a renovar a apólice do consumidor, unilateralmente e sem justificativa.

7. CDC COMO LEI “DE FUNÇÃO SOCIAL”

Alguns autores (ex.: Cláudia Lima Marques⁶) entendem que o CDC é uma lei de função social. Isso significa dizer que **essa lei não pode sofrer ab-rogações ou derrogações, quer em parte ou absolutamente, por outros diplomas legais de igual hierarquia, em detrimento dos direitos do consumidor.**

Apesar de o CDC tomar forma jurídica de lei ordinária, esses autores entendem que ele concretiza, no plano da legislação infraconstitucional, uma vontade explicitada pelo constituinte, ou seja, pela Constituição Federal. Assim, reduzida a proteção do consumidor pelo CDC através de outro diploma, estar-se-ia contrariando o anseio constitucional, de forma que essa nova lei seria inconstitucional.

⁶ Benjamin, Antonio Herman V., et al. **Manual de direito do consumidor**. 4ª. ed. [E-book baseado na 8ª ed. impressa] Revista dos Tribunais, 2017.



O CDC é uma lei ordinária e, consequentemente, poderia ser revogada por qualquer lei que lhe fosse superior. Porém, parcela da doutrina consumerista identifica o CDC como lei de função social, estabelece, por assim dizer, um peso normativo para baixo do qual não é lícito ir.

Tal noção faz com que se avenge a possibilidade da existência de um princípio da vedação do retrocesso em matéria consumerista.

O Supremo Tribunal Federal, através de sua Primeira Turma, em acórdão relatado pelo Ministro Carlos Britto em 17/03/2009, chegou a aventar a possibilidade de afastamento de normas supervenientes em prejuízo do CDC⁷, afirmando que: “Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.” (RE 351750/RJ).

Entretanto, a matéria de fundo julgada nesse Recurso Extraordinário foi novamente posta em discussão, desta feita, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE 636.331/RJ, ocasião em que o STF firmou a tese de que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”

Portanto, embora a questão relativa ao princípio da vedação do retrocesso em matéria consumerista não tenha sido analisada expressamente, certo é que sua aplicação restou inegavelmente prejudicada.

8. APLICAÇÃO DO CDC NO TEMPO

O CDC foi publicado em 12 de setembro de 1990, contendo “vacatio legis” de cento e oitenta dias (art. 118) e imediatamente após sua vigência instaurou-se controvérsia acerca da sua aplicação aos contratos que, embora firmados antes de sua vigência, envolviam prestação de trato sucessivo, cuja extensão temporal ocorreria já quando vigente o novo diploma consumerista.

A solução para essa questão perpassa a análise dos comandos do art. 5º, XXXVI da CRFB/88 e do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os quais preveem o princípio da irretroatividade das leis.

Embora em um primeiro momento o STJ tenha admitido a aplicação do CDC aos efeitos ocorridos sob sua vigência em decorrência de contratos pactuados antes de tal marco temporal (REsp 735.168/RJ), em fenômeno denominado “retroatividade mínima”, o STF passou a perfilhar entendimento diverso (RE 555.906/SP; RE 204769/RS e ADI 493/DF), de modo que, atualmente, encontra-se pacífico que **o CDC não se aplica aos contratos firmados antes de sua vigência.**

9. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES

A Teoria do Diálogo das Fontes (TDF) tem suas origens na doutrina de Erik Jayme e, embora tenha sua análise doutrinária e jurisprudencial fortemente atrelada à disciplina consumerista, a TDF possui pretensão acadêmica que se espalha à aplicação do direito como um todo, mais se aproximando da Teoria Geral do Direito do que propriamente da disciplina consumerista.

O fato de ser mais comum se estudar a TDF quando do estudo da disciplina consumerista se deve a dois principais fatores: 1) a doutrina elaborada por uma das mais renomadas especialistas em Direito do Consumidor do Brasil: Cláudia Lima Marques; e 2) o caráter principiológico e macro sistemático do CDC, que o coloca constantemente em diálogo com outras áreas do direito, em relações que podem ser tidas pelo intérprete como de conflito.

O desenvolvimento da TDF parte da existência de um problema denominado **Pluralismo Pós-Moderno**, que se identifica com a existência de **Fontes Legislativas Plúrimas**. De fato, os

⁷ A Convenção de Montreal foi celebrada em 28 de maio de 1999, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 59, de 18 de abril de 2006.



desenvolvimentos tecnológicos e a massificação das relações têm gerado pressão pela constante edição de leis em diversos ramos do direito, visando, não raro, o enfrentamento do mesmo problema, o que favorece a ocorrência das tensões na aplicação e interpretação das leis.

O objetivo da TDF é exatamente a obtenção da **Coerência Derivada ou Restaurada** entre esses diversos diplomas, visando garantir, através da “**aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas**”⁸, a **Eficiência Funcional** de suas disposições, o que não tem ocorrido de forma adequada a partir da adoção das soluções previstas pelos critérios tradicionais de solução de conflitos (cronológico, especialidade e hierarquia - art. 2º da LINDB).

Portanto, a partir da aplicação da TDF, quando identificada a existência de duas ou mais normas aplicáveis à mesma situação jurídica, **não se cogita a prevalência de uma delas, mas sim a aplicação coordenada “flexível e útil”**⁹, pois elas devem conviver harmonicamente na maior extensão possível, independentemente de análises sobre especialidade, hierarquia ou critério temporal, sempre objetivando a “prevalência do princípio *pro homine* e d(a) eficácia horizontal dos direitos fundamentais por aplicação do CDC às relações privadas”¹⁰.

A aplicação da TDF se dá através de três formas de diálogos: 1) **Diálogo Sistemático de Coerência**: “aplicação simultânea das duas leis, uma lei pode servir de base conceitual para a outra (...) especialmente se uma lei é geral e a outra especial”¹¹ (ex.: conceito de contrato de compra e venda do CCB apoiando a aplicação do CDC); 2) **Diálogo Sistemático de Complementaridade e Subsidiariedade**: “aplicação coordenada das duas leis, uma lei pode complementar a aplicação da outra, a depender de seu campo de aplicação no caso concreto”¹² (ex.: aplicação dos prazos prescricionais do CCB à demanda de repetição de indébito fundada no art. 42 do CDC); 3) **Diálogo das Influências Recíprocas Sistemáticas**: “no caso de uma possível redefinição do campo de aplicação de uma lei (...) É a influência do sistema especial no geral e do geral no especial, um diálogo de ‘*double sens*’”¹³ (ex.: definição da pessoa jurídica como consumidora a partir da adoção da teoria finalista mitigada como hipótese excepcional decorre de influência do CCB no CDC).

A TDF tem sido largamente utilizada pelos Tribunais Superiores¹⁴ e o principal fundamento para sua aplicação dentro da disciplina consumerista é o conteúdo do art. 7º, caput, do CDC, que dispõe: “Os direitos previstos neste código **não excluem outros** decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, **bem**

⁸ Benjamin, Antonio Herman V., et al. **Manual de direito do consumidor**. 4ª. ed. [E-book baseado na 8ª ed. impressa], Revista dos Tribunais, 2017.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ O caso paradigmático do STF no que tange a aplicação da TDF é a ADI nº 2.591/DF (conhecida “ADI dos bancos”). Quanto ao STJ, Cláudia Lima Marques traz larga exemplificação da aplicação da TDF, citando os seguintes precedentes: “Se inicialmente o e. Superior se mostrava resistente à ideia de convivência de fontes como eficácia da proteção constitucional especial aos consumidores, como se observa nos votos vencidos que usaram a ex-pressão em matéria de serviços públicos (REsp 911.802, Min. Herman Benjamin) e do uso do prazo prescricional geral se mais favorável ao consumidor (REsp 782.433, Min. Nancy Andrighi), note-se que a ideia de um “diálogo” de aplicação simultânea do CDC, CC e leis especiais para realizar, de forma mais eficaz, a proteção do consumidor foi recebida nas decisões mais recentes do e. STJ, em matéria de seguro-saúde (REsp 1.330.919-MT), leasing (REsp 1.060.515-DF), de SFH (REsp 969.129-MG), transporte (REsp 821.935-SE), seguros (REsp 403.155-SP), crianças (REsp 1.037.759-RJ), idosos (REsp 1.057.274-RS), bancos (REsp 347.752-SP), incorporação imobiliária (AgRg no REsp 1.006.765-ES), processo civil (REsp 1.241.063-RJ) e serviços públicos (REsp 1.079.064-SP), e a expressão diálogo das fontes já consta de algumas de suas ementas (veja REsp 1.037.759-RJ, REsp 1.060.515-DF, AgRg no REsp 1.196.537, REsp. 1.388.197-PR e REsp 1.272.827-PE).” (Ibidem).



como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.”
(Grifei)

Questões

1) (Ano: 2019/Banca: FCC/Órgão: DPE-SP/Prova: FCC - 2019 - DPE-SP - Defensor Público) — O Código de Defesa do Consumidor disciplinou temas da relação de consumo e seus efeitos, além de aspectos processuais ligados à proteção do consumidor. Tal lei, contudo, não tratou de matéria referente

- A) à tutela coletiva.
- B) à distribuição do ônus de prova.
- C) às responsabilidades decorrentes da relação de consumo.
- D) à teoria dos contratos.
- E) aos recursos cíveis.

2) (Ano: 2019/Banca: VUNESP/Órgão: TJ-AC/Prova: VUNESP - 2019 - TJ-AC - Juiz de Direito Substituto) — A Política Nacional das Relações de Consumo é regida pelo seguinte princípio, dentre outros:

- A) racionalização e melhoria dos serviços públicos e privados.
- B) harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
- C) coibição e repressão de abusos praticados no mercado de consumo que possam causar prejuízo aos consumidores e fornecedores.
- D) educação e informação de consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.

Comentários

1) A) O CDC, em seu Título III, Capítulo II, cuida "Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos".

B) O Art. 6º do CDC estabelece que: “São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".



C) O CDC, em seu Título I, Capítulo IV, Seções II e III, trata, respectivamente, "Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço" e "Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço".

D) O Título I, Capítulo VI do CDC trata da "Proteção Contratual".

E) Não há disposição sobre recursos no CDC.

2) A) CDC, Art. 4º, VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;

B) CDC, Art. 4º, III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (...), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

C) CDC, Art. 4º, VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

D) CDC, Art. 4º, IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;



CAPÍTULO 2 — PRINCÍPIOS DO CDC

1. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR

A vulnerabilidade do consumidor é expressamente reconhecida no inciso I do art. 4º do CDC e fundamenta a Política Nacional das Relações de Consumo, sendo a razão da própria determinação constitucional de publicação do CDC (arts. 5º, XXXII, 170, V e CRFB/88).

De acordo com Cláudia Lima Marques: “Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo.”¹⁵

É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência:

- **Vulnerabilidade:**
Tem **caráter material** e é **presumida absolutamente**. Uma vez qualificada como consumidora, a pessoa será tida por vulnerável.
- **Hipossuficiência:**
Tem **caráter processual** e é **presumida relativamente**. Uma vez qualificada como consumidora, a pessoa será tida por hipossuficiente, incumbindo à parte contrária demonstrar ausência de tal qualidade. A relevância do reconhecimento da hipossuficiência diz respeito à aplicação da inversão do ônus da prova, que será estudada adiante.

Todo consumidor é vulnerável, porém, nem todo consumidor é hipossuficiente, pois a hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto.

Ainda quanto ao tema, é importante mencionar que vulnerabilidade e hipossuficiência não se encontram relacionados exclusivamente a questões financeiras. A doutrina costuma apontar a existência de **4 espécies de vulnerabilidade ou hipossuficiência**: **1) Vulnerabilidade Técnica**: ligada às hipóteses em que o consumidor desconhece especificidades técnicas do produto ou serviço que está contratando ou adquirindo; **2) Vulnerabilidade Jurídica**: ocorre quando o consumidor dispõe de poucos conhecimentos jurídicos sobre o produto ou serviço que está contratando ou adquirindo; **3) Vulnerabilidade Fática ou Econômica**: atrelada à análise de circunstâncias fáticas ligadas à contratação do serviço ou aquisição do produto (ex.: monopólio, possibilidade de escolha, situação de urgência, etc.) além da questão econômica; **4) Vulnerabilidade Informacional**: espécie de vulnerabilidade cujo conceito é trabalhado por Cláudia Lima Marques e constitui decorrência de “dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra”¹⁶.

Embora seja mais comum que o estudo dessas subespécies seja realizado a partir da denominação “tipos de vulnerabilidade”¹⁷, é possível encontrar a discussão a partir do conceito “tipos de hipossuficiência”.

A par da inconsistência conceitual, é importante lembrar que nenhum tipo de classificação é inerentemente ruim ou bom. Pelo contrário, a qualidade de uma classificação se dá a partir de sua utilidade. Assim, a identificação de subespécies para facilitar a aplicação do direito é relevante tanto para se apurar a existência de vulnerabilidade (ex.: aplicação do CDC à

¹⁵ Benjamin, Antonio Herman V., et al. **Manual de direito do consumidor**. 4ª. ed. [E-book baseado na 8ª ed. impressa] Revista dos Tribunais, 2017.

¹⁶ Ibidem. Releva notar que, embora se trate de hipótese de vulnerabilidade que se assemelha ao conceito da vulnerabilidade técnica, o que se percebe é que a autora destaca que a informação atualmente disponível pode ser manipulada e controlada pelos detentores originários que, na maioria das vezes, possuem acesso à fonte garantido por exclusividade decorrente de segredo industrial.

¹⁷ Cláudia Lima Marques, por exemplo, trabalha os tipos relacionados à vulnerabilidade (Benjamin, Antônio Herman V., et al. **Manual de direito do consumidor**. 4ª. ed. [E-book baseado na 8ª ed. impressa] Revista dos Tribunais, 2017).



pessoa jurídica na posição de consumidora, hipótese em que esta deve comprovar sua vulnerabilidade) e a ocorrência de hipossuficiência (ex.: na apuração do preenchimento do requisito para a inversão do ônus da prova).

Portanto, não haveria, a princípio, equívoco em posicionar a diferenciação entre espécies de vulnerabilidade ou hipossuficiência, embora, como dito, seja mais comum que a doutrina o faça com relação à vulnerabilidade¹⁸.

2. PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR PELO ESTADO

Previsto no art. 4º, II do CDC, o princípio da defesa do consumidor pelo Estado também possui suas raízes nas disposições constitucionais que tratam da defesa do consumidor, em especial a que elenca os direitos do consumidor como direitos fundamentais (art. 5º XXXII da CRFB/88) e a que alça a defesa do consumidor à condição de princípio fundamental da ordem econômica (art. 170, V da CRFB/88).

Tais mandamentos constitucionais estabelecem dever inafastável imposto a todo Estado no sentido de promover efetivamente a defesa dos interesses e direitos do consumidor. Nos termos da doutrina especializada, trata-se de “direito a uma ação afirmativa ou positiva do Estado em favor dos consumidores (direito a prestações)”¹⁹.

Cuida-se de postulado que cria patamar de sustentação amplo para a extração de **deveres estatais** que passam pela criação de **políticas públicas** ligadas à proteção do consumidor como parte vulnerável da relação de consumo, devendo esse direito ser promovido em consonância com as demais diretrizes econômicas e individuais inscritas na CRFB/88.

A atuação estatal que objetiva a proteção do consumidor segue as linhas desenhadas pelo CDC, em especial, os instrumentos de execução previstos no art. 5º e a atuação dos órgãos que compõem o SNDC (arts. 105 e 106), sem prejuízo de outros instrumentos previstos em legislações especiais, como os Estatutos do Idoso, da Pessoa com Deficiência e do Torcedor.

O que se percebe, portanto, é que o princípio da defesa do consumidor pelo Estado promove hipótese de **intervenção, direta ou indireta, do Estado no domínio econômico**, nos termos especificados pela doutrina de Eros Roberto Grau²⁰.

De todo modo, a harmonização de direitos fundamentais, em especial, quando se tem em mente a existência de direitos com conteúdo econômico, há de ser feita a partir de uma visão constitucionalizada e será marcada pela concorrência de direitos durante grande parte da aplicação do CDC, como se verá a partir do princípio da harmonização.

¹⁸ José Geraldo Brito Filomeno, um dos autores do anteprojeto do CDC, ao comentar o art. 6º, VIII do diploma, afirma que a hipossuficiência possui conotação estritamente econômica e que esse requisito não se encontrava no anteprojeto, que somente elencava a verossimilhança das alegações como requisito da inversão do ônus da prova (GRINOVER, Ada Pellegrini; BRAZIL (org.). **Código brasileiro de defesa do consumidor**. 12ª. ed. rev., atualizada e reformulada. Gen, Editora Forense, 2019). Na jurisprudência do STJ, contudo, é comum encontrar a aplicação dos subtipos também à hipossuficiência (ex.: REsp 1667776 / SP – Hipossuficiência Técnica; REsp 1262132 / SP - Hipossuficiência Inofrmacional; e AgInt no AREsp 1059924 / SP – Hipossuficiência Jurídica).

¹⁹ ANDRADE, Adriano et al. **Interesses Difusos e Coletivos**. Vol. 1. 9ª ed. Editora Método, 2019. p.485.

²⁰ Nos termos da classificação adotada por Eros Grau (**A ordem econômica na constituição de 1988**. São Paulo, Malheiros, 2018), a intervenção do Estado na economia pode ocorrer através de três modalidades básicas: por absorção ou participação, por direção ou por indução. A intervenção direta por absorção ou participação ocorre nas hipóteses em que o Estado presta diretamente, através de monopólio (absorção) ou em regime de concorrência (participação). A intervenção por direção, a seu turno, corresponde à atuação reguladora do Estado, nas hipóteses em que lança mão de instrumentos legais e infralegais para induzir condutas sob pena de sanções. Por fim, a intervenção por indução é identificada com atividades de incentivo, por meio das quais o Estado traça regras diretivas orientadoras, porém, não cogentes, lançando mão, também, de políticas de fomento ou de incentivos, inclusive financeiros.



3. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO

Nos termos do art. 4º, III do CDC, o direito consumerista pátrio tem como princípio de alto relevo a “**harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo** e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de **desenvolvimento econômico e tecnológico**, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”.

Embora seja claro que a estrutura do diploma consumerista se dá a partir do reconhecimento do consumidor como parte vulnerável e protagonista, o legislador deixa claro, ao elencar os princípios que regem o CDC, a existência de norte interpretativo que demanda a harmonização dos interesses entre a defesa do consumidor e o desenvolvimento econômico.

A tensão entre o setor produtivo e a representação de interesses dos indivíduos que compõem o mercado, comumente representados pelo Estado, manifesta-se corriqueiramente em economias de mercado que adotam o sistema capitalista como forma de organização da produção, opção que mais se adequa ao sistema constitucional brasileiro.

José Geraldo Brito Filomeno²¹, ao comentar o princípio da harmonização, identifica três grandes instrumentos como caminhos de sua efetivação: 1) o sistema de SACs (Sistemas de Atendimento ao Consumidor), regulamentado pelo Decreto nº 6.523/2008 e pela Portaria 2.014/2008; 2) a convenção coletiva de consumo, prevista no art. 107 do CDC; e 3) a realização de “recalls” em observância ao art. 10 do CDC e Portaria 789/2001 do Ministério da Justiça.

Dada a textura aberta contida no princípio da harmonização e sua inegável inserção na tensa relação entre participantes de mercados e intervenção estatal na economia, pode-se dizer que esse princípio é uma das primeiras e mais relevantes “portas de entrada” à realização das teorias que examinam a relação entre direito e economia²².

4. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

Ainda do conteúdo do **art. 4º, III do CDC**, extrai-se a primeira menção à boa-fé no diploma consumerista. Essa previsão se soma ao que prevê o **art. 51, IV** do mesmo diploma para avaliar a aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva na disciplina consumerista, a qual, ademais, também encontra pleno influxo dos arts. 113, 187 e 422 do CCB, a partir da realização de um Diálogo de Influências Recíprocas Sistemáticas.

Nas palavras de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves, a boa-fé objetiva identifica-se com a noção de “‘confiança adjetivada’, uma crença efetiva no comportamento alheio. O princípio compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro **standard jurídico ou regra de comportamento**, caracterizado por uma **atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte**”²³.

Portanto, trata-se de princípio que se diferencia da tradicional análise de boa-fé subjetiva, ligada ao estado psicológico interno de cada pessoa em qualquer relação da vida civil,

²¹ GRINOVER, Ada Pellegrini; Brazil (orgs.). **Código brasileiro de defesa do consumidor**. 12a. ed. rev., atualizada e reformulada. Gen, Editora Forense, 2019.

²² Dentre as quais cite-se, apenas a título introdutório, a teoria da análise econômica do direito (“Law and economics”), a teoria do direito e economia comportamental (“Behavioral Law and Economics”), a teoria das origens ou do direito e finanças (“Law and Finance”), a teoria do direito e desenvolvimento (“Law and development”) e a análise jurídica da política econômica (AJPE). Para uma análise acurada, consulte-se a introdução de: P. CASTRO, M. F. de; FERREIRA, H. L. P. **Análise jurídica da política econômica: a efetividade dos direitos na economia global**. 1ª ed. CRV, 2018. DOI.org (Crossref), doi:10.24824/978854442488.9.

²³ FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil: Contratos, Teoria Geral e Contratos em Espécie**. v. 4. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2019.



na medida em que o caráter objetivo do princípio da boa-fé objetiva prioriza a análise da conduta das partes sob uma perspectiva externa, buscando-se aferir se as ações por elas adotadas se compatibilizam com os padrões de comportamento razoavelmente exigíveis.

A relevância do princípio da boa-fé objetiva no âmago do Direito do Consumidor é particularmente maior, dado que a disciplina consumerista é marcada pela permanente existência de parte vulnerável — o consumidor — sendo necessária a vigilância constante por parte dos aplicadores do direito neste particular. Esclarecedoras as palavras de Rosenvald e Chaves sobre o tema: “Portanto, é evidente que em cotejo com a autonomia privada, o peso da boa-fé cresce a medida em que a assimetria das partes se evidencia (v.g. contrato de adesão) ou que o bem jurídico em jogo possua caráter essencial (v.g. contrato educacional) (...) e também nas relações contratuais continuadas por instrumentos contratuais sucessivos (v.g. seguro de vida)”²⁴.

Em geral, a doutrina costuma realizar a divisão da boa-fé objetiva em três funções:

4.1. FUNÇÃO INTERPRETATIVA

Nesse plano, destaca-se o conteúdo do art. 113 do CCB, que estabelece diretrizes para a interpretação dos negócios jurídicos em alinhamento ao conteúdo que emana da boa-fé objetiva. Para Rosenvald e Chaves, essa função determina que “a leitura das cláusulas negociais privilegiará sentido que melhor conceda proteção à confiança”²⁵.

A opção do legislador civilista pelo acolhimento da teoria da confiança (em contraposição à teoria da vontade e à teoria da declaração) é plenamente aplicável à interpretação contratual a ser realizada no microsistema consumerista, sendo reforçada pela função interpretativa da boa-fé objetiva e pelas disposições protetivas contidas no CDC (arts. 6º, II a V; 9º; 25; 30; 31; 35; 46 a 54).

Portanto, a interpretação dos contratos consumeristas, em especial nas hipóteses de lacuna, deve ser realizada a partir de “standards” de conduta razoavelmente traçados a partir das práticas comerciais, visando a preservação da finalidade econômico-social do negócio jurídico, sempre levando em conta a vulnerabilidade do consumidor.

4.2. FUNÇÃO INTEGRATIVA

A identificação da função integrativa da boa-fé objetiva decorre da superação da visão clássica do negócio jurídico como estrutura formada por partes que se portam como adversários e encontra sua principal fonte no art. 422 do CCB, bem como no art. 6º, II do CDC. A constitucionalização do Direito Civil permitiu a revisão de tal conceito, passando a identificar a relação obrigacional negocial como solidária, onde os contratantes atuam como parceiros visando a obtenção de bons termos durante a execução do objeto que avençaram.

Assim, embora o conteúdo principal da relação obrigacional, correspondente ao objeto que se pactuou (dar, fazer ou não fazer), seja definido pela vontade das partes, em legítima aplicação da autonomia da vontade, a boa-fé objetiva passa a ser fonte integrativa de todos os negócios jurídicos, atuando de maneira heterônoma através da imposição de **deveres que são denominados de conduta ou anexos**, sendo definidos por Rosenvald e Chaves como “exigências de uma atuação calcada na boa-fé e derivadas do sistema, não de qualquer vontade das partes”²⁶.

A aplicação da boa-fé objetiva em sua vertente integrativa é inegavelmente categorizada como de ordem pública (arts. 422, parágrafo único c/c 2.035 do CCB), em especial quando se tem em vista que essa característica é reforçada pelo art. 1º do CDC, de modo que, observada a vulnerabilidade do consumidor, mostra-se como poder-dever do magistrado a

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem.



integração a partir da aplicação dos deveres anexos de ofício, os quais atuam em todos os momentos da relação obrigacional (incluindo fases pré e pós negociais).

Nos termos da classificação tripartite adotada por Rosenthal e Chagas²⁷, os deveres anexos são divididos em: A) **Deveres de Proteção ou de Cuidado**: objetivam a proteção da integridade física e do patrimônio da parte (exs.: art. 42 do CDC e a cobrança de dívidas; Súmula 130 do STJ e estacionamento não cobrado; Súmula 359 do STJ e dever de notificação do consumidor antes de negativação; etc.); B) **Deveres de Cooperação**: impõem às partes o dever de não agir de forma a prejudicar a parte contrária ou alterar o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico (exs.: Súmula 286 do STJ e operações bancárias que sucedem operações anteriores visando mascarar encargos ilícitos; arts. 30 e 35 do CDC e o princípio do caráter vinculativo da oferta; art. 32 do CDC e o dever de fornecimento de peças de reposição, visando combater a obsolescência programada; etc.); C) **Deveres de Esclarecimento ou de Informação**: são especialmente relevantes no CDC, onde a vulnerabilidade do consumidor possui vertente informacional²⁸, sendo preocupação constante do legislador (arts. 4º, IV; 6º, III e parágrafo único; 8º; 10º, § 3º; 12; 14; 30; 31; 36 a 38; 43; 44; e 52, todos do CDC). Portanto, o grau de informação ao consumidor é especialmente profundo quando comparado ao exigido nos negócios jurídicos em geral.

O descumprimento dos deveres anexos é uma forma de inadimplemento contratual denominada **violação positiva do contrato**, a qual pode resultar no dever de indenizar e/ou no direito de resolução do vínculo (ex.: condenação de médico a indenizar por danos morais paciente na hipótese em que, embora executado tratamento adequado, não houve informação adequada dos procedimentos — REsp 1540580/DF).

4.3. FUNÇÃO DE LIMITE AO EXERCÍCIO DE DIREITOS SUBJETIVOS

Por fim, a boa-fé objetiva dialoga também com a concepção de **abuso de direito**, definida no art. 187 do CCB e identificada com as hipóteses em que o titular de um determinado direito o exerce em desconformidade ética, desempenhando sua posição subjetiva de maneira ilegítima e causando lesão a direitos de terceiros. Ou seja, nas palavras de Rosenthal e Chaves: “Há um descompasso entre o objetivo perseguido pelo agente (titular do direito) e aquele para o qual o ordenamento direcionou o exercício do direito. A violação ao espírito do ordenamento é posta em seus fundamentos axiológicos – boa-fé, bons costumes e finalidade econômica ou social do direito subjetivo.”²⁹

A boa-fé objetiva serve de critério de balizamento de análise do exercício de uma determinada posição abusiva, e o CDC, em seu art. 51, IV, ao reputar nulas as cláusulas “incompatíveis com a boa-fé”, internaliza tal função ao nulificar o exercício de posições abusivas através de instrumentos contratuais.

Rosenthal e Chaves³⁰ distinguem três categorias de exercícios abusivos de um direito:

4.3.1. DESLEAL EXERCÍCIO DE UM DIREITO

Ocorre nas hipóteses em que há manifesta desproporção entre a vantagem que será obtida pelo titular do direito e o prejuízo daquele que sofre as consequências do exercício. Há aqui uma espécie de análise de proporcionalidade *strictu sensu* no campo do direito das obrigações, sendo a mais notória forma de exercício desleal de direito a hipótese em que se reconhece a ocorrência de **adimplemento substancial do contrato** (ex.: embora tenha sido vedada pelo STJ - REsp 1.622.555, a matéria é comum nos contratos de financiamento de veículos garantidos pela alienação fiduciária).

²⁷ Ibidem.

²⁸ Vide Capítulo 2, item I.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Ibidem.



4.3.2. DESLEAL NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

Aqui a postura do titular do direito é, inicialmente, omissiva, o que gera legítima confiança de terceiros que, após prazo razoável, é quebrada, prejudicando aqueles que inicialmente acreditaram na inação. Exemplo de hipótese de reconhecimento dessa forma de exercício abusivo é o ***venire contra factum proprium***, conhecido brocardo de bloqueio ao exercício de posição jurídica que contradite ato anteriormente tomado pelo próprio titular de direito (exs.: Súmula 370 do STJ e venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava — REsp 984106/SC).

Mostram-se também derivados do desleal não exercício de um direito os brocardos ***supressio*** e ***surrectio***, sendo a “supressio” decorrente da inação por parte do titular de um direito por lapso temporal que gere situação em que o seu exercício causará situação de desequilíbrio inadmissível entre as partes; enquanto a “surrectio” decorre de exercício de direito em desconformidade com a lei ou com o pactuado, de maneira a gerar nova fonte de direito subjetivo estabilizada para o futuro.

4.3.3. DESLEAL CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS

Por fim, a boa-fé objetiva, através da teoria do abuso do direito, impede que eventual indivíduo violador de determinada norma jurídica se valha dos direitos decorrentes da mesma norma que violou inicialmente. Nessa quadra, releva destacar o brocardo ***tu quoque***, que representa a defesa dos princípios da boa-fé e da justiça contratual, na medida em que, ao vedar o reconhecimento jurídico de posição obtida a partir de violação de um direito, também resguarda o equilíbrio entre as prestações, conforme destacado por Rosendal e Chaves³¹ (ex.: há nulidade dos atos praticados pela instituição financeira em nome do consumidor quando decorrentes de cláusula de mandato ilegalmente imposta no contrato — REsp 1084640/SP).

Outra hipótese de conduta que representa abuso de direito na modalidade de desleal constituição é a que deriva do descumprimento do **dever de mitigar o próprio prejuízo (“Duty to Mitigate the Own Loss”)**. Tal brocardo impõe ao contratante que ocupa a posição de credor a obrigação de, em observância ao dever anexo de cooperação, adotar medidas céleres e adequadas visando reduzir ao máximo possível o prejuízo imposto à parte devedora, mesmo que inadimplente (ex.: demora na retomada de imóvel financiado — REsp 758518/PR).

Entretanto, engana-se o intérprete que modula a aplicação e os efeitos da boa-fé objetiva apenas em direção ao consumidor. Na realidade, embora grande parte da relevância desse princípio na disciplina consumerista resida na compensação da vulnerabilidade do consumidor, é inegável que as funções supracitadas também se estendem ao consumidor, em especial no que tange à imposição dos deveres e condutas socialmente esperados.

5. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA

A **Política Nacional das Relações de Consumo** busca, dentre outros objetivos, **assegurar a transparência das relações de consumo**, conforme o art. 4º, caput, do CDC. Pretende o legislador, a partir da positivação desse princípio, oportunizar às partes envolvidas na relação consumerista amplo acesso às informações que envolvam o produto ou serviço negociado, desde sua fabricação ou execução, passando por sua comercialização, utilização e vida útil.

O consumidor, portanto, é titular do direito de exigir toda informação que julgue necessária à avaliação do produto ou serviço, bem como acerca do contrato que envolva a negociação em si. O fornecedor, por seu turno, encontra-se obrigado a, de acordo com a boa-fé objetiva, expor de maneira clara e adequada todas as informações que envolvam o produto ou serviço que coloque no mercado.

³¹ Ibidem.



Tais diretrizes são reforçadas pelos arts. 6º, III e 31 do CDC, sendo que este último adjetiva a informação exigida do fornecedor como **“corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa** sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

São exemplos de aplicação desse princípio: 1) vedação de cláusulas dúbias em prejuízo do consumidor (art. 47 do CDC); 2) Súmula 402 do STJ: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”; 3) aplicação da teoria da aparência na cadeia de consumo (REsp 1077911).

Como se percebe, o espectro de atuação do princípio da transparência é amplo, informando a relação consumerista em sua fase pré-contratual (ex.: exigências contidas na seção relativa à proteção à saúde e segurança — arts. 8º a 10 do CDC), contratual (ex.: princípio da oferta — art. 30 do CDC) e pós-contratual (art. 10, § 1º do CDC).

6. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO

O princípio da informação está ligado ao princípio da transparência, sendo forma relevante de concretização da atuação transparente das partes visando a adequada formação de vontade para contratação do serviço ou produto ofertado.

A adoção do paradigma do princípio da informação suprimiu a regra do “Caveat emptor”, que determinava ao contratante — no caso, o consumidor — o acautelamento na busca da informação. A partir de seu acolhimento, o CDC passa a determinar como ônus do fornecedor o oferecimento amplo de informações relativas ao produto ou serviço que oferta.

O princípio da informação possui **núcleo normativo dúplice**³²:

- **Direito do consumidor** de ser informado;
- **Dever do fornecedor** de informar.

Segundo o art. 6º, III, CDC, o consumidor tem o direito básico à **informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço**, bem como sobre os **riscos que apresentem**. Ademais, o parágrafo único do art. 6º ainda estabelece que: “A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.”

O STJ já entendeu que **informação adequada é informação completa, gratuita e útil**³³. Com relação ao “útil”, o STJ veda haja a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, destituídas de qualquer relevância e serventia para o consumidor (REsp 586.316, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJ 19/03/09).

A **obrigação de informação** é desdobrada em **4 categorias**:

- **Informação-conteúdo**: servirá para saber quais são as características intrínsecas do produto e do serviço;
- **Informação-utilização**: mais do que saber o que há dentro do produto, é necessário saber como ele usará o produto ou do serviço;
- **Informação-preço**: é necessário saber quais são os custos, as formas e condições de pagamento;
- **Informação-advertência**: é necessário saber os riscos do produto ou do serviço.

³² Expressão utilizada por Felipe P. Braga Neto (BRAGA NETO, Felipe P. **Manual de Direito do Consumidor**. 12. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017).

³³ Ibidem.



A falha no atendimento aos preceitos do princípio da informação gera, quanto à oferta, publicidade enganosa (por omissão ou por comissão — art. 37, §§ 2º e 3º do CDC).

No REsp 586.316, o STJ decidiu que este dever de informação ativo do fornecedor existe mesmo que o produto só possa causar dano a uma parcela pequena da população. Por exemplo, para o doente celíaco a informação “contém glúten”.

Outra hipótese relevante de aplicação concreta do princípio da informação foi dada pelo STJ no REsp 1540580/DF, onde ele estabeleceu que o postulado em comento impõe ao médico que: 1) esclareça o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico; 2) os esclarecimentos devem se relacionar especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica; 3) o dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil “per se”; e 4) o ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital.

Ainda, com base no princípio da informação, o STJ considerou enganosa a publicidade que omite o preço e a forma de pagamento, condicionando ligação para sabê-los (REsp 1428801); sendo também de relevo o precedente que estabeleceu que: “Ainda que haja abatimento no preço do produto, o fornecedor responderá por vício de quantidade na hipótese em que reduzir o volume da mercadoria para quantidade diversa da que habitualmente fornecia no mercado, sem informar na embalagem, de forma clara, precisa e ostensiva, a diminuição do conteúdo.” (REsp 1.364.915-MG).

Portanto, o princípio da informação possui ampla penetração no sistema consumerista, constituindo direitos e deveres em todas as relações jurídicas travadas no âmbito do direito do consumidor, em especial, quando se tem em vista sua estreita conexão com o princípio da boa-fé objetiva.

7. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA

O princípio da segurança estabelece diretriz no sentido de vedar ao fornecedor a oferta de produtos ou serviços que causem danos aos consumidores. Sua principal diretriz encontra-se no art. 6º, I, do CDC, que estabelece ser direito básico do consumidor a **proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos**.

O art. 8º do CDC, em reforço, diz que **os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição**, obrigando-se os fornecedores, **em qualquer hipótese**, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Perceba-se que o legislador não veda ao fornecedor o fornecimento de produtos que ofereçam riscos “considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição”, sendo tal ressalva fundamental à concretização do princípio da harmonização das relações no mercado de consumo, já que é normal que todo produto ou serviço ofereça riscos que são considerados toleráveis, cuja aceitação decorre de uma análise de proporcionalidade entre os benefícios advindos de seu fornecimento e os toleráveis efeitos colaterais dele advindos.

Cuida-se de hipótese denominada pela doutrina de **Perigo Inerente ou Latente**, encontrando-se presente na grande maioria dos casos da sociedade de risco atual (ex.: não se pode proibir a venda de um veículo baseada no risco de acidente automobilístico).

De outro lado, no caso de **produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança**, o fornecedor deverá informar, de maneira **ostensiva e adequada**, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto, conforme destacado pelo art. 9º do CDC.

Aqui, há uma gradação superior na periculosidade envolvida na comercialização do produto ou do serviço, embora também seja a hipótese tolerada pela análise de proporcionalidade entre os benefícios e os possíveis prejuízos, desde que haja informação ostensiva e adequada a respeito da nocividade ou periculosidade do produto.

Adiante, segundo o art. 10, **o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou alto grau de periculosidade à saúde ou segurança.**

Aqui, diante da existência de grau de periculosidade substancialmente superior ao previsto no art. 9º, o legislador trata da hipótese denominada **Perigo Exagerado**, o qual não é tolerado pelo ordenamento pátrio, justamente em razão do exame negativo de proporcionalidade “strictu”, ou seja, os benefícios não superam os custos ou os custos em si são inegociáveis (ex.: vidas humanas).

Se o fornecedor introduziu o produto e descobriu após que o produto era nocivo à saúde ou à segurança, o §1º impõe a ele o dever de **comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.** Esses anúncios publicitários serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, **às expensas do fornecedor do produto ou serviço**, conforme § 2º do mesmo art. 10. Trata-se da **periculosidade superveniente**, a qual também não é tolerada pelo ordenamento jurídico, que demanda sua publicização e reparação pelo fornecedor.

Inserir-se aqui o chamado **Recall**, que é posto como obrigação oposta ao fornecedor quando ciente da periculosidade superveniente apresentada por seu produto. A realização de “recall” é obrigação imposta pelo diploma consumerista ao fornecedor, sendo diretriz que também decorre do princípio da segurança e é regulamentada pela Portaria 618/19 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo sua análise retomada adiante neste E-book quando da análise das causas de rompimento de nexo de causalidade.

Além disso, **a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, sempre que tiverem conhecimento da periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou à segurança dos consumidores, **deverão informar os consumidores a respeito dessa periculosidade**, conforme § 3º do art. 10 do CDC.

Por fim, quanto aos tipos de periculosidade, para além das já citadas, há de se destacar que a doutrina também reconhece a existência de **periculosidade adquirida** na hipótese prevista no art. 12, § 1º do CDC, que trata de fato do produto e será melhor analisada quando do estudo da teoria da qualidade.

8. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO NAS PRESTAÇÕES

O equilíbrio nas prestações é princípio que decorre do postulado da harmonização, previsto no art. 4º, III do CDC, já visto acima. O princípio em estudo possui maior grau de especificação, formulando diretriz no sentido de que as disposições contratuais que se submetem ao CDC não podem prever vantagens desproporcionais, nos termos do art. 6º, V do CDC.

O art. 51, IV, CDC, dispõe que são **nulas de pleno direito**, entre outras, as **cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada**, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Isso não autoriza colocar o consumidor em vantagem exagerada. O que se busca efetivamente é o equilíbrio nas prestações, de forma que, se a cláusula é abusiva, esta cláusula é nula.

O CDC, em seu art. 6º, V, prevê como direito básico do consumidor a **modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão das cláusulas em razão de fatos supervenientes que tornem aquelas obrigações excessivamente onerosas.**

Basicamente, se há desequilíbrio no nascedouro do contrato, é possível que essa cláusula seja modificada. Da mesma forma, **se, após o nascimento, ocorrer um fato**



superveniente, passando-se a perceber um desequilíbrio no contrato, também será admitida a modificação ou a revisão das cláusulas contratuais.

O art. 6º, V, o CDC adotou a **teoria do rompimento da base objetiva do negócio**, afastando-se da teoria da imprevisão adotada pelo Código Civil Brasileiro em seus arts. 317 e 478, pois **não demanda que o evento seja imprevisível** e nem que a onerosidade seja excessiva para alterar ou modificar as cláusulas contratuais.

São exemplos de aplicação desse princípio a Súmula 302 do STJ, que dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.” No mesmo sentido, o precedente firmado em sede de repetitivo que afirma que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp 1.498.484-DF e REsp 1.631.485-DF - Tema 971).

A textura aberta de tal princípio e a sua concretização através da análise das práticas e cláusulas abusivas (arts. 39 e 51 do CDC) evidenciam um espectro amplo de aplicação, o qual será novamente revisado de maneira específica quando da análise dos dispositivos supracitados.

9. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL

Dentre os direitos básicos do consumidor, o art. 6º, VI, estabelece que o consumidor tem direito à **efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos**. Cuida-se de previsão legal que estabelece a reparação integral como diretriz a ser seguida pelo intérprete, visando a ampla reparação do dano eventualmente experimentado, em qualquer de suas vertentes, como forma, inclusive, de prevenir a ocorrência de novas violações (função dissuasória).

Exemplo de entendimento que atende ao princípio da reparação integral é o conteúdo da Súmula 465 do STJ, que estabelece: “Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação.” Nesse sentido, a Súmula 402 do mesmo sodalício, estabelece que “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Uma consequência do princípio da reparação integral é que **a jurisprudência brasileira não admite a indenização tarifada**. Entretanto, essa diretriz, assim como a do princípio da reparação integral, restou afetada pelo julgamento pelo STF, em repercussão geral, do Tema 210, onde restou fixada a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. (RE 636331/RJ)

Dessa forma, na hipótese de transporte aéreo internacional (no doméstico remanesce a integral aplicação do CDC) há de ser observada a diretriz de limitação prevista nos arts. 21 e 22 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, que estabelece o teto de ressarcimento baseado em Direitos Especiais de Saque, espécie de ativo com cotação em bolsa (XDR)³⁴.

Ademais, o CDC também permite a mitigação do princípio da reparação integral na hipótese em que o consumidor for pessoa jurídica. Nesse caso, a indenização poderá ser limitada e tarifada, conforme o art. 51, I, do CDC, que diz, em sua parte final, que nas relações de

³⁴ Ex.: No caso de extravio de bagagem, onde a Convenção de Montreal estabelece limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, o valor máximo a ser deferido consistiria em R\$ 6.324,45 (Seis Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos) em 04/03/2020 (<https://cuex.com/pt/xdr-br/>).



consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Portanto, é possível a indenização limitada se o consumidor for pessoas jurídica, desde que essa limitação seja justificada.

10. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE (RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA)

O princípio da solidariedade representa diretriz específica do CDC quando do tratamento do regime da responsabilidade dos fornecedores, na medida em que o consumidor poderá exigir o seu direito à reparação **contra todos aqueles fornecedores, ou contra apenas um deles**, conforme preferir, levando-se em conta a solidariedade entre eles.

Note-se que, para além do conteúdo da solidariedade imposta pelo legislador civilista no art. 942, parágrafo único do CCB, o princípio em estudo reputa solidários todos os fornecedores que atuam na cadeia de fornecimento, **independente de verificação de nexo de causalidade a partir da teoria da causalidade**. Ou seja, via de regra, em fornecimento de produto ou serviço submetido ao CDC, todos aqueles que estão vinculados à prestação são por ela responsáveis, mesmo que não tenham contribuído de nenhuma maneira para o evento.

Trata-se de garantia ofertada ao consumidor, diante de sua vulnerabilidade perante a complexa formação das cadeias de fornecimento, a qual, não raro, conta com o estabelecimento de estruturas jurídicas de “blindagem patrimonial” que podem vir a frustrar o direito do consumidor de se ver reparado por eventual prejuízo sofrido.

O art. 7º, parágrafo único do CDC dá vazão a esse princípio ao estabelecer que **“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”** Essa previsão é reforçada pelo art. 25, § 1º do CDC, que afirma que **“havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.”** Ainda, os caputs dos arts. 18 e 19 do CDC reforçam a existência de solidariedade na cadeia de fornecimento em decorrência de vício do produto.

Exemplo de aplicação desse princípio se evidencia na jurisprudência do STJ que entende que a empresa de turismo que vende pacote responde pelo dano causado pelo hotel (REsp 888.751), assim como no entendimento de que a franqueadora responde solidariamente pelos danos causados pela franqueada (REsp 1.426.578). No mesmo sentido, o STJ entende que empresas de plano de saúde respondem solidariamente pelo dano causado por médico ou hospital que foi por ela credenciado (REsp 164.084).

O STJ entende, no tocante ao provedor de conteúdo de internet, que ele não responderá objetivamente pelo conteúdo inserido pelo usuário (AgRg no REsp 1.309.891), em entendimento que restou ratificado pelo art. 18 da Lei nº 12.965/14, que estabeleceu o marco civil da internet. Entretanto, quando o provedor da internet for comunicado do conteúdo inadequado, terá obrigação de retirá-lo e, caso não retire após a determinação judicial, passará então a responder subsidiariamente com o autor do dano, conforme arts. 19 e 21 da Lei nº 12.965/14.

11. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR

O art. 47 do CDC dispõe que **“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”** A interpretação contra o estipulante também é prevista pelo Código Civil em seu art. 423, havendo aqui hipótese de diálogo entre as fontes. Portanto, eventuais disposições dúbias ou obscuras presentes no instrumento contratual devem ser interpretadas em benefício do consumidor, considerada sua vulnerabilidade e, em última instância, sua categorização como aderente ao contrato com cláusulas já postas.

Exemplo de aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor ocorre nas hipóteses em que determinado seguro de erige cobertura do evento de furto qualificado, a seguradora não pode se negar a cobrir o evento se o que ocorreu foi furto simples (REsp 814.060/RJ). Isso porque a distinção rígida entre o que é furto simples e furto qualificado é uma distinção inerente ao profissional do direito penal.



12. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO OBJETIVA

Ao lado do princípio da solidariedade, o princípio da reparação objetiva estabelece peculiaridade inerente ao regime de responsabilização previsto no CDC. De fato, ao contrário do que ocorre no CCB, a responsabilidade prevista no sistema consumerista é marcada pela objetividade, ou seja, independe da apuração de culpa para sua ocorrência.

Nesse sentido, os caputs dos arts. 12 e 14 do CDC afirmam expressamente a desnecessidade da verificação de culpa para apuração da reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos produtos ou serviços.

Cuida-se de princípio que comporta exceções, como a prevista no art. 14, § 4º do CDC, que estabelece que “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”; a do art. 28, § 4º do CDC, que afirma que “as sociedades coligadas só responderão por culpa”; e as ligadas à responsabilização penal (arts. 61 a 80 do CDC) que, por razão constitucional, não comportam responsabilidade objetiva.

13. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO

O CDC diz no art. 51, § 2º, que a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando da ausência dessa cláusula, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Portanto, o diploma consumerista adota a mesma linha do Código Civil que estabelece, em seu art. 184, que “respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará o negócio jurídico na parte válida, se for possível fazer essa separação entre a parte inválida e a parte válida.”

Assim, diversamente do que possa aparentar eventual demanda que decorra da condição de hipossuficiente do consumidor, a nulidade de cláusulas contratuais em contratos submetidos ao CDC não implica na anulação total da avença.

14. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS OU DA INTANGIBILIDADE CONTRATUAL (*PACTA SUNT SERVANDA*)

O princípio da força obrigatória dos contratos, que confere eficácia vinculante às disposições livremente pactuadas entre as partes, é plenamente aplicável aos contratos submetidos ao CDC. Tal locução significa dizer que o contrato que sofre o influxo do CDC também é exequível de maneira coercitiva, na forma do art. 389 do CCB.

Entretanto, diversamente do que ocorre no diploma civilista, a flexibilização do “pacta sunt servanda” não se restringe às hipóteses de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CCB) ou de aplicação da teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 do CCB). Ao contrário, considerada a vulnerabilidade do consumidor, os negócios jurídicos tutelados pelo CDC encontram-se expostos a maior grau de heterogeneidade, considerado o caráter de ordem pública expressamente estabelecido pelo art. 1º do diploma consumerista.

Dessa forma, embora o CDC estabeleça número significativamente maior de hipóteses de rompimento da lógica da obrigatoriedade da disposição contratual, inclusive hipóteses de conteúdo jurídico indeterminado como as dos arts. 39, V e 51, IV, ambos do CDC, certo é que a lógica da força obrigatória dos contratos prevalece quando inexistente hipótese abusiva.

O art. 5º do CDC estabelece que, para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Poder Público com os seguintes **instrumentos**:

- **Manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;**
- **Instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;**

- Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
- Criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;
- Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.

Veja, o art. 5º viabiliza o princípio do acesso à justiça, facilitando o direito do consumidor.

Questões

1) (Ano: 2020/Banca: CEBRASPE/Órgão: MPE-CE/Prova: CESPE - 2020 - MPE-CE - Promotor de Justiça de Entrância Inicial) — No âmbito do direito do consumidor, a igualdade de condições entre consumidores no momento da contratação, especificamente, é garantida pelo princípio da

- A) função social do contrato.
- B) hipossuficiência do consumidor.
- C) boa-fé objetiva.
- D) equivalência negocial.
- E) vulnerabilidade do consumidor.

2) (Ano: 2016/Banca: MPE-GO/Órgão: MPE-GO/Prova: MPE-GO - 2016 - MPE-GO - Promotor de Justiça Substituto) — Considerando os princípios e direitos básicos que regem o Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

- A) O conceito de hipossuficiência consumerista restringe-se a análise da situação socioeconômica do consumidor perante o fornecedor, permitindo, inclusive, a inversão do ônus probatório.
- B) O boa-fé objetiva é uma causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos, e, ainda se caracteriza por ser fonte de deveres anexos contratuais.
- C) Por ser os princípios da hipossuficiência e da vulnerabilidade conceitos jurídicos pode-se afirmar que todo consumidor vulnerável é, logicamente, hipossuficiente.
- D) A regra do *pacta sunt servanda* se aplica as relações de consumo e encontra-se prevista expressamente no CDC.

Comentários



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



1) Gabarito: D. O art. 6º, II, do CDC estabelece o princípio da equivalência negocial ao garantir a “igualdade nas contratações” no momento da contratação ou de aperfeiçoamento da relação jurídica consumerista. A diferenciação desarrazoada de tratamento entre consumidores é, também, prática abusiva, nos termos do art. 39, II e X do CDC.

Os demais princípios, embora relevantes, não tratam especificamente do equilíbrio das prestações.

2) A) Tanto o conceito de hipossuficiência quanto o conceito de vulnerabilidade são trabalhados pela doutrina sob os aspectos técnico, jurídico, fático e informacional, não se restringindo os conceitos à questão econômica, a qual se insere na subespécie fática.

B) Correto. Cuida-se da dupla função assumida pela boa-fé objetiva na disciplina contratual.

C) A vulnerabilidade é conceito de direito material (art. 4º, I do CDC) e alvo presunção absoluta. Já a hipossuficiência é conceito de direito processual (art. 6º, VIII do CDC) e alvo de presunção relativa. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente.

D) Embora o brocardo “pacta sunt servanda” seja aplicável à seara consumerista mediante observância das restrições de ordem pública nela previstas, não há previsão expressa de seu conteúdo no CDC.



CAPÍTULO 3 — RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO

1. CONCEITO

A relação jurídica de consumo é caracterizada pela presença em polos opostos de um consumidor e de um fornecedor, tendo por objeto produtos e serviços.

A $\leftarrow^x \rightarrow$ B

2. SUJEITOS

2.1. CONSUMIDOR

O art. 2º do CDC diz que **consumidor** é toda **pessoa física ou jurídica** que **adquire ou utiliza** produto ou serviço **como destinatário final**.

A locução “destinatário final” é a chave para a identificação da pessoa como consumidora e, considerando seu caráter de conceito jurídico indeterminado, foram criadas três teorias acerca de sua interpretação:

2.1.1. TEORIA FINALISTA CLÁSSICA (TAMBÉM CHAMADA DE SUBJETIVA OU MINIMALISTA)

Reputa consumidor toda pessoa física ou jurídica que se vale de um bem como destinatário final fático e econômico.

2.1.2. TEORIA OBJETIVA (TAMBÉM CHAMADA DE MAXIMALISTA)

Classifica como consumidor toda pessoa física ou jurídica que utiliza um bem como destinatário final fático.

2.1.3. TEORIA FINALISTA MITIGADA OU TEMPERADA OU APROFUNDADA

Trata como consumidor toda pessoa física ou jurídica que se vale de um bem como destinatário final fático e econômico. Entretanto, prevê a possibilidade de mitigação da rigidez do caráter cumulativo nas hipóteses em que houver vulnerabilidade na relação travada entre o potencial consumidor e o potencial fornecedor, ocasião em que o bastará que a pessoa física ou jurídica seja tida como destinatária final fática para que seja reputada como consumidora.

Mas o que é ser destinatário final fático e econômico?

Destinatário final fático é toda pessoa física ou jurídica que utiliza um bem ou serviço como último integrante da cadeia de consumo. Ou seja, é aquele que exaure em benefício próprio todo o potencial econômico do produto ou serviço, retirando-o de circulação.

Destinatário final econômico é toda pessoa física ou jurídica que se serve de um bem ou um serviço fora de uma atividade econômica. É aquele que não incorpora o bem ou serviço no processo produtivo de uma atividade prestada no mercado.

Dois exemplos para facilitar o entendimento da questão: A) a caminhoneira que adquire um caminhão para o exercício de sua atividade profissional é destinatária final fática, pois usa o produto em benefício próprio, não o expõe à revenda. Entretanto, não é destinatária final econômica, pois se vale do bem para colher remuneração; e B) o costureiro que adquire uma máquina de costura é destinatário final fático, pois não a expõe à revenda. Entretanto, não é destinatário final econômico, pois se vale do potencial econômico da máquina para obter remuneração.

Diante de tais considerações, tanto a caminhoneira quanto o costureiro não seriam consumidores a partir da aplicação da teoria finalista clássica. Sob a óptica da teoria objetiva, a resposta seria diversa, pois seriam eles consumidores.

Por fim, quanto à teoria finalista mitigada, ambos, a princípio, não seriam consumidores por não serem destinatários finais econômicos. Contudo, dada a evidente vulnerabilidade



existente entre eles e o fornecedor de serviços, há o preenchimento do requisito para a mitigação dos rigores da teoria finalista, o que os colocaria na condição de consumidores. Nessas situações, onde a vulnerabilidade autoriza a mitigação da teoria finalista, ocorre o que a doutrina denomina **consumo intermediário**.

Qual a teoria adotada pela letra da lei? Nenhuma delas. **Qual a teoria adotada pelo STJ? A teoria finalista mitigada** (Ex: AgInt no AREsp 1545508/RJ).

A Pessoa Jurídica pode ser consumidora? Sim. O caput do art. 2º do CDC é claro ao afirmar essa possibilidade, de modo que, verificada a posição da Pessoa Jurídica como destinatária final fática e econômica, mostrar-se-á possível a plena aplicação do CDC na relação concreta. Entretanto, para a aplicação da mitigação da teoria finalista, o STJ diferencia o tratamento: se o consumidor for pessoa física, sua vulnerabilidade será presumida, ao passo que se for ele pessoa jurídica, deverá comprovar, no caso concreto, sua vulnerabilidade.

A jurisprudência do STJ faz uma distinção em relação a tema: a vulnerabilidade do consumidor pessoa física é presumida, ao passo que a vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica deve ser comprovada (Ex.: AgRg nos EREsp 1331112 / SP).

2.2. FORNECEDOR

Segundo o art. 3º, fornecedor é **toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira**, bem como os **entes despersonalizados**, que desenvolvem atividade de **produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição** ou **comercialização de produtos ou prestação de serviços**.

Cuida-se de formulação ampla, de conteúdo enumerativo no que tange às atividades sublinhadas.

A caracterização de alguém como consumidor encontra-se atrelada ao reconhecimento cumulativo de **três características básicas**: 1) profissionalismo: deve-se observar ao menos um grau rudimentar de organização dos fatores de produção ligados à atividade exercida no mercado; 2) habitualidade: há de se apurar se o produto ou o serviço não foram ofertados de maneira esporádica, em situação ocasional. A verificação deve ser feita no caso concreto, não se exigindo previamente caráter diário ou semanal, mas apenas um certo grau mínimo de reiteração; 3) remuneração: somente há incidência do CDC nos serviços ou produtos fornecidos mediante remuneração. Contudo, essa remuneração pode ser indireta (ex.: responsabilidade por estacionamento gratuito em shoppings ou supermercados, dado a remuneração através das compras — Súmula 130 do STJ; relação entre consumidor e emissora de televisão com sinal aberto — REsp 1665213/RS).

Note-se que o produto ou serviço deve ser comercializado no **mercado de consumo**, assim entendido como o “espaço de negócios não institucional no qual se desenvolvem atividades econômicas próprias do ciclo de produção e circulação dos produtos ou de fornecimento de serviços³⁵”. Essa conceituação, embora de natureza fluida, tem servido de argumento para a não incidência do CDC em atividades como a relação entre condômino e o condomínio, entre o locador e o locatário e outros casos que serão estudados no final deste capítulo.

O STJ já decidiu que **mesmo as entidades sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, poderão ser consideradas fornecedoras**, caso desempenhem atividade no mercado de consumo mediante remuneração (STJ, AgRg no Ag 1.215.680).

Releva destacar, ainda, que o CDC é claro ao estabelecer sua **aplicação aos serviços públicos**, conforme comando dos arts. 4º, VII, 6º, X e 22, todos do diploma consumerista. Entretanto, a jurisprudência do STJ (paradigma no REsp 609.332/SC) diferencia as situações: a) aplica-se o CDC aos serviços públicos prestados mediante tarifa ou preço público, também denominados de serviços públicos “uti singuli” ou impróprios, pois são fornecidos no mercado

³⁵ ANDRADE, Adriano et al. **Interesses Difusos e Coletivos**. Vol. 1. 9ª ed. Editora Método, 2019. p. 539.



de consumo (ex.: energia elétrica — AgRg no AREsp 354.991/RJ; telefonia — AgInt no AREsp 1017611/AM; saneamento — REsp 1629505/SE; e rodovias — REsp 1268743/RJ); b) não se aplica o CDC aos serviços prestados mediante taxas ou através de remuneração indireta a partir de tributos, haja vista que neles não há, propriamente, serviço ofertado no mercado de consumo, mas, antes, efetivação de política pública submetida ao regime de direito público (ex.: serviços médico-hospitalares do SUS — AgInt no REsp 1347473/SP; e escolas públicas).

2.3. INTERNET E RELAÇÕES DE CONSUMO

Destaque-se a Lei do Marco Civil. Segundo o art. 18, **o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.**

No entanto, o art. 19, enxergando o provedor como fornecedor, disciplinou que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, **o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente**, ressalvadas as disposições legais em contrário.

O art. 21 diz que o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será **responsabilizado subsidiariamente** pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado **quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.**

Em outras palavras, o provedor de acesso à internet não responderá por eventual conteúdo danoso colocado na rede mundial de computadores por um terceiro que utilizá-lo. Do contrário, poderia haver censura por parte do provedor. Todavia, o provedor responderá se houver decisão judicial para que o conteúdo seja indisponibilizado e ele não obedeça à determinação judicial.

Segundo o STJ, não se pode exigir do provedor de hospedagem de blogs a fiscalização antecipada de cada nova mensagem postada. A mensagem deve ser postada primeiramente para que, somente após, seja possível a sua retirada.

Ou seja, a Lei do Marco Civil da Internet trouxe um **temperamento à responsabilidade solidária do provedor.**

2.4. PROFISSIONAIS LIBERAIS SÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS?

O profissional liberal é aquele que **exerce com autonomia a sua tarefa, sem subordinação técnica a outrem.** Além da **habilidade ou habilitação técnica**, o profissional liberal é caracterizado pela sua **autonomia e habitualidade no exercício de sua profissão.**

Observados os requisitos da categorização como fornecedor, não há óbice ao enquadramento do profissional, sendo tal interpretação extraída, também, a “contrario sensu”, do art. 14, § 4º do CDC, o qual, entretanto, excepciona o regime geral de responsabilidade adotado pelo CDC, afirmando que a **responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.**

Qual é a vantagem da aplicação do CDC em relação ao CC, no tocante aos profissionais liberais? O professor Felipe Peixoto enumera algumas vantagens de se aplicar o CDC: 1) possibilidade de **inversão do ônus da prova**, se houver **verossimilhança das alegações** ou **hipossuficiência do consumidor**; 2) possibilidade de o consumidor **propor a ação no seu domicílio**; 3) o **dever de informar de forma clara e adequada**, inclusive sobre os riscos dos produtos e serviços, **é mais severo**, já que se está diante de um vulnerável.



A relação entre o advogado e o cliente se submete ao CDC?

NÃO. O STJ firmou posição no sentido de que não é possível invocar as normas do CDC para regular o contrato de prestação de serviços advocatícios. Segundo o STJ, a relação é regulada pelo Estatuto da OAB e o advogado possui deveres para com o ordenamento jurídico, além do cliente, o que evidencia ausência de fornecimento de serviço no mercado de consumo. Portanto, nesse caso, seria inaplicável o CDC às relações advocatícias (REsp 1228104).

2.5. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO

O CDC prevê três hipóteses de consumidor por equiparação: 1) **art. 2º, parágrafo único, do CDC**: segundo o dispositivo, equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, **que intervenham nas relações de consumo** (é o caso do condomínio em sua relação com o público externo); 2) **art. 17, do CDC**: segundo o art. 17, para os efeitos desta Seção, **equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento**. Todas as vítimas do acidente de consumo são consideradas consumidoras. São os denominados *bystanders* (ex.: vítimas de acidente aéreo localizadas na superfície. O sujeito foi vítima do acidente de consumo, mesmo que não tenha relação com o contrato consumerista, sendo considerado consumidor); 3) **art. 29, do CDC**: para os fins deste capítulo e do seguinte, **equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas**. Todos os que forem atingidos por práticas comerciais são tidos como consumidores, mesmo que não tenham contratado o produto ou serviço ligado a prática em si.

Eventualmente, a legislação pode criar outras figuras de fornecedores. Por exemplo, o Estatuto do Torcedor, que equipara ao fornecedor a entidade responsável pela organização da atividade esportiva (art. 3º da Lei nº 10.671/03).

3. OBJETO

O CDC traz, nos parágrafos 1º e 2º de seu art. 3º, definições de caráter exemplificativo acerca do que deve ser considerado produto (§ 1º) e do que deve ser considerado serviço (§ 2º).

Note-se que a abertura do conceito de produto, incluindo bens móveis e imóveis, assim como materiais ou imateriais, amplia sua incidência, abarcando, por exemplo, o segmento imobiliário e as relações jurídicas que abrangem a produção intelectual.

No mesmo sentido, a dicção do conceito de serviço também é ampla e de caráter não taxativo, incluindo, por exemplo, a atividade bancária (Súmula 297 do STJ) entre outras amplas formas de atividades de prestação de benefícios ou de vantagens.

Muito importante a observação de que **apenas a prestação de serviço é que exige remuneração**, na esteira da letra da lei, haja vista que o CDC pode ser aplicado a produtos fornecidos gratuitamente, por força do comando do art. 39, III c/c parágrafo único do diploma, que determina a aplicação das disposições consumeristas às “amostras grátis”.

4. APLICAÇÃO JURISPRUDENCIAL

Com base nessas linhas gerais, cumpre citar alguns casos concretos:

Não se aplica o CDC:

1. Relação entre condôminos e condomínios: não há fornecimento de serviço no mercado de consumo (REsp 650.791);
2. Relação entre autarquia previdenciária e seus beneficiários: não há fornecimento de serviço no mercado de consumo (REsp 369.822);



3. Relações jurídicas tributárias: não há fornecimento de serviço no mercado de consumo (REsp 673.374);
4. Relações disciplinadas pela Lei do Inquilinato: não há fornecimento de serviço no mercado de consumo (AgRg AREsp 11.983);
5. Relação entre o representante comercial autônomo e a sociedade representada: não há preenchimento da figura do consumidor, pois o serviço é contratado na ausência da condição de destinatário final fático e econômico (REsp 761.557);
6. Não há relação de consumo quando as partes se juntam para construir — regime de administração ou de preço de custo, REsp 860.064 (não há preenchimento da figura do consumidor, pois o serviço é contratado na ausência da condição de destinatário final fático e econômico);
7. Franquia: “O contrato de franquia por sua natureza não está sujeito às regras do CDC, pois não há relação de consumo, mas relação de fomento econômico” (REsp 632.958). Não há preenchimento da figura do consumidor, pois o serviço é contratado na ausência da condição de destinatário final fático e econômico;
8. FIES: por se tratar de política relativa ao fomento da educação, não se aplica o CDC. 983 — Não há fornecimento de serviço no mercado de consumo;
9. Relação entre cooperativa e cooperado: não há fornecimento de serviço no mercado de consumo (AgRgREsp 12.122.507);
10. *Factoring*: as empresas de *factoring* não são consideradas instituições financeiras. Não há preenchimento da figura do consumidor, pois o serviço é contratado na ausência da condição de destinatário final fático e econômico (REsp 836.823, REsp 938.979);
11. Financiamentos bancários ou aplicação financeira com o propósito de ampliar o capital de giro: não há preenchimento da figura do consumidor, pois o serviço é contratado na ausência da condição de destinatário final fático e econômico (REsp 963.852);
12. Não se aplica ao serviço prestado em voo internacional: tese específica definida pelo STF em Repercussão Geral (RE 636331);
13. Transporte internacional de cargas: não há preenchimento da figura do consumidor, pois o serviço é contratado na ausência da condição de destinatário final fático e econômico (REsp 1.442.674).

Aplica-se o CDC ao(s):

1. Contratos de administração imobiliária (REsp 509.304);
2. Mercado de ações, corretagem de valores e títulos imobiliários (REsp 1.599.535);
3. Condomínio e público externo contratado para execução de serviços, por força do art. 2º, parágrafo único, do CDC (ex.: companhia de água — REsp 650.791);
4. Contratos de promessa de compra e venda em que a construtora/incorporadora se obriga à construção de unidades imobiliárias mediante financiamento. Compra de imóveis na planta (REsp 334.829 e REsp 1.560.728);
5. Cooperativas quando equiparadas às atividades típicas de instituições financeiras (AgRgAgr 1.088.329). Aliás, o STJ editou Súmula 602 entendendo que o CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais realizados pelas sociedades cooperativas;
6. O STJ entende que o CDC se aplica aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Nesse caso, cabe lembrar da Súmula 473. Existe uma exceção, o STJ diz nos contratos regidos pelo SFH que forem firmados com a cobertura do fundo de compensações salariais não se aplica o CDC (AgRgEDREsp 1.032.061). O STJ entende que, nesse caso, a garantia dada pelo governo de quitar o contrato afasta o CDC;



7. Exploração comercial da internet (REsp 1.186.616);
8. Entidades abertas de previdência privada (a fechada não se submete ao CDC — Súmula 563 do STJ);
9. Consórcio (REsp 1.185.109). Há dois feixes de relações jurídicas. Na relação entre administrado e administradora se aplica o CDC. Na relação entre os consorciados não se aplica;
10. Planos de saúde, salvo se forem regidos pelo sistema de autogestão (Súmula 608 do STJ);
11. Serviços de atendimento médico hospitalar — emergência (REsp 696.284);
12. Atividade notarial — cartório (REsp 1.163.652);³⁶
13. Correios (REsp 1.210.732).

Questões

1) (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RJ Prova: VUNESP - 2019 - TJ-RJ - Juiz Substituto) — Tendo em vista o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que

- A) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
- B) é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê a limitação do tempo de internação hospitalar do segurado.
- C) constitui prática abusiva a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.
- D) incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do pagamento do débito ainda que parcial.
- E) constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, não se sujeitando, no entanto, à aplicação de multa administrativa.

2) (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RO Prova: VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto) — Segundo o inteiro e exato teor das súmulas vigentes editadas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das relações de consumo, é correto afirmar que

³⁶ Entendia-se, anteriormente, que “a atividade notarial não é regida pelo CDC”, vencidos alguns ministros (STJ, REsp 625.144, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJ 29/05/06). O STJ, revendo o entendimento anterior acerca do tema, firmou posição no sentido de que “o Código de Defesa do consumidor aplica-se à atividade notarial” (STJ, REsp 1.163.652, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJ 01/07/10). Os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do poder público. É também irrelevante o argumento de os cartórios não terem personalidade jurídica. O CDC, art. 3º, é explícito ao dispor que também os entes despersonalizados podem ser fornecedores. Pesa contra a aplicação do CDC aos cartórios a natureza jurídica de taxa da remuneração por ele cobrada. Outro aspecto relevante a ser destacado é que o STF, em repercussão geral, definiu que: “O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (RE 842846). Tal entendimento afasta grande parte do regime de responsabilidade traçado pelo CDC.



- A) se aplica o Código de Defesa do Consumidor a todos os contratos de plano de saúde.
- B) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a todas as espécies de contratos de cartão de crédito.
- C) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
- D) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a quaisquer relações jurídicas entabuladas entre entidade de previdência privada e seus participantes.
- E) é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa.

Comentários

- 1) A) Não corresponde ao conteúdo da súmula 602 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.”
- B) Correta. Trata-se do entendimento exposto na Súmula 302 do STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.”
- C) Em desconformidade com a súmula 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
- D) Incorreta. Em contradição com a Súmula nº 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
- E) Incorreta. Discrepante da Súmula nº 532 do STJ: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”
- 2) A) Incorreta. A súmula nº 608 do STJ estabelece que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
- B) Incorreta. Desconforme com o enunciado. Não há súmula do STJ com a locução da questão.
- C) Correta. A súmula 602 do STJ afirma que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.”



D) Incorreta. A súmula 563 do STJ dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

E) Incorreta. A súmula 603 do STJ dispunha no sentido do enunciado. Entretanto, ela foi cancelada em fevereiro de 2018.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 4 — TEORIA DA QUALIDADE

O capítulo IV do Código de Defesa do Consumidor, que se estende dos arts. 8º a 28 do diploma, trata da teoria da qualidade, assim denominada por objetivar o controle da adequação dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo, assim como por traçar as diretrizes para garantir a efetiva reparação do consumidor em caso de funcionamento inadequado do produto ou serviço adquirido.

Trata-se, portanto, de regime similar ao tratado pela doutrina da responsabilidade civil na disciplina civilista. Entretanto, na seara consumerista, a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual perde relevância, em função do estabelecimento de regime único aplicável às relações de consumo, aliada à amplitude das regras de equiparação já mencionadas (arts. 2º, p.u.; 17 e 29 do CDC), que maximizaram o espectro protetivo das regras consumeristas³⁷.

Tais diferenças, entretanto, não impedem a utilização de conceitos desenvolvidos pelo Código Civil para a regulamentação da responsabilidade civil de natureza contratual e extracontratual. Ao contrário, concepções ligadas ao ato ilícito, ao nexo de causalidade e ao dano e sua indenização são aplicáveis em diálogo de fontes, respeitadas as peculiaridades da relação consumerista.

Ainda, há de se destacar que a doutrina trabalha com a conceituação de três tipos diversos de fornecedor responsável: 1) Responsável Real: aquele responsável por fabricar o produto ou prestar diretamente o serviço; 2) Responsável Presumido: o responsável pela exposição à venda do produto ou serviço; 3) Responsável Ficto: o responsável pela importação de um produto ou serviço para venda no mercado doméstico.

1. PECULIARIDADES DO REGIME CONSUMERISTA

A responsabilidade civil nas relações de consumo é marcada por duas características próprias: via de regra, é **objetiva e, também, solidária**, pois está inspirada fortemente na **teoria do risco** (inspiradora também da regra contida no artigo 927, parágrafo único). De acordo com essa teoria, quem cria, com a sua atividade ou serviço, um risco, deve por ele responder sem culpa, inclusive por ter dele se beneficiado economicamente (risco-proveito).

A) Caráter Objetivo: a objetividade do caráter da responsabilidade do fornecedor resta clara a partir da análise do caput dos arts. 12 e 14 do CDC, sendo marca geral do sistema consumerista, seja no que tange à apuração de práticas comerciais, seja quanto à apuração administrativa de eventuais violações aos direitos e garantias consumeristas. Portanto, a apuração da responsabilidade do fornecedor pelo funcionamento inadequado de algum produto ou serviço, assim como por práticas abusivas ou inserção de cláusulas contratuais abusivas e como por infrações administrativas, dá-se de maneira objetiva.

Entretanto, pode-se cogitar de **duas exceções ao caráter objetivo da responsabilidade** no sistema consumerista: 1) a responsabilidade dos profissionais liberais por acidentes ligados à prestação de seu serviço, conforme comando do art. 14, § 4º do CDC; 2) a responsabilidade penal diante dos tipos previstos nos arts. 61 a 80 do CDC.

Quanto à responsabilidade dos profissionais liberais por acidentes ligados ao serviço por eles prestado, há de se mencionar a existência de **exceção da exceção**. A obrigação dos profissionais liberais é, em geral, obrigação de meio, haja vista compreender a utilização de sua técnica e esforços de acordo com os protocolos técnicos aplicáveis, buscando a obtenção de benefício em linha com o usualmente esperado de sua técnica. Trata-se, portanto, de obrigação

³⁷ Parcela da doutrina afirma a adoção da teoria unitária da responsabilidade civil pelo CDC, conforme anotado por ANDRADE, Adriano et al. **Interesses Difusos e Coletivos**. Vol. 1. 9ª ed. Editora Método, 2019. p. 557.



de cuidado, de diligência e perícia (ex.: a contratação de médico cardiologista para realização de cateterismo não envolve a contratação da cura do paciente, mas sim o emprego adequado das técnicas razoavelmente esperadas do profissional).

Entretanto, quando a obrigação contratada pelo consumidor envolver expressamente a obtenção de resultado certo e prometido pelo profissional, eventual não atingimento da finalidade prometida implicará em presunção de culpa, a qual será tida como do profissional liberal responsável pelo procedimento, a quem incumbirá comprovar a ausência de culpa e/ou o advento de situação de rompimento do nexo de causalidade. Portanto, haverá, na prática, a inversão do ônus da prova em desfavor do profissional liberal responsável pelo tratamento.

O caso da cirurgia plástica é o mais comum entre as obrigações de resultado do médico (ex.: REsp 985888/SP). Não é qualquer cirurgia plástica que é capaz de gerar obrigação de resultado. A cirurgia reparadora é obrigação de meio (REsp 819008/PR).

Outros exemplos de obrigação de resultado entre profissionais são: tratamento de odontológico com finalidade estética (REsp 1178105/SP); transfusões de sangue (REsp 1645786 / PR); e exames laboratoriais (REsp 1653134/SP).

1.1. CARÁTER SOLIDÁRIO

A solidariedade na responsabilidade no sistema consumerista é marca permanente, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único; 18, 19 e 25, §§ 1º e 2º do CDC. Assim, havendo mais de um fornecedor na cadeia de fornecimento, todos serão solidariamente responsáveis por eventual funcionamento inadequado do produto ou do serviço.

No particular, assim como no caráter objetivo, a solidariedade também se mostra presente em toda a análise do CDC, aplicando-se também aos casos de práticas abusivas, abusos contratuais e infrações administrativas.

A existência da solidariedade é deferida em benefício do consumidor, motivo pelo qual o art. 88 do CDC **veda a realização de denúncia da lide** em demanda consumerista, visando preservar o consumidor da realização de inversões tumultuárias no curso processual, em especial, com a integração de terceiros que ele possa ter optado por não demandar, tudo em busca da duração razoável do processo.

Entretanto, por se tratar de garantia deferida ao consumidor, caso haja pleito de denúncia acolhido e processado, não cabe ao denunciado levantar o óbice do art. 88 do CDC, pois o consumidor pode dele abrir mão se assim julgar conveniente (REsp 913.687/SP). Ademais, há de se mencionar que o próprio CDC estabelece em seu art. 101, II do CDC, a possibilidade de intervenção de terceiro denominada “**chamamento**” de seguradora por parte do fornecedor.

Por fim, há de se destacar que há **uma exceção** à solidariedade, de alta relevância: a hipótese prevista no art. 13 do CDC, segundo o qual o comerciante (responsável aparente) é subsidiariamente responsável pelo fato do produto, não valendo essa exceção para as hipóteses de fato do serviço (interpretação restritiva ligada ao caput do art. 12, que trata somente do fato do produto).

Há, portanto, de se diferenciar o fato do vício do produto para que essa exceção se torne de fácil compreensão.

1.2. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO E FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO

No **vício (arts. 18 a 25 do CDC)**, há um **descompasso entre o produto e o serviço oferecido e as legítimas expectativas que o consumidor tinha**. Espera-se um produto com a qualidade X, mas vem com a qualidade Y, viciado.

No **fato (arts. 12 e 14 do CDC)**, há um **dano que o consumidor experimentou, seja à integridade física ou à integridade moral**.

O vício atinge o produto e o fato atinge a pessoa do consumidor.

Embora o CDC separe as hipóteses para traçar o seu regime jurídico, tanto o fato quanto o vício do produto estão ligados à **teoria da qualidade** estabelecida pelo CDC, no sentido de impor duas vertentes a serem observadas pelo fornecedor: 1) **qualidade-segurança**: ligada ao



fato do produto, determina que os produtos e serviços devem atender às diretrizes de segurança impostas pela lei (ex.: arts. 8º a 10 do CDC) e por órgãos técnicos responsáveis (art. 39, VIII do CDC), vedando-se que representem ofensa ao patrimônio e/ou à integridade física ou psíquica do consumidor; e 2) **qualidade-adequação**: ligada ao vício do produto, demanda que os produtos e serviços devem atender ao que transpareceram em sua oferta (arts. 30 e 35 do CDC) e ao que razoavelmente dele se espera em termos de durabilidade e prestabilidade.

Outro aspecto relevante a se destacar é o de que o dever do fornecedor de reparar os vícios eventualmente encontrados nos produtos ou serviços fornecidos no mercado encontra-se geralmente atrelado à noção de “**garantia legal**”, prevista no art. 24 do CDC. Ou seja, independente do que se encontra no conteúdo contratual, o consumidor tem o direito de ver seu produto ou serviço reparado pelo fornecedor nas hipóteses de vício oculto ou aparente, desde que observadas as regras de prescrição e decadência previstas nos arts. 26 e 27 do CDC, as quais serão melhor estudadas adiante.

Dessa forma, nos termos do art. 50 do CDC, a garantia contratual (ex.: garantia estendida) é complementar à garantia legal, vigendo seus prazos apenas após o fim dos prazos da garantia legal, ou seja, apenas após o transcurso do prazo decadencial ou prescricional.

Outro aspecto relevante a se mencionar é que as disposições ligadas ao estudo da teoria da qualidade (arts. 12 a 25 do CDC) encontram-se no núcleo essencial de proteção do consumidor e, por essa razão, mostram-se irrenunciáveis “a priori” e de maneira geral, dado seu caráter de ordem pública (art. 1º do CDC). Por essa razão, a preocupação em demonstrar a irrenunciabilidade dos direitos que decorrem dos deveres de garantia legal é repetida pelo legislador nos arts. 25, caput e 51, I, do CDC.

Dito isso, passemos à análise de cada tipo de vício.

1.2.1. VÍCIO DO PRODUTO

Segundo o art. 18, os fornecedores de produtos de consumo **duráveis** ou **não duráveis** respondem solidariamente pelos:

- **Vícios de qualidade ou quantidade que tornem esses produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam;**
- **Vícios de qualidade ou quantidade que diminuam o valor do produto;**
- **Vícios decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.**

O § 6º do art. 18 apresenta conceitos exemplificativos de vícios ao dizer que são impróprios ao uso e consumo: produtos com prazos de validade vencidos; produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; produtos inadequados ao fim a que se destinam.

A violação dos deveres de qualidade acarreta a aplicação do comando do parágrafo 1º do mesmo dispositivo, que determina: “§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

O prazo de trinta dias é um direito que o fornecedor tem para solucionar o problema, devendo o consumidor concedê-lo, sob pena de perda dos direitos elencados nos incisos do § 1º (REsp 1.520.500/SP). Entretanto, nas hipóteses em que o fornecedor devolve o produto e o vício reaparece, o STJ tem tido o entendimento de que não há renovação com nova concessão do prazo de 30 dias para o conserto, mas sim uma espécie de suspensão do prazo, o que daria ao fornecedor, em tese, apenas o prazo remanescente dos trinta dias anteriores para conserto



do bem, sob pena de incidirem as alternativas legais dos incisos³⁸ (REsp 1.443.268/DF). Ex.: veículo automotor apresenta vício no câmbio. O consumidor deixa para conserto na oficina credenciada por 12 dias e o retira supostamente sanado. Entretanto, o mesmo vício reaparece, ocasião em que o fabricante ou vendedor disporia de apenas 18 dias para consertá-lo.

Destaque-se que o prazo de 30 dias pode ser reduzido ou ampliado, conforme diretriz do § 2º do art. 18 do CDC, desde que não seja inferior a sete e nem superior a cento e oitenta dias, devendo a cláusula de alteração, em todos os casos, ser convencionada em separado e alvo de manifestação expressa do consumidor (em geral através de ciência específica).

Ademais, o prazo de trinta dias não precisa ser observado nas hipóteses do § 3º do art. 18 do CDC, ligadas à extensão do vício ou a produto essencial (ex.: vício grave de potência no motor do carro ou vício em produtos médicos como um marca-passo).

Além disso, o § 4º do CDC destaca que se o consumidor opta pela substituição do produto por um novo e essa substituição não se mostrar viável por ter o produto parado de ser produzido, por exemplo, mostra-se possível a “substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço”.

Outra regra relevante diz respeito ao fornecimento de produtos “in natura” (ex.: vegetais, frutas e alimentos). Nesses casos, constatada a existência de vício no produto, apenas o produtor irá por ele responder se este for identificado claramente pelo comerciante que expõe o produto à venda³⁹.

No vício de produto, há sempre responsabilidade solidária, inclusive do comerciante (ex.: concessionária é solidária na venda de veículos viciados). Portanto, constatando o consumidor a existência de vício no produto, deve procurar algum dos fornecedores responsáveis pelo produto para lhe conceder o prazo de 30 dias para a reparação.

No particular, o STJ chegou a entender, no REsp 1.411.136-RS, que, em que pese a existência de solidariedade quanto ao vício do produto, nas hipóteses em que houve assistência técnica do fabricante no local em que foi adquirido o produto, o comerciante não teria o dever de promover o encaminhamento para conserto, o que deveria ser realizado diretamente pelo consumidor. Entretanto, de maneira mais recente, o STJ reviu esse entendimento no REsp 1.634.851-RJ, ocasião em que reafirmou a existência de solidariedade com relação a todos os fornecedores no caso de vício, inclusive o comerciante, que possui o ônus do encaminhamento independentemente da existência de assistência técnica no local.

1.2.2. VÍCIO DE QUANTIDADE

Já no caso de vício de quantidade, o art. 19 do CDC estabelece que os fornecedores **respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto** sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, **seu conteúdo líquido for inferior às indicações**

³⁸ Essa diretriz foi adotada pelo Distrito Federal na Lei Distrital nº 6.259/2019: “Art. 1º A contagem do prazo de 30 dias de que trata o art. 18, §1º, da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, inicia-se com entrega do produto ao serviço de assistência técnica indicada pelo fornecedor ou fabricante. § 1º O prazo de que trata este artigo é suspenso com a entrega do produto ao consumidor após sanado o vício. § 2º Caso o produto apresente vício novamente, o prazo de que trata esta Lei volta a correr do momento da suspensão, devendo o vício ser sanado no prazo remanescente, sob pena de aplicação das disposições contidas no art. 18, § 1º, I, II e III, da Lei federal nº 8.078, de 1990.”

³⁹ A questão foi abordada na prova objetiva do concurso de ingresso na carreira de Promotor de Justiça do MPE-AM da seguinte forma: “No caso do fornecimento de maçãs a granel pelo ‘Supermercado Vende Bem’, identificadas nas gôndolas do estabelecimento como produzidas por ‘Irmãos Santos & Cia. Ltda.’, CNPJ 123.444.555/0001-00, em que houve a constatação técnica, pelo órgão oficial de fiscalização, de utilização de agrotóxicos permitidos para a referida cultura, mas utilizados além do limite máximo permitido pela ANVISA, quanto à Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço”. A resposta adequada ao problema era: “apenas ‘Irmãos Santos & Cia. Ltda.’ deve ser responsabilizado perante o consumidor.”



constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- Abatimento proporcional do preço;
- Complementação do peso ou medida;
- Substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;
- Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

O regime de garantia legal em caso de vício de quantidade concedido ao consumidor se assemelha ao que ocorre com o vício do produto. As peculiaridades relativas ao vício de quantidade são: a desnecessidade de aguardo de prazo de trinta dias para lançar mão das alternativas e a opção de complementação de quantidade, que se soma às alternativas similares já previstas nos incisos do § 1º do art. 18 do CDC.

O § 2º do art. 19 do CDC afirma que: “O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.” Em geral, a hipótese é direcionada aos fornecedores que se utilizem de instrumentos de medição (ex.: balança).

1.2.3. VÍCIO DO SERVIÇO

Segundo o art. 20, o **fornecedor de serviços** responde pelos:

- **Vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo;**
- **Vícios que diminuam o valor do serviço;**
- **Vícios decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.**

Neste caso, **poderá o consumidor exigir**, alternativamente e à sua escolha:

- **Reexecução dos serviços**, sem custo adicional e quando cabível;
- **Restituição imediata da quantia paga**, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- **Abatimento proporcional do preço.**

No mesmo sentido, o § 2º do art. 20 do CDC adiciona, exemplificativamente, que: “São impróprios os serviços que se mostrem **inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam**, bem como aqueles que **não atendam as normas regulamentares** de prestabilidade”. Mais uma vez nota-se a preocupação do legislador com a observância de parâmetros regulamentares, em especial, os emitidos por entes públicos com capacidade de certificação de qualidade (ex.: INMETRO). Vale lembrar que, em todas as circunstâncias e independentemente do resultado, a inobservância de parâmetros regulamentares aplicáveis é prática abusiva, nos termos do art. 39, X do CDC.

Note-se, ainda, que no caso do fato do serviço inexistir, a princípio, a necessidade de se aguardar o prazo de trinta dias para reparação, pois se presume que a reexecução do serviço, em sendo constatado o vício, deve ser imediata.

Ademais, releva destacar que o § 1º destaca que: “A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.” O comando permite a delegação da reexecução pelo fornecedor de acordo com análise de conveniência.

É normal que nas hipóteses em que ocorre desavença comercial quanto à execução de serviços, a fidúcia entre as partes se dissipe, tornando mais satisfatória a saída de terceirização da reexecução de serviços para evitar que a animosidade entre as partes prolongue ainda mais a situação de descumprimento contratual (ex.: constatada a má execução de uma reforma, torna-se mais prudente a reexecução dos serviços por outro profissional, com o custeio



imputado ao primeiro fornecedor, evitando a extensão do contato entre as partes originalmente contratadas em virtude da perda de fides.

Embora o § 1º do art. 20 transpore que a opção pela reexecução por terceiros seja deferida somente ao fornecedor, o que ocorre na prática é que, diante da controvérsia acerca da qualidade do serviço (o consumidor considera defeituoso e o fornecedor não), o consumidor opta pelo ajuizamento de procedimento antecipatório de produção de provas (art. 381 e seguintes do CPC/15) para comprovar o erro que alega ter ocorrido (ex.: através de perícia nos serviços de engenharia) e, para evitar a demora na tramitação processual até o trânsito em julgado, produz três orçamentos diversos, escolhendo o mais barato deles para reexecução e posterior reembolso em caso de procedência de seus pedidos (alguns tribunais adotam a regra do orçamento médio).

1.3. FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO

Sinônimo de acidente de consumo e de defeito do produto ou serviço, o fato do produto ou serviço é a ocorrência de danos oriundos de **ausência de segurança** do produto ou serviço que atingem o consumidor em sua **integridade física ou moral**.

Portanto, há aqui uma diferença de **intensidade** quanto ao vício do produto ou serviço, pois nestes há um mau funcionamento cujos efeitos se limitam a atingir a adequação do produto ou serviço ao que razoavelmente deles se espera em termos de funcionamento, ao passo que o fato do produto ou serviço decorre de um defeito que gera consequência danosa de ordem física ou psíquica ao consumidor.

Um exemplo simples é o da aquisição de uma televisão: se o consumidor liga a televisão e esta não liga ou funciona de maneira inadequada (ex: sem volume ou cor), a televisão é considerada viciada. Ao contrário, se ao ligar a televisão sobreaquece e explode, lesionando o consumidor, há um fato do produto, na medida em que lesionada a integridade física do consumidor.

Portanto, o que se percebe é que **o defeito pressupõe o vício**, de modo que **sempre que houver um defeito haverá um vício**, sendo a recíproca falsa. Ou seja, **nem sempre que houver um vício haverá um defeito que lhe seja correspondente**.

De outro lado, é relevante destacar que a doutrina costuma classificar os defeitos em: 1) **Defeito de concepção**, decorrentes de equívocos no próprio projeto de construção, fabricação ou execução; 2) **Defeito de fabricação**, que ocorre nas hipóteses em que embora o projeto seja hígido a sua execução resulta em produto defeituoso; 3) **Defeito de comercialização**, o qual, a despeito de envolver produto ou serviço cujo modelo de execução é adequado e cuja execução é correta, é comercializado de maneira inadequada.

É importante mencionar, ainda, que a jurisprudência do STJ costuma conferir interpretação extensiva ao conceito de fato do produto, como destacado no REsp 1.176.323 / SP, ocasião em que se afirmou que “O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal.”

Na hipótese, tratava-se de situação em que o consumidor havia adquirido cerâmicas que vieram a se deteriorar em prazo amplamente inferior ao razoavelmente esperado (9 meses) o que, em uma primeira leitura, poderia levar à categorização da hipótese como vício do produto. Entretanto, entendeu-se que a gravidade das consequências causadas pela deterioração do piso, em especial infiltrações e gastos com a reexecução do serviço, eram indicativos de que a hipótese seria de fato do produto e não de vício.

Tal categorização é relevante para a definição da extensão dos prazos, pois, como se verá adiante, o prazo prescricional para reparação de fatos do produto ou serviço (cinco anos)



é substancialmente superior aos prazos decadenciais (trinta dias para produtos ou serviços não duráveis e noventa dias para serviços ou produtos duráveis).

De outro lado, ressalte-se que **o fato do produto ou serviço poderá coexistir com o vício do produto ou serviço**. Trata-se de consideração alinhada com a própria sistemática do CDC, o qual adota, como visto, o princípio da reparação integral, exemplificado pelos comandos dos arts. 18, § 1º, II, 19, IV e 20, II, todos do CDC, que destacam que a restituição de valores em casos de vício do produto, quantidade ou serviço ocorre “sem prejuízo de eventuais perdas e danos”.

De fato, o que se percebe é que o entendimento que eventualmente prestigiasse a possibilidade de reparação de danos de ordem material, estética ou moral, apenas nos casos em que fosse solicitada a restituição de valores acabaria por induzir situação de desequilíbrio nas relações consumeristas, ferindo o princípio da reparação integral e prejudicando, inclusive, o fornecedor, para quem, em geral, medidas como a reexecução do serviço, o abatimento do preço e a restituição parcial de valores costuma ser menos prejudicial do que o reembolso em si.

Na jurisprudência do STJ é comum se encontrar precedentes deferindo a indenização por danos morais ou materiais em conjunto com a determinação de algumas das alternativas ligadas à garantia legal (ex: AgInt no AREsp 1146222 / RS).

Visto isso, passemos à análise dos tipos de acidente de consumo.

1.3.1. FATO DO PRODUTO

Segundo o art. 12, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por **defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos**, bem como por **informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos**.

Quanto aos defeitos em si, o § 1º do art. 12 do CDC estabelece rol exemplificativo de tipos: § 1º O produto é defeituoso quando não oferece a **segurança que dele legitimamente se espera**, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua **apresentação**; II - o **uso e os riscos** que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação.”

Ou seja, há aqui comando amplo de responsabilização do fornecedor, que deve ser entendido como **dever de reparação de danos morais, estéticos e materiais em todas as hipóteses que a integridade física ou moral do consumidor for violada em decorrência de um defeito de segurança de um determinado produto**. Na prática, a amplitude dos comandos de responsabilização e a principiologia do CDC têm sido interpretados no sentido de que uma vez constatada a ocorrência de violação à integridade física ou psíquica do consumidor e apurado o nexo de causalidade entre o dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor, este deverá ser responsabilizado pela reparação integral, ressalvada a ocorrência de circunstâncias que rompam o nexo de causalidade, as quais serão estudadas adiante.

Vale lembrar que **o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado**, conforme destacado no art. 12, § 2º do CDC.

Ademais, segundo o art. 13, **nos casos de fato do produto, o comerciante é igualmente responsável** quando:

- O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador **não puderem ser identificados**;
- O produto for fornecido **sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador**;
- **Não conservar adequadamente os produtos perecíveis**.

Com base nesse comando, é comum se afirmar que **por fato do produto a responsabilidade do comerciante é subsidiária**. Isso porque só irá responder nas hipóteses



acima. Alguns doutrinadores, entretanto, afirmam que a hipótese encerra espécie de regime especial de responsabilização, aplicável apenas ao fato do produto, em que a responsabilidade do comerciante não segue a regra geral de ampla solidariedade, estando condicionada às hipóteses do art. 13.

De todo modo, caso haja alguma das hipóteses previstas no art. 13 do CDC, nos termos da jurisprudência do STJ (ex: AgInt no AREsp 1016278 / RJ), o comerciante passará a ter as mesmas obrigações dos demais coobrigados, que remanescem responsabilizados (ex: o fato de comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis não exclui a responsabilidade do fabricante pelo fato do produto, restando apenas reforçada a fonte de responsabilização em benefício do consumidor, haja vista que também o comerciante pode ser acionado solidariamente com os demais integrantes da cadeia de fornecimento).

1.3.2. FATO DO SERVIÇO

Diz o art. 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por **defeitos relativos à prestação dos serviços**, bem como por **informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos**.

Exemplificativamente, o § 1º do art. 14 estabelece que “O serviço é defeituoso quando não fornece a **segurança** que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o **modo de seu fornecimento**; II - o **resultado e os riscos** que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.”

Saliente-se que o **serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas**, conforme expressamente destacado pelo § 2º do art. 14 do CDC.

Ainda, como destacado anteriormente, o § 4º do art. 14 do CDC estabelece que, em se tratando de serviço prestado por profissional liberal, a responsabilidade será apurada de maneira subjetiva, ou seja, demandará a apuração de culpa “*latu sensu*” para sua verificação.

1.4. EXCLUDENTES DE NEXO DE CAUSALIDADE

Assim como ocorre na teoria geral da responsabilidade civil contratual e extracontratual, uma vez evidenciada a existência de dano e nexo de causalidade entre o produto ou serviço fornecido, é possível a isenção de responsabilização nas hipóteses em que for comprovada a existência de hipótese que rompa o nexo de causalidade.

O CDC dispõe, em seu art. 12, § 3º, que o fabricante, o construtor, o produtor ou importador **só não será responsabilizado quando provar:**

- Que **não colocou o produto no mercado**;
- Que, embora haja colocado o produto no mercado ou tenha prestado o serviço, o **defeito inexistia**;
- Que a **culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros**.

Em redação semelhante, o art. 14, § 3º do CDC, tratando do fato do serviço, estabelece que “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistia; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Destaque-se que, embora inexistia comando similar quanto ao vício, é consenso na prática que tais matérias também podem ser alegadas como rompimento de nexo de causalidade nos casos de vício do produto ou serviço (Ex: AgRg no AREsp 400983 / PB, onde o STJ rechaça a tese de culpa exclusiva do consumidor).

Dito isto, releva notar que, diversamente do que ocorre com a comprovação em si da existência do vício ou fato do produto de serviço, que depende de decisão judicial para ser submetida ao ônus da prova invertido em desfavor do fornecedor (art. 6º, VIII do CDC), no caso da comprovação da ocorrência de fato que rompe o nexo de causalidade tal inversão opera em todos os casos, independente de atuação jurisdicional, sendo denominada “*ope legis*”.

Dessa forma, acaso seja alegada a ocorrência de vício ou fato do produto pelo consumidor em demanda judicial, eventual alegação de rompimento de nexo de causalidade,



inclusive a de ausência de vício ou defeito, fica a cargo do fornecedor, independente de atuação judicial, já de partida. Ou seja, evidenciada, “a priori” a existência de vício ou defeito, cabe ao fornecedor comprovar que não se trata de vício ou defeito (ex: que é hipótese de desgaste natural e não vício) ou a ocorrência de qualquer outra forma de rompimento de nexo de causalidade (ex: que vício decorreu de mau uso pelo consumidor).

Quanto às hipóteses elencadas nos dispositivos supracitados, verifica-se que os incisos I e II dos parágrafos 3º dos arts. 12 e 14, ao estabelecerem a prova da ausência de colocação do produto ou serviço no mercado ou a inexistência do defeito não tratam, propriamente, de hipóteses de rompimento do nexo de causalidade. Isso porque a ausência de defeito encontra-se ligada à caracterização do próprio ato ilícito, de modo que, ausente o ato ilícito, não há sequer de se apurar o nexo de causalidade. Ademais, a hipótese em que o fornecedor não colocou o produto ou serviço no mercado representa ausência de nexo de causalidade em si, e não rompimento.

Dessa forma, tecnicamente falando, apenas o inciso III dos parágrafos 3º dos arts. 12 e 14, constitui, tecnicamente, hipótese de rompimento de nexo de causalidade, conforme, inclusive, o conteúdo da teoria geral da responsabilidade civil. De fato, quando a culpa é atribuível exclusivamente ao consumidor ou a terceiro há, a princípio, o preenchimento dos requisitos básicos da responsabilidade civil em desfavor do fornecedor (ato ilícito, nexo causal e dano). Entretanto, nessas hipóteses, a apuração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros é apta a romper o nexo de causalidade e inviabilizar a responsabilização do fornecedor.

Relevante apurar, se a hipótese da culpa exclusiva do consumidor também abarcaria a situação em que resta apurada a culpa concorrente. O Código Civil estabelece, em seu art. 945, que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, levando em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a gravidade da culpa do autor do dano.

Portanto, o que se percebe é que, mesmo que admitida a aplicação do diploma civilista, resta inviável a exclusão total de responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa concorrente, tendo em vista que, também, a própria dicção do CDC se refere à culpa “exclusiva”, restando apurar a possibilidade de se reduzir o valor da indenização.

Parcela substancial da doutrina (ex: Zelmo Denari, Rizzato Nunes, etc.), entende que a culpa concorrente não resulta nenhum tipo de consequência no regime do CDC, basicamente por duas razões: 1) o regime de responsabilidade objetiva adotado pelo CDC busca eliminar da apuração da relação de consumo a discussão sobre o elemento subjetivo; 2) o CDC não elenca regra similar à do CCB, a qual não pode ser aplicada ao sistema consumerista diante das limitações apresentadas pela vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I do CDC) e pelo princípio da reparação integral (art. 6º, VI, CDC).

Entretanto, em caso concreto, o STJ já entendeu que a verificação de culpa concorrente permite a redução da condenação (REsp 287.849 / SP), aplicando em diálogo de fontes o comando do art. 945 do CCB.

De outro lado, quanto a culpa exclusiva de terceiro, trata-se de situação que envolve a interferência de pessoa completamente alheia ao serviço ou produto contratado que acaba contribuindo para ocasionar o defeito do produto. Evidentemente que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, 25, §2º e 34 do CDC, não se caracterizam como terceiros quaisquer pessoas relacionadas à cadeia de fornecimento.

Por tal razão, é comum que a causa de rompimento relativa a atuação de terceiros é comumente associada ao caso fortuito ou força maior (ex: roubos em coletivos, hipótese em que o STJ entende rompido o nexo de causalidade - AgRg no REsp 1551484 / SP).

De todo modo, para além das hipóteses dos parágrafos 3º dos arts. 12 e 14, há também a discussão acerca da possibilidade de outras hipóteses de rompimento de nexo de causalidade.



1.4.1. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Verifique que os arts. 12, § 3º e 14, § 3º, não elencam o caso fortuito ou força maior como causas excludentes da responsabilidade, gerando a dúvida acerca da aplicação de tais fatores como hipótese de rompimento.

Embora parcela substancial da doutrina tenha articulado que tratava-se de silêncio eloquente, ou seja, que o legislador deixou de contemplar o caso fortuito e a força maior exatamente porque queria que tais casos não fossem vistos como fator de rompimento do nexo de causalidade, a jurisprudência do STJ passou a acatar tais hipóteses como aptas ao rompimento, preocupando-se com a distinção entre fortuito interno e fortuito externo:

a) Fortuito interno

Se o dano sofrido pela vítima guarda relação com a atividade desenvolvida pelo ofensor, o caso é de fortuito interno e, nestas hipóteses, o **dever de indenizar continua** (Ex.: A súmula 479 do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”).

b) Fortuito externo

Nos casos em que o dano não guardar ligação com a atividade desenvolvida pelo ofensor haverá rompimento do nexo de causalidade, sendo o **dever de indenizar afastado** (Ex: A concessionária de transporte ferroviário não responde por ato ilícito cometido por terceiro e estranho ao contrato de transporte. A prática de crime (ato ilícito) – seja ele roubo, furto, lesão corporal, por terceiro em veículo de transporte público, afasta a hipótese de indenização pela concessionária, por configurar fato de terceiro. REsp 1.748.295 / SP; Concessionária de rodovia não responde por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários - REsp 1.749.941 / PR; e “Banco não é responsável por fraude em compra on-line paga via boleto quando não se verificar qualquer falha na prestação do serviço bancário.” - REsp 1.786.157 / SP)

1.4.2. TEORIA DO RISCO DO DESENVOLVIMENTO

A teoria do risco do desenvolvimento envolve a **aceitação, como excludente da responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços, da circunstância de o defeito apurado derivar de fato que o fornecedor não poderia ter conhecimento, de acordo com as tecnologias disponíveis, no momento em que inseriu o produto ou serviço no mercado de consumo.**

Ou seja, trata-se de defeito que se evidencia somente após o fornecimento do produto ou serviço, de acordo com o avanço da ciência, ocasião em que os danos começam a aparecer. O CDC não adotou posição categórica sobre ela. A União Europeia e os Estados Unidos a aceitam como excludente de responsabilidade.

No Brasil há autores que entendem que ela é uma excludente (Fábio Ulhoa Coelho e Gustavo Tepedino), em geral, pelos seguintes motivos: 1) os riscos referentes ao desenvolvimento não representariam, propriamente defeito do produto ou serviço, já que o CDC só proíbe o fornecimento de produtos ou serviços que o fornecedor “sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança” (art. 10 do CDC); 2) o CDC considera defeituosos apenas os produtos e serviços que “não oferece(m) a segurança que dele(s) legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...) II - o uso e os riscos que **razoavelmente dele se esperam**; III - a **época em que foi colocado em circulação**.” (Grifei).

Outros autores (Herman Benjamin, Sérgio Cavalieri e Bruno Miragem), entretanto, entendem que o risco do desenvolvimento não rompe o nexo de causalidade, pois: 1) Não há menção expressa do CDC; 2) O acolhimento de tal teoria vai de encontro aos princípios da



vulnerabilidade (art. 4º, I do CDC) e da reparação integral (art. 6º, VI do CDC), transferindo o risco da atividade desproporcionalmente ao consumidor; 3) o defeito ligado ao desenvolvimento é uma forma de defeito de concepção. No sentido disposto por esta segunda corrente, o Enunciado nº 43 da I Jornada de Direito Civil afirma que: “A responsabilidade civil pelo fato do produto, prevista no art. 931 do novo Código Civil, também inclui os riscos do desenvolvimento.”

2. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DO REGIME DE RESPONSABILIDADE DO CDC

2.1. DANOS AO TEMPO COMO BEM JURÍDICO AUTÔNOMO

Trata-se de discussão suscitada pela doutrina e recentemente analisada no campo jurisdicional, a qual se liga a viabilidade de se reputar valor juridicamente tutelável ao tempo do consumidor para efeito de proteção.

Atualmente, a questão vem sendo debatida principalmente em torno da **teoria do desvio produtivo do consumidor**, a qual trata das hipóteses em que o consumidor se vê obrigado a renunciar a seu tempo para solucionar problemas criados pelo fornecedor, os quais são vistos como ato ilícito.

A questão já foi enfrentada pela jurisprudência do STJ, ocasião em que se afirmou a possibilidade de reparação do desvio produtivo, conforme se extrai dos seguintes precedentes: 1) AREsp 1.260.458 / SP: O STJ entendeu que houve dano moral quando o consumidor passa por verdadeiro calvário para obter o estorno pretendido, no caso, passaram-se dois anos entre o ajuizamento da ação e a sentença; 2) AREsp 1.241.259 / SP: a 4ª Turma do STJ fixou indenização de R\$15 mil em favor do consumidor diante da “frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício ‘sério’, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento”; 3) REsp 1.737.412 / SE: dano moral coletivo por descumprimento reiterado de limites de espera em filas de banco.

Releva destacar que, em geral, o STJ defere a indenização pelo desvio produtivo a título de dano moral, sendo controversa a natureza jurídica da indenização na doutrina, havendo doutrinadores que defendem seu caráter autônomo.

2.2. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL MÉDICO

Como visto, o regime de responsabilização dos profissionais liberais, em caso de acidente de consumo, possui natureza subjetiva (art. 14, § 4º do CDC), demandando comprovação de culpa para seu reconhecimento, ressaltando, como já visto, o caso em que há contratação de obrigação de resultado, ocasião em que a culpa do médico é presumida, como ocorre na cirurgia plástica embelezadora que não apresenta o resultado esperado (ex: REsp 985888/SP).

De outro lado, uma coisa é a responsabilidade do médico, como profissional liberal, outra coisa é a responsabilidade do hospital, pois este é um fornecedor de serviços também. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto aos serviços por ele prestados (ex: estadia internação, instalações, equipamentos, serviços auxiliares, como exames, imagens, radiografias, etc). Mas, em se tratando de um erro de atuação médica de profissional que componha seus quadros (contratado pelo hospital), a responsabilidade só existirá se ficar comprovada a culpa dos médicos.

De todo modo, em se tratando de médico que não seja contratado pelo hospital (ex: aluga a estrutura para fazer uma cirurgia), não haverá responsabilização do nosocômio se houver erro no procedimento, haja vista a inexistência de nexo de causalidade.

Outro aspecto relevante sobre o tema médico está ligado ao entendimento do STJ que responsabiliza os planos de saúde por atos praticados por profissionais médicos e clínicas a credenciados por eles (REsp 866.371/RS).



3. JURISPRUDÊNCIA SOBRE A TEORIA DA QUALIDADE

3.1. DANOS CONSIDERADOS *IN RE IPSA*

- Inclusão/manutenção em cadastros negativos. REsp 432177. REsp 597.814.
- Se os correios não comprovar a efetiva entrega de carta registrada postada pelos clientes REsp 1.097.226.
- *Súmula 370/STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.*
- *Súmula 388/STJ: A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.*
- *Súmula 403/STJ: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.*

3.2. DANOS QUE NÃO SÃO CONSIDERADOS *IN RE IPSA*

- Atraso de voo – pacificado pelo STJ. Deve-se provar no caso concreto os prejuízos ao consumidor (REsp 1.584.465 / MG).
- Alimento com corpo estranho (REsp 1.395.647-SC) = dano moral *in re ipsa* – ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REsp 1.424.304/SP. Tendência de retorno à jurisprudência antiga na Terceira Turma no REsp 1744321 / RJ e REsp 1.828.026-SP, embora Quarta Turma mantenha exigência de ingestão (ex: REsp 1744321/RJ);
- Dano sofrido pela pessoa jurídica. REsp 1.564.955;
- Inclusão de valor indevido na fatura de cartão de crédito e/ou saque indevido. (REsp 1.550.509 / RJ).

Questões

1) (Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: TJ-AL Prova: FCC - 2019 - TJ-AL - Juiz Substituto) — No que concerne à qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos nas relações de consumo,

- A) o comerciante só será responsabilizado perante o consumidor se não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
- B) os produtos e serviços colocados no mercado de consumo em nenhuma hipótese poderão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores.
- C) o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de nexo de causalidade, na modalidade de risco integral.
- D) o fornecedor de produtos e serviços deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados nesse fornecimento, ou colocados à disposição do consumidor, informando, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.



E) a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais dar-se-á objetivamente, na modalidade do risco atividade.

2) (Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-AC Prova: VUNESP - 2019 - TJ-AC - Juiz de Direito Substituto) — Maria da Silva comprou um aparelho celular e, durante o regular uso, a bateria superaqueceu e explodiu, ferindo a sua sobrinha que estava manuseando o aparelho. Diante desse fato hipotético, assinale a alternativa correta quanto à responsabilidade do fornecedor.

A) Há responsabilidade do fornecedor por fato do produto, pois o aparelho se apresentou defeituoso, causando danos aos consumidores.

B) Não há responsabilização do fornecedor pelos ferimentos na sobrinha com base na legislação consumerista, pois o aparelho celular não lhe pertence e, desse modo, não é considerada consumidora.

C) Trata-se de dano causado por vício do produto, devendo Maria da Silva e a sobrinha serem reparadas pelos danos patrimoniais e físicos sofridos.

D) O fornecedor se exime da responsabilidade de reparar os danos se conseguir comprovar a inexistência de culpa pelo defeito do aparelho celular.

Comentários

1) A) Incorreta. A responsabilidade do comerciante em caso de fato do produto é subsidiária e ocorre nos casos do Art. 13 do CDC: “quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados” (inciso I); “quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador” (inciso II); “no caso de produtos perecíveis, o comerciante não os conservar adequadamente” (inciso III). O erro ocorre porque há omissão dos incisos I e II.

B) Incorreta. O art. 8º do CDC estabelece que “Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.” (Grifei). Portanto, a periculosidade inerente é aceita.

C) Incorreta. Em desconformidade com o art. 12 “caput” do CDC, que afirma que “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem,



fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.” O CDC estabelece apenas responsabilidade objetiva, não se filiando à teoria do risco integral (conforme excludentes de nexo de causalidade do arts. 12, § 3º e 14, § 3º do CDC) e nem dispensando a ocorrência de nexo de causalidade.

D) Correta. Corresponde ao conteúdo do art. 8º, § 2º do CDC: “O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.”

E) Incorreta. O Art. 14, § 4º do CDC estabelece que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

2) A) Correto. No caso de fato do produto o fornecedor responderá pelo dano (CDC, art. 12).

B) Incorreto. A sobrinha será considerada consumidora por equiparação (“bystander”), nos termos do art. 17 do CDC.

C) Incorreto. Como destacado, a hipótese trata de fato do produto, também nomeada acidente de consumo, tratada pelo art. 12 do CDC.

D) Incorreto. Nos termos do “caput” do art. 12 do CDC a responsabilidade pelo fato do produto é objetiva.



CAPÍTULO 5 — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NO CDC

O Código de Defesa do Consumidor encerra o tema da garantia legal com o estabelecimento de prazo decadenciais e prescricionais. Explique-se: 1) o art. 24 do CDC afirma que “A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor”; 2) e qual é a garantia legal de adequação? A referente ao regime dos arts. 12 a 20 do CDC, ou seja, a que garante a reparação pelo fato e pelo vício do produto; 3) a partir de quando o consumidor possui essa garantia? Desde a aquisição do produto ou serviço; 4) e até quando? Até a expiração do prazo decadencial ou prescricional, conforme o caso.

Daí deriva a importância de se estudar os prazos prescricionais e decadenciais sob a ótica do CDC: definir até qual momento o consumidor pode exigir do fornecedor a reparação por um vício ou por um fato do serviço.

O regime de prescrição e decadência encontra-se nos arts. 26 e 27 do CDC, separando prazos e instituições de acordo com a hipótese de vício ou fato do produto. Nesse sentido, a categoria conceitual da prescrição é aplicável ao fato do produto ou serviço (acidente de consumo), e a categoria conceitual da decadência é aplicável ao vício produto ou serviço.

O prazo para a parte reclamar de um **vício** de um produto ou serviço é um **prazo decadencial**, definido pelo art. 26 do CDC:

- **30 dias para produtos duráveis** (inciso I - Produto durável é aquele que não se esgota com a sua primeira utilização, ou com a sua aquisição. Ex.: carro, celular, vestido de casamento, roupa etc.);
- **90 dias para produtos não duráveis** (inciso II).

De outro lado, o art. 27 do CDC afirma que **prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço** (acidente de consumo).

1. APLICAÇÃO RESTRITA DOS PRAZOS EXTINTIVOS DO CDC

A aplicação de tais prazos tem recebido interpretação restritiva por parte do STJ, que tem restringido a incidência de seu regramento aos casos que tecnicamente se evidenciam como fato ou vício do produto. Tal afirmação pode parecer ser lógica, mas, na prática, há grande controvérsia, gerada principalmente pela existência de prazos diversos no CCB e em outros diplomas legais, como, por exemplo, o prazo previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações movidas em desfavor do poder público.

Um exemplo disso é que o Código Civil, no art. 205, diz que **a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor**, sendo que o STJ afirma que esse é o prazo para reclamar danos contratuais (REsp 1.281.594). Ainda, o art. 206, §3º, V, do CC diz que **a prescrição para a reparação civil ocorre em 3 anos**. Nesses casos, em comparação com o prazo prescricional aplicável ao acidente de consumo (5 anos), a lei civil, para reparação do dano extracontratual (3 anos), fixou prazo menor, enquanto para o dano contratual, fixou prazo maior (10 anos).

Para facilitar a compreensão cite-se os seguintes precedentes sobre o tema:

- Erro médico é fato do serviço e prescreve em 5 anos, nos termos do art. 27 do CDC (AgInt no AREsp 1127015 / MG);
- Restituição Tarifas Elétrica, Esgoto e Telefonia é demanda submetida a regime especial de direito público e, à falta de disposição específica, prescreve no prazo genérico de 10 anos do art. 205 do CCB (REsp 1.113.403/RJ e REsp 1.512.465/RS);
- Súmula 477 do STJ - "A decadência do art. 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre a cobrança de taxas, tarifas e encargos



bancários”. Nesses casos o STJ vem entendendo que o prazo prescricional é o decenal previsto no art. 205 do CCB - AgInt no AREsp 606001 / MG);

- Complementação de indenização securitária segue o prazo de um ano previsto no art. 206, § 1º, II do CCB (Recurso Especial 574.947/BA). Lembre-se que o prazo prescricional do art. 206, § 1º, II do CCB somente se aplica à relação entre seguradora e segurado. No caso de terceiros beneficiários o prazo prescricional é o decenal previsto no art. 205 do CC/02 (AgInt no AREsp 178910 / MG);
- As pretensões indenizatórias decorrentes do furto de joias, objeto de penhor em instituição financeira, prescrevem em 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no art. 27 do CDC. (REsp 1.369.579-PR - 2018/VUNESP /TJ-RS);
- Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes possui prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, § 3º, V do CCB (AgInt no AREsp 1073899/RS);
- Aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do CC/02 às ações indenizatórias por danos materiais decorrentes de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido pelo consumidor, e não o prazo decadencial estabelecido pelo art. 26 do CDC. (REsp 1.534.831-DF);

2. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

O termo inicial do prazo prescricional no CDC se dá a partir do conhecimento do dano e da sua autoria, nos termos dos arts. 26, §§ 1º e 3º e 27, “caput” do CDC.

O CDC, assim como o CCB, adota a teoria da “**actio nata**” para definição do termo inicial do prazo extintivo. Isso implica em dizer que tanto o prazo prescricional quanto o decadencial se iniciam quando o **consumidor toma ciência da existência do vício ou do defeito do produto**.

Assim, no caso em que o vício ou defeito do produto forem ocultos ou só se manifestarem após certo tempo de uso, o legislador vai estabelecer expressamente que sua contagem se dará a partir do momento em que “ficar evidenciado o defeito” (art. 26, §3º) ou, no caso de defeito, quando houver o “conhecimento do dano e de sua autoria” (art. 27, “caput” do CDC).

Isso significa que o fornecedor fica eternamente sujeito a essa reclamação?

NÃO. Entende o STJ que **essa garantia contra vícios ocultos persiste durante o período de vida útil do bem** (REsp 984.103 / SC).

Portanto, os prazos para exercício de garantia legal têm seu início com a aquisição do produto ou serviço e seu fim com o transcurso do prazo decadencial ou prescricional, os quais se iniciam com o surgimento do vício ou defeito, desde que o produto ainda esteja em sua vida útil.

Vale lembrar que, nos termos do art. 50 do CDC (ex: garantia estendida), a garantia contratual é complementar à legal, de modo que o seu prazo de cobertura se inicia após o fim do prazo estimado para a vida útil do bem no caso de vício ou defeito oculto.

Quanto ao conceito de vida útil, insta salientar que, em geral, deve ser expressamente estabelecido pelo fornecedor, nos termos do art. 31 do CDC. À falta de tal informação, a durabilidade do bem deve ser apurada no caso concreto (ex: bateria de celular que perde capacidade de recarga após um mês da aquisição está evidentemente viciada).

3. CAUSAS QUE SUSPENDEM A DECADÊNCIA

O art. 26, §2º do CDC estabelece exceção ao regime geral da decadência previsto no art. 207 do CCB, afirmando que **obstam a decadência**:

- **A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca:**



O STJ vem entendendo que a reclamação não demanda qualquer tipo de formalidade, bastando a ciência inequívoca do fornecedor (ex: e-mail informando o problema, reclamação perante o SAC mediante anotação de protocolo, reclamação no “chat” do “site” etc. - REsp 1.442.597 / DF);

- **A instauração de inquérito civil, até seu encerramento:**

O prazo decadencial ficará suspenso até o encerramento da investigação pelo MP nas hipóteses em que houver apuração mediante instauração de Inquérito Civil Público.

Insta salientar que, por força do veto apostado no inciso II do art. 26, §2º do CDC, a reclamação realizada perante o PROCON não suspende o prazo decadencial.

Questões comentadas

1) Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: TJ-MS Prova: FCC - 2020 - TJ-MS - Juiz Substituto — Mariana adquiriu numa loja uma geladeira nova, para utilizar em sua residência. Apenas dois dias depois da compra, o produto apresentou vício, deixando de refrigerar. Mariana então pleiteou a imediata restituição do preço, o que foi negado pelo fornecedor sob o fundamento de que o produto poderia ser consertado. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assiste razão

A) à Mariana, por se tratar de produto essencial, circunstância que lhe garante exigir a imediata restituição do preço, ainda que o vício do produto possa ser sanado.

B) à Mariana, em virtude de o vício ter se manifestado dentro do prazo de sete dias contado da compra, circunstância que lhe garante exigir a imediata restituição do preço, ainda que o vício do produto possa ser sanado.

C) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que pode ser aumentado ou diminuído por convenção das partes.

D) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que não pode ser aumentado nem diminuído por convenção das partes.

E) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que não pode ser aumentado, mas pode ser diminuído por convenção das partes.

A alternativa A é a correta. Nos termos do art. 18, § 3º do CDC: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício,



a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.” A geladeira é produto essencial. Logo, havendo vício no produto, o consumidor pode exigir imediatamente alguma das alternativas do art. 18, § 1º do CDC.

2) Ano: 2019 Banca: MPE-GO Órgão: MPE-GO Prova: MPE-GO - 2019 - MPE-GO - Promotor de Justiça – Reaplicação

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é tido pela doutrina como uma norma principiológica, diante da proteção constitucional dos consumidores, que consta, especialmente, do art.5º, XXXII, da Constituição Federal, ao enunciar que " o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor ".

Acerca do tema e da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a alternativa correta:

A) O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual.

Correta. Dispõe o art. 50 do CDC que “A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.” O STJ entende que “O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual.” (Jurisprudência em Teses do STJ, Edição nº 42)

B) O prazo de decadência estabelecido no art. 26 do CDC é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre a cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.

A súmula nº 477 do STJ estabelece que “A decadência do art. 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.”

C) O Superior Tribunal de Justiça não admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Incorreta. O STJ adota a teoria finalista mitigada para conceituação da pessoa do consumidor. (Jurisprudência em Teses do STJ, Edição nº 39)



D) Em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), aplica-se a inversão do ônus da prova previsto art.6º, inciso VIII, do CDC ("ope judicis").

Incorreta. Os arts. 12, § 3º e 14, § 3º do CDC estabelecem hipóteses de inversão "ope legis" do ônus da prova nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço.



CAPÍTULO 6 — DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

1. TEORIA MAIOR E TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Quando uma pessoa jurídica é criada no Direito Privado talvez a mais importante criação seja a autonomia patrimonial, isto é, separar os bens do sócio, dos bens da personalidade jurídica, esta é a regra geral, o que a teoria faz é romper isto – A origem clássica da teoria diz que nos casos em que houver fraude ou abuso, o juiz fica autorizado a levantar o véu para atingir a pessoa física que está atrás.

Segundo o art. 28 do CDC, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver **abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social**. A desconsideração também será efetivada quando houver **falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração**.

A redação do *caput* se assemelha ao conteúdo do art. 50 do Código Civil. No entanto, o §5º do art. 28 afirma que: “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica **sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.**”

Sobre o tema destaque-se a existência de duas teorias:

1.1. TEORIA MAIOR

Prevista no art. 50 do Código Civil, exige, como visto, o preenchimento de algum dos seguintes requisitos:

1.1.1. DESVIO DE FINALIDADE

Caracteriza-se pelo uso abusivo ou fraudulento (**teoria maior subjetiva**).

1.1.2. CONFUSÃO PATRIMONIAL

Caracteriza-se pela não separação entre o patrimônio da pessoa e o patrimônio de seus sócios (**teoria maior objetiva**).

Portanto, para aplicação da vertente maior, prevista no art. 50 do CCB, não basta a insolvência ou a impossibilidade de reparação do dano pela pessoa jurídica, sendo indispensável que tenha havido o abuso da personalidade jurídica, que poderá se dar pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

1.2. TEORIA MENOR

Trata-se da teoria adotada pelo CDC, a qual não exige fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. Para sua aplicação, basta que o consumidor demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica aptos a saldar a dívida.

Importante destacar que o CDC, diversamente do que prevê o CCB, admite a realização da desconsideração da personalidade jurídica de ofício pelo juiz, em especial quando se tem em mente a própria redação do art. 28 “caput” (“O juiz poderá desconsiderar...” e o já mencionado caráter de ordem pública das disposições consumeristas (art. 1º, “Caput” do CDC). Cuida-se de entendimento já acolhido pela jurisprudência do STJ (REsp. 279.273/SP).

Entretanto, o Novo CPC condicionou a realização da desconsideração da personalidade jurídica à instauração de um incidente processual (art. 133 a 137 do NCPC). Segundo o NCPC, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou a pedido do Ministério Público, quando for o caso (art. 133, “caput” do NCPC), o que apresenta óbice à atuação de ofício do juiz, haja vista não estar ele legitimado pela regra do art. 133, “caput” do NCPC.



Embora não tenha havido manifestação do STJ sobre o tema, há de se mencionar que o caráter de ordem pública das disposições consumeristas, aliado à vulnerabilidade do consumidor, parece autorizar a instauração de ofício pelo juiz do incidente de desconconsideração de personalidade jurídica no bojo de demanda consumerista, especialmente com fulcro no art. 28, “caput” e § 5º do CDC.

Ademais, a desconconsideração da personalidade jurídica pode se dar de maneira inversa, conforme art. 135 do NCPC. Na formulação tradicional, levanta-se o véu para atingir o patrimônio da pessoa física sócia da pessoa jurídica. No caso da desconconsideração inversa ocorre o contrário, ou seja, atinge-se o patrimônio de na pessoa jurídica para responder por débitos da pessoa física que compõe seu quadro social.

2. SOCIEDADES INTEGRANTES DE GRUPOS SOCIETÁRIOS, SOCIEDADES CONTROLADAS, SOCIEDADES CONSORCIADAS E SOCIEDADES COLIGADAS

O §2º do art. 28 diz que as sociedades integrantes dos **grupos societários** e **as sociedades controladas**, são **subsidiariamente** responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. O conceito de grupo societário encontra-se no art. 265 e seguintes da Lei nº 6.404/76, enquanto o de sociedades controladas está apresentado no art. 243, § 2º da mesma lei.

Questão atual acerca de grupos societários e sociedades controladas é a relativa às empresas de tecnologia que, embora não tenham sede no Brasil, operam através de aplicativos no país. Nestas situações, poder-se-ia cogitar de se condicionar o acionamento da pessoa jurídica sediada no exterior para, só então, em caso de inadimplência, se viabilizar o acionamento da pessoa jurídica componente do grupo econômico que é sediada no Brasil (ex: acidente de consumo ligado a aplicativo oferecido no Brasil, mas gerenciado por pessoa jurídica própria sediada no estrangeiro, a qual, contudo, é controlada por multinacional de tecnologia que possui sede no país.)

Embora a situação ainda não tenha sido explorada em detalhes, o que se tem percebido é que as cortes pátrias têm entendido que a controladora deve responder pelos danos da controlada situada no exterior em função do comando do art. 7º, p.u. e 25, § 2º do CDC.

O §3º do art. 28 diz que as **sociedades consorciadas** são **solidariamente** responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. O conceito de consórcio encontra-se previsto no art. 278, § 1º da Lei nº 6.404/76. Vale dizer que a regra do CDC, por contrariar o comando da Lei de Sociedades Anônima, deve ser interpretada de maneira restritiva, permitindo solidariedade entre consorciadas apenas no que tange às obrigações relativas ao consórcio e não a qualquer ato tomado por elas isoladamente (REsp 1.635.637 / RJ).

O §4º diz que as sociedades **coligadas** só responderão por **culpa**. O conceito de sociedades coligadas encontra-se no art. 243, § 1º da Lei nº 6.404/76.

As regras desses dispositivos costumam ser cobradas através da reprodução da letra da lei nas provas objetivas de concurso.

Questões comentadas

1) Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-BA Prova: CESPE - 2019 - TJ-BA - Juiz de Direito Substituto (ADAPTADA)

À luz da jurisprudência e da legislação acerca do direito das relações de consumo, assinale a opção correta.

(...)

B) As sociedades controladas e as consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do CDC.



Incorreta. Em desconformidade com o Art. 28 § 2º do CDC: “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.”

(...)

E) Atos lesivos praticados por representantes autônomos de determinado produto ou serviço são de responsabilidade subsidiária dos fornecedores daquele produto ou serviço.

Incorreta. Em desconformidade com o Art. 34 do CDC: “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

2) Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: TJ-SP Prova: VUNESP - 2018 - TJ-SP - Juiz Substituto — Nas obrigações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, pelo defeito do produto, as sociedades

A) coligadas, consorciadas ou integrantes dos grupos societários e as controladas são solidariamente responsáveis, independentemente de culpa.

Incorreta. As sociedades coligadas só responderão por culpa, nos termos do Art. 28, § 4º do CDC: “As sociedades coligadas só responderão por culpa”, enquanto as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do CDC, conforme Art. 28, § 3º do CDC: “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.”

B) coligadas só respondem por culpa, as consorciadas são solidariamente responsáveis e as integrantes dos grupos societários, ou controladas, são subsidiariamente responsáveis.

Correta. As sociedades coligadas só responderão por culpa, nos termos do Art. 28, § 4º do CDC: “As sociedades coligadas só responderão por culpa”; as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do CDC, conforme Art. 28, § 3º do CDC: “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.” Por fim, nos termos do Art. 28, § 2º do CDC: “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.”

C) integrantes dos grupos societários e as controladas são solidariamente responsáveis, as consorciadas respondem subsidiariamente e as coligadas só responderão por culpa.

Incorreta. Nos termos do Art. 28, § 2º do CDC: “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.”

D) consorciadas e as coligadas respondem solidariamente, mas só por culpa, e as integrantes dos grupos societários ou controladas são subsidiariamente responsáveis.

Incorreta. As sociedades coligadas só responderão por culpa, sem solidariedade, nos termos do Art. 28, § 4º do CDC: “As sociedades coligadas só responderão por culpa”.



CAPÍTULO 7 — PRÁTICAS COMERCIAIS

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

O Capítulo V do CDC traz 6 seções:

- Das Disposições Gerais
- Da Oferta
- Da Publicidade
- Das Práticas Abusivas
- Da Cobrança de Dívidas
- Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores

O art. 29 diz que, para os fins deste Capítulo e do seguinte, **equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas**. Portanto, qualquer pessoa que tome contato com qualquer tipo de prática publicitária ou prática abusiva é considerado consumidor, independentemente de ter ou não contratado o serviço ou produto ligado à publicidade, oferta ou prática comercial.

2. OFERTA

2.1. EFEITO VINCULANTE DA OFERTA PUBLICITÁRIA

O art. 30 do CDC diz que **toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada** por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, **obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado**.

Tal dispositivo consagra o **princípio da vinculação da oferta**. Trata-se de princípio que decorre da boa-fé objetiva, pois o dever de lealdade, cooperação, informação e transparência deve existir antes, durante e após a celebração do contrato e mesmo após a execução do contrato.

Para que seja tido como vinculante, a oferta tem que possuir dois requisitos essenciais: A) Deve ter sido **veiculada ou publicizada** de alguma maneira; B) Deve ser razoavelmente **precisa**. Preenchidos tais requisitos, a oferta atua de duas maneiras: A) **obriga o fornecedor a contratar** com o consumidor que se proponha a atender seus termos; B) **integra o contrato** que vier a ser celebrado. Portanto, a oferta publicitária, no âmbito do CDC, é irretratável.

Entretanto, o STJ vem admitindo que, na hipótese em que se evidenciar a ocorrência de **erro grosseiro**, aquele facilmente perceptível aos olhos do próprio consumidor (ex: o anúncio se equivoca com a inserção de um zero e acaba por ofertar uma TV por R\$ 150,00 ao invés de R\$ 1.500,00).

Eventual recusa de cumprimento de oferta gera o efeito previsto no art. 35 do CDC, que dispõe que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, **o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha**:

- **Exigir o cumprimento forçado da obrigação (tutela específica)**, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- **Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;**
- **Rescindir o contrato**, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

A conversão em perdas e danos só pode ocorrer se o consumidor por ela optar ou se for impossível a tutela específica.



2.2. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CORRETAS E PRECISAS

Trata-se de dever que também decorre do direito de informação e da boa-fé objetiva. O art. 31 estabelece que **a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa** sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

As informações acima, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma **indelével**, nos termos do parágrafo único do art. 31.

Como se percebe da redação do “caput”, o art. 31 estabelece rol exemplificativo de informações que devem constar da oferta, valendo mencionar que, observados os princípios da transparência e da informação (art. 4º, “caput” e 6º, III do CDC), deve o fornecedor apresentar o máximo possível de informações úteis ao consumidor ligadas ao produto ou serviço, em especial aquelas que influam em sua decisão por adquiri-lo, bem como as ligadas a eventuais repercussões da aquisição para sua saúde.

Nesse sentido, o art. 2º, III da Lei nº 10.962/04 contém diretrizes de observância obrigatória acerca da forma de oferta a ser observada pelos fornecedores que se valem da “internet” para comercializar seus produtos e serviços.

2.3. OFERTAS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Segundo o art. 32, “os **fabricantes e importadores** deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição **enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.**”

Enquanto o fornecedor estiver fabricando e importando o produto é necessário assegurar a oferta de peças de reposição. O parágrafo único diz que, cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida **por período razoável**, na forma da lei. Perceba-se que a lei não fixou o prazo, mas o art. 13, XXI do Decreto 2.181/97 afirma que o dever de fornecimento de peças deve se guiar pela vida útil do bem ou serviço fornecido.

O descumprimento do dever de oferta de peças de reposição é espécie de prática abusiva que pode estar estritamente ligado à ocorrência de **obsolescência programada**, assim entendida a prática comercial que dolosamente reduz a vida útil de um bem ou serviço visando forçar o consumidor a adquirir novas versões.

Trata-se de fenômeno já repudiado pelo STJ, que assim afirmou: “Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo (REsp 984.106 / SC).

São exemplos de tal conduta: atualizações de software que, desarrazoadamente, não contemplam versões mais antigas do produto; fabricação de componentes com baixa duração aliada a cobrança de valores altos para reposição, quadro que força o consumidor a adquirir novas versões; criação de barreiras artificiais na reposição de peças após a inserção no mercado de nova versão do produto ou serviço.

De fato, para além de representar ofensa à boa-fé objetiva, a prática de obsolescência programada também viola a Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4º, II, “d” do CDC), que expressamente trata da questão da durabilidade adequada.



2.4. VENDA POR TELEFONE E REEMBOLSO POSTAL

Segundo o art. 33, **em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal**, deve constar o **nome do fabricante e endereço** na embalagem, na publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial.

Trata-se de dever que decorre do princípio da transparência, pois permite a adequada identificação do fornecedor quando do recebimento do produto, nas hipóteses em que a aquisição foi realizada à distância. No particular, embora não haja menção à internet, em virtude da data de publicação do CDC, o comando do art. 33 do CDC mostra-se plenamente aplicável às compras realizadas virtualmente, haja vista o fato de se tratar de regra que deriva da principiologia consumerista (art. 4º, “caput” e 6º, III do CDC).

O parágrafo único diz que **é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina.**

O CDC, também em virtude da época em que foi publicado, trata relativamente pouco da questão relativa à publicidade por telefone, valendo mencionar que a questão dos “call centers” é regulada pelo Decreto nº 6.523/2008, o qual prevê expressamente que a ligação originada ou destinada a esse tipo de atendimento será gratuita.

Também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) trata da questão, devendo ser lida em sintonia com o princípio da vulnerabilidade (art. 4º, I do CDC) na busca da proteção do sossego e tranquilidade do consumidor quando alvo de práticas publicitárias, sendo recorrente o reconhecimento de que a realização de ligações exaustivas e em horários não convencionais (após as 22 horas durante a semana e aos finais de semana) são hipóteses geradoras de dano moral, por se tratar de hipótese de abuso de direito (art. 187 do CCB), violadora da boa-fé objetiva.

2.5. SOLIDARIEDADE DO FORNECEDOR PELOS ATOS DOS PREPOSTOS OU REPRESENTANTES AUTÔNOMOS

De acordo com o art. 34 do CDC, **o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável** pelos atos de seus **prepostos ou representantes autônomos.**

Trata-se de regra de extensão do comando do art. 932, III do Código Civil Brasileiro, a qual ganha especial relevância na relação consumerista, onde a vulnerabilidade do consumidor deve prevalecer diante de eventuais acordos ou estruturas formais pactuadas entre fornecedores para a oferta de um determinado serviço ou produto.

A relação de preposição é marcada pela subordinação. Logo, preposto é “aquele que presta serviço ou realiza alguma atividade por conta e sob a direção de outrem, podendo essa atividade materializar-se em uma função duradoura (permanente) ou em um ato isolado (transitório)⁴⁰”. De outro lado, representante autônomo, como o próprio nome sugere, é a pessoa física ou jurídica que atua sem relação empregatícia mas representando, de maneira não eventual, o fornecedor. A relação de agência autônoma é regulamentada, entre outros, pelos arts. 710 a 721 do CCB, que tratam do contrato de agência e distribuição, além dos comandos da Lei 4.886/65, que também tratam da representação comercial autônoma.

Um exemplo da aplicação do dispositivo em comento é o da corretagem imobiliária no caso da incorporação. Nessas hipóteses, contrariamente ao sustentado pelas incorporadoras, no sentido de que os corretores imobiliários que trabalhavam em “stands” de venda eram autônomos, o STJ reconheceu a existência de direito do consumidor em receber a restituição dos valores de corretagem nas hipóteses em que haja a rescisão do contrato por culpa da construtora (ex: atraso – Edcl no AgInt no AREsp 1220381/DF)

O art. 34 do CDC encontra-se aliado à aplicação da chamada **teoria da aparência**, que estabelece que, à luz de uma leitura permeada pela boa-fé objetiva, em especial no que tange

⁴⁰ ANDRADE, Adriano et. Al. Interesses Difusos e Coletivos Vol. 1. 9ª ed. Editora Método, 2019, P.655.



ao princípio da confiança, todo ato praticado por pessoa que razoavelmente se evidenciar como representante de um determinado fornecedor diante do consumidor deve vincular tal fornecedor.

Questões comentadas

1) Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RO Prova: VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto (ADAPTADA)

Para colocação dos seus produtos e serviços na economia, o fornecedor deve adotar práticas comerciais condizentes com as regras existentes no sistema jurídico de proteção ao consumidor, sendo certo que

A) o fornecedor do produto ou serviço é subsidiariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Incorreta. Conforme art. 34 do CDC: “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

(...)

C) se equiparam aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas em questão.

Correta. Nos termos do Art. 29 do CDC: “Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

2) Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: TJ-AL Prova: FCC - 2019 - TJ-AL - Juiz Substituto (ADAPTADA)

Considere os enunciados concernentes às relações de consumo:

I. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, ou pleitear perdas e danos.

Incorreta. Nos termos do art. 35, III do CDC: “Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Logo, as perdas e danos são cumulativas com o direito de rescisão, em observância ao princípio da reparação integral.



CAPÍTULO 8 — PUBLICIDADE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

A publicidade assume dimensão de extrema importância na sociedade contemporânea, motivo pelo qual foi objeto de preocupação pelo legislador durante a elaboração do CDC. Entende-se por publicidade “toda informação ou comunicação difundida com o fim direto ou indireto de promover, junto aos consumidores, a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço, qualquer que seja o local ou meio de comunicação utilizado⁴¹”. Releva destacar que a publicidade se diferencia da propaganda, sendo esta última marcada por “fim ideológico, religioso, político, econômico ou social⁴²”.

A publicidade pode ser **institucional**, quando voltada a promover o fornecedor de produtos ou serviços em si, e **promocional**, quando busca incrementar e expandir a venda de um produto ou serviço específico.

O ordenamento jurídico brasileiro adota **sistema misto** de regulamentação e controle da publicidade, sendo o CDC, ao lado de outros dispositivos (ex: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018), a forma de controle legal das relações publicitárias. A tal forma de controle, se alia o sistema privado de regulamentação, especificamente representado pela atuação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR).

1. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE

O microsistema consumerista apresenta uma série de princípios que atuam na prática publicitária.

1.1. PRINCÍPIO DA IDENTIFICAÇÃO

Representado pelo comando do art. 36 do CDC, que estabelece que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal, ou seja, a identifique como publicidade.

O consumidor tem o direito de saber quando a mensagem é publicitária.

E o merchandising? Seria lícito ou ilícito?

“Pela técnica do *merchandising*, hoje comum em novelas de televisão, nos filmes e mesmo nas peças teatrais, um produto aparece na tela e é utilizado ou consumido pelos atores em meio à ação teatral, de forma a sugerir ao consumidor uma identificação do produto com aquele personagem, história, classe social ou determinada conduta social. O aparecimento do produto não é gratuito, nem fortuito; ao contrário, existe um vínculo contratual entre o fornecedor e o responsável pelo evento cultural, sendo que o fornecedor oferece uma contraprestação pelo espaço de divulgação para o seu produto.⁴³”

Apesar da redação do art. 36, o *merchandising* tem sido admitido.

E o puffing?

O *puffing* é uma técnica de exagero publicitário. Este tipo de exagero, também denominado como *dolus bonus*, é admitido. Ex.: “compre o melhor sorvete do mundo!”.

E o teaser?

Outro recurso de técnica de “marketing” é o “teaser” que representa uma espécie de provocação da curiosidade do consumidor para chamar sua atenção para uma determinada campanha de “marketing” (Ex: “não compre o item x essa semana! Semana que vem a loja y fará preços inacreditáveis!”). Embora tal estratégia não conte com identificação clara de alguns elementos da mensagem publicitária, sua utilização tem sido reputada válida.

⁴¹ Marques, Cláudia Lima, et al. Comentários ao Código de defesa do consumidor. 6a edição revista, atualizada e ampliada, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2019, RL-1.12 “E-book”.

⁴² ANDRADE, Adriano et. Al. Interesses Difusos e Coletivos Vol. 1. 9ª ed. Editora Método, 2019, P.658.

⁴³ Marques, Cláudia Lima, et al. Comentários ao Código de defesa do consumidor. 6a edição revista, atualizada e ampliada, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2019, RL-1.12 “E-book”.



1.2. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL

Trata-se de postulado ligado à aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, os quais já foram analisados acima. Basicamente, dispõe que a mensagem publicitária vincula o anunciante.

1.3. PRINCÍPIO DA VERACIDADE

Cuida-se de diretriz expressamente adotada no art. 37, § 1º do CDC que determina que toda informação utilizada em campanha publicitária deve estar integralmente comprometida com a verdade, o que veda recurso a informações não comprovadas ou falsas. A integridade da informação publicitária foi alvo de ampla cautela do legislador, em especial no trato da questão relativa à vedação da publicidade enganosa, que será estudada adiante.

1.4. PRINCÍPIO DA NÃO ABUSIVIDADE

Em complemento ao princípio da veracidade, não basta que a publicidade traga informações verdadeiras, pois tais dados devem também ser livres de componentes abusivos, na exata extensão do art. 37, § 2º do diploma consumerista. Aqui, também, a questão será aprofundada adiante.

1.5. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o art. 36, parágrafo único do CDC: “**o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.**” Portanto, antes de qualquer questionamento, incumbe ao responsável por veicular a mensagem publicitária a obtenção e guarda de todos dados técnicos que corroborem as afirmações realizadas na peça de promoção, as quais podem ser demandadas pelo consumidor a qualquer tempo e/ou pelo judiciário, nos termos do art. 38 do CDC, tudo sob pena, inclusive, de responsabilização criminal (art. 69 do CDC).

1.6. PRINCÍPIO DA LEALDADE PUBLICITÁRIA

O art. 4º, VI do CDC estabelece como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”. Parte da doutrina extrai desse comando a diretriz do princípio da lealdade publicitária, que vincularia eticamente os fornecedores quando da realização de suas práticas de “marketing”, visando coibir atitudes desleais entre eles que viessem a prejudicar o consumidor. Possui especial relevo na análise deste princípio a questão relativa à publicidade comparativa (realizada por um anunciante expressamente contemplando e exibindo outros produtos de concorrentes), a qual, embora não seja vedada por si, deve atender regras de especial diligência, em especial as previstas no art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária.

2. PUBLICIDADE ABUSIVA E ENGANOSA

O art. 37 “caput” do CDC diz que é **proibida** toda **publicidade enganosa** ou **publicidade abusiva**. Ciente do potencial de dano que pode ser causado pelas práticas publicitárias, o legislador atua de maneira incisiva contra a má utilização de tais expedientes, estabelecendo regime de vedação peremptória de práticas que considera desconformes com o microsistema consumerista.

Nesse sentido, o §1º do art. 37 afirma que **é publicidade enganosa** qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, **inteira ou parcialmente falsa**, ou, por qualquer outro modo, **mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor** a respeito



da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Portanto, o que se percebe é que a **publicidade enganosa por comissão** está ligada à **falsidade** da informação veiculada, bem como à sua capacidade de induzir o consumidor a cometer erro de julgamento quanto ao produto de maneira abrangente (quanto ao uso, durabilidade, qualidade, etc.)

O §3º aduz que, para os efeitos do CDC, a publicidade é **enganosa por omissão** quando deixar de informar sobre **dado essencial** do produto ou serviço. O STJ entende que a obrigação de informação exige um comportamento ativo do fornecedor. **O STJ rejeita o denominado “caveat emptor”**, que é a chamada **subinformação**. Segundo o “*caveat emptor*”, quem deve procurar informação é o consumidor, caso queira se resguardar de eventuais danos. No Brasil, quem deve prestar a informação é o fornecedor, a fim de evitar o consumidor de sofrer danos. (AgRg no AgRg no REsp 1261824 / SP)

De outro lado, segundo o §2º do art. 37, é **abusiva**, dentre outras a publicidade **discriminatória** de qualquer natureza (ex: gênero, raça, idade, cor, etc.), a que **incite à violência**, explore o **medo ou a superstição**, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da **criança**, desrespeite **valores ambientais**, ou que seja capaz de **induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança**.

A publicidade abusiva, portanto, encontra-se ligada à integridade física e moral do consumidor, possuindo conceito aberto, ligado ao rol exemplificativo contido no §2º do art. 37, o que faz a doutrina lhe atribuir caráter residual, no sentido de que seria abusiva toda publicidade que não fosse enganosa e que agredisse os valores consagrados no ordenamento jurídico.

A publicidade enganosa e abusiva é **aferida objetivamente**, não interessando se o sujeito atuou culposamente, ou se tinha intenção de enganar ou praticar conduta abusiva, sendo também **irrelevante a causação efetiva de dano**. Ou seja, basta que se prove a capacidade da publicidade de induzir o consumidor a erro ou causar situação abusiva para que seja ela reputada enganosa ou abusiva, respectivamente, sendo irrelevante a comprovação de prejuízo em desfavor do consumidor ou de que este tenha, de fato, adquirido o produto ou serviço anunciado.

A publicidade enganosa vincula a empresa que foi por ela beneficiada. Mesmo que haja erro de terceiro, a empresa que promoveu a publicidade enganosa responderá por ela. O STJ entende que a emissora de televisão não responde pela publicidade de palco. Ex.: Apresentador faz propaganda de produto, caso haja dano ao consumidor tanto o apresentador quanto a emissora não responderão em solidariedade com a empresa (REsp 1.157.228 / RS).

3. ÔNUS DA PROVA NA COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA

O art. 38 diz que o **ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina**.

Trata-se de hipótese de inversão da prova “*ope legis*”, que, diversamente do que ocorre no caso do art. 6º, VIII do CDC, independe da atuação do juiz, pois já se encontra prevista na legislação. Dessa forma, existindo questionamento acerca de dados ligados à publicidade, deverá o fornecedor responsável por sua veiculação fornecer todos os dados requeridos, os quais, inclusive, já devem estar em sua posse, nos termos do art. 36, parágrafo único do CDC.

4. SANÇÕES

Considerando-se que o CDC veda expressamente a veiculação de publicidade abusiva ou enganosa (art. 37), resta saber quais as consequências para o descumprimento de tais vedações.

A **contrapropaganda**, segundo os arts. 56, XII c/c 60 do CDC, é a principal consequência a ser apontada em caso de veiculação de publicidade abusiva ou enganosa. De fato, a



contrapropaganda, segundo o art. 60, “**será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva**, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, **sempre às expensas do infrator.**”

Conforme estabelecido pelo § 1º do art. 60, “a contrapropaganda **será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.**”

Portanto, por se tratar de sanção administrativa, a veiculação de contrapropaganda pode ser determinada pela autoridade de defesa do consumidor (ex: PROCON), conforme comando do parágrafo único do art. 56, sendo de se destacar que sua finalidade principal é a de desfazer os malefícios causados pela informação enganosa ou abusiva.

Dessa forma, o conteúdo da contrapropaganda deve deixar clara a existência do equívoco (abusividade ou enganabilidade), apontando exatamente qual ele é e o porquê de ser equivocado, devendo, ainda, dar destaque adequado à informação verdadeira, que deveria ser veiculada a princípio e/ou ao dado adequado a ser informado em caso de abusividade.

Por fim, para além da contrapropaganda, **a publicidade enganosa ou abusiva também é penalizada criminalmente**, nos termos dos **arts. 67 a 69 do CDC**, que serão objeto de estudo futuro. Tal fator evidencia a gravidade da conduta do fornecedor que apresenta comportamento desleal e antissocial na veiculação de seus produtos na visão do legislador.

Questões comentadas

1) Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: TJ-MS Prova: FCC - 2020 - TJ-MS - Juiz Substituto
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a publicidade que explora a superstição dos consumidores é

- A) abusiva e enganosa.
- B) abusiva, apenas.
- C) enganosa, apenas.
- D) enganosa por omissão.
- E) permitida, desde que não seja contrária aos bons costumes.

Correto o item B. Nos termos do art. 37, § 2º do CDC: “É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.” (Grifei)

2) Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-PA Prova: CESPE - 2019 - TJ-PA - Juiz de Direito Substituto.

No que se refere a publicidade de bens e serviços de consumo, teaser consiste na

- A) publicidade socialmente aceita, mesmo que contenha expressões exageradas.

Incorreto. O conceito aqui se assemelha ao de “poofing”.



B) técnica publicitária que tem por objetivo inserir produtos e serviços nos meios de comunicação sem que haja declaração ostensiva da marca.

Incorreto. Trata-se de conceito similar ao de “merchandising”.

C) publicidade que implica a utilização de aspecto discriminatório de qualquer natureza.

Incorreto. A publicidade que apresenta aspecto discriminatório é tida por abusiva, nos termos do art. 37, § 2º do CDC.

D) publicidade que induz o consumidor a erro quanto a informações relevantes sobre produto ou serviço.

Incorreto. Tal tipo de publicidade é a ligada ao “recall”, em cumprimento ao dever imposto pelo art. 10, §§ 1º e 2º do CDC, que tratam da periculosidade superveniente.

E) mensagem que visa criar expectativa ou curiosidade no público acerca de determinado produto ou serviço.

Correto. Esse é o conceito de “teaser”. O verbo “tease” em inglês tem significado similar ao de provocação em português. Logo, o fornecedor que se vale da técnica “teaser” deseja provocar o consumidor, inspirando curiosidade para atrair atenção a seu produto ou serviço.



CAPÍTULO 9 — PRÁTICAS ABUSIVAS

1. PRÁTICAS ABUSIVAS EM ESPÉCIE

O art. 39 do CDC afirma que “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, **dentre outras** práticas abusivas”. Em seus incisos, o comando traz 13 práticas que considera abusivas. Conforme se extrai da expressão “dentre outras” contida no “caput” e da redação do inciso V do art. 39, trata-se de rol **exemplificativo**, que enumera algumas das práticas que, ao tempo da publicação do CDC, eram reputadas pelos legisladores como abusivas.

As práticas abusivas representam, em verdade, padrões de comportamento adotados por fornecedores que violam a principiologia e regramento do Código de Defesa do Consumidor, vilipendiando **direitos titularizados pelos consumidores individualmente ou coletivamente**.

Como se pode notar da descrição das hipóteses contidas nos incisos do art. 39 e da própria definição do que se entende por práticas abusivas, há de se destacar que estas podem ocorrer em qualquer momento da relação de fornecimento. Ou seja, **as práticas abusivas podem ser identificadas durante a execução do contrato e pré ou pós contratualmente**.

Ademais, a prática abusiva pode decorrer de uma **ação ou omissão** do fornecedor, **não se fazendo necessária a apuração de culpa e de resultado** para que seja reputada sua ocorrência. Ou seja, basta que seja verificada a ocorrência de conduta do fornecedor que possa ser reputada abusiva para que surtam os efeitos dela decorrentes (anulação de disposições contratuais, reparação do consumidor e/ou punições administrativas – arts. 6º, VO c/c 39 c/c 55 e seguintes do CDC), sendo irrelevante a apuração de elemento subjetivo (culpa “lato sensu”) ou prejuízo efetivo para a capitulação propriamente dita (tais elementos podem influir na extensão da pena a ser aplicada, mas são irrelevantes para se apurar a ocorrência em si de prática abusiva⁴⁴).

Vistas as linhas gerais sobre as práticas abusivas, há de se analisar o conteúdo dos incisos do art. 39 do CDC.

1.1. VENDA CASADA OU IMPOSIÇÃO DE LIMITES QUANTITATIVOS PELO FORNECEDOR

Segundo o art. 39, I do CDC, **é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços**, dentre outras práticas abusivas, **condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço**, bem como, **sem justa causa**, sujeitar o fornecimento de produto ou de serviço a **limites quantitativos**.

A primeira situação, ligada ao condicionamento do fornecimento de um bem ou serviço à aquisição de outro é o que se denomina **venda casada**. Com essa disposição pretende o legislador proteger a liberdade de escolha do consumidor (art. 6º, II do CDC). Um exemplo de venda casada foi julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo através do Tema 958, ocasião em que se firmou o entendimento de que não se pode obrigar o consumidor que contrata mútuo a contratar seguro com o banco mutuante ou com instituição por ele indicada (REsp 1.639.259/SP). No mesmo sentido, também é considerada venda casada a proibição de consumo de produtos adquiridos fora do cinema em seu interior (REsp 744.602 / RJ).

Para além da venda casada tradicional, expressamente descrita no inciso I do art. 39, a jurisprudência do STJ também reconhece a ocorrência da **venda casada às avessas , indireta ou dissimulada** nas hipóteses em que “a venda de ingressos em meio virtual (internet) (é) vinculada

⁴⁴ A apuração de elemento subjetivo mostra-se relevante para se verificar a ocorrência de crime contra as relações de consumo no caso em que a prática abusiva também for tipificada no CDC ou em outras leis, sendo de se rememorar a independência entre as instâncias administrativa e judicial para todos os efeitos (ex: certa publicidade pode ser tida como abusiva por enganosidade para efeito de aplicação das sanções que decorrem do CDC, mas pode não ser reputada crime do art. 67 do CDC por ausência de comprovação de dolo (“sabe ou deveria saber”).



a uma única intermediadora e mediante o pagamento de taxa de conveniência” (REsp 1.737.428/RS). Nessa situação, o STJ definiu a venda casada às avessas como “se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício, é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor.”

Da mesma forma, ainda de acordo com o inciso I do art. 39, **não é possível limitar quantitativamente a aquisição de um produto sem justa causa**. A justa causa da limitação quantitativa deve ser apurada concretamente em alinhamento com o microsistema consumerista. Ex: o taxista que não quer levar o sujeito porque a corrida é de curta distância ou para local diverso do que pretende ir viola o dispositivo. De outro lado, o estabelecimento comercial que limita o número de itens vendidos em uma promoção para garantir acesso ao maior número possível de consumidores está impondo limitação razoável. No mesmo sentido, em algumas circunstâncias, o STJ tem admitido a imposição de limite quantitativo mínimo através da fixação de tarifa básica, conforme se afere do conteúdo da Súmula 356 do STJ, que trata da tarifa básica na telefonia fixa.

1.2. RECUSA DE CONTRATAR PELO FORNECEDOR

É prática abusiva, segundo o art. 39, II do CDC, a conduta de **recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque**, e, ainda, **de conformidade com os usos e costumes**. Busca o legislador coibir práticas discriminatórias de qualquer tipo.

Exemplo recente de aplicação do dispositivo é o precedente do STJ no sentido de que “A seguradora não pode recusar a contratação de seguro a quem se disponha a pronto pagamento se a justificativa se basear unicamente na restrição financeira do consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito. (REsp 1.594.024-SP).

1.3. PRODUTOS ENVIADOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA

O inciso III do art. 39 do CDC diz que é prática abusiva a conduta de **enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia**, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço. Em complementação, o parágrafo único do art. 39 afirma que **os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor equiparam-se às amostras grátis**, inexistindo obrigação de pagamento

A Súmula 532 do STJ, em reforço a esse comando, aduz que “constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem expressa e prévia solicitação do consumidor”. Neste caso, haverá um ato ilícito, que é indenizável, sem prejuízo de eventual aplicação de multa administrativa.

1.4. HIPERVULNERABILIDADE

Segundo o inciso IV do art. 39 do CDC é prática abusiva a conduta de se prevalecer da **fraqueza ou ignorância** do consumidor, **tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social**, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Trata o legislador das hipóteses denominadas pela doutrina de **hipervulnerabilidade**, em que a característica da vulnerabilidade inerente a todo consumidor (art. 4º, I do CDC) é aprofundada diante de elementos pessoais específicos ali enumerados.

Adotando-se o espírito de interpretação de textura aberta e principiológica do diploma consumerista, há de se reputar como exemplificativo o rol de pessoas tidas como “hipervulneráveis”, o que viabiliza o reconhecimento de outras hipóteses em que o consumidor deve receber tutela especial diante do fornecedor (ex: gênero).



Um exemplo de prática abusiva nesta seara é a relativa a cobrança realizada por hospitais de valores adicionais em desfavor de pacientes que possuem plano de saúde (REsp 1.324.712 / MG). De outro lado, o STJ reconheceu inexistir abusividade “(N)O critério de vedação ao crédito consignado – a soma da idade do cliente com o prazo do contrato não pode ser maior que 80 anos” (REsp 1.783.731-PR), pois o seu estabelecimento atua no sentido de evitar o superendividamento.

1.5. EXIGÊNCIA DE VANTAGENS EXCESSIVAS

O inciso V do art. 39 do CDC estabelece que é prática abusiva exigir do consumidor **vantagem manifestamente excessiva**. Trata-se de conceito jurídico indeterminado que atua como **cláusula geral** de verificação de práticas abusivas.

Dada a semelhança entre a expressão “vantagem manifestamente excessiva” e a locução “vantagem exagerada” prevista no art. 51, IV do CDC, a doutrina e a jurisprudência têm se valido das definições previstas nos incisos do § 1º do art. 51 como norte interpretativo para aferição da ocorrência de prática abusiva que represente “vantagem manifestamente excessiva”.

A maior preocupação do legislador em ambos casos é a manutenção do equilíbrio contratual (art. 6º, V do CDC), observada a harmonização dos interesses entre fornecedor e consumidor (art. 4º, II do CDC), sem se descuidar da vulnerabilidade deste (art. 4º, I do CDC).

1.6. EXECUÇÃO DE SERVIÇO SEM ORÇAMENTO PRÉVIO

O inciso VI do art. 39 do CDC reconhece como prática abusiva a conduta de executar serviços **sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa** do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes.

As características do orçamento que deve ser obrigatoriamente fornecido pelo fornecedor e aprovado expressamente pelo consumidor antes do início do serviço estão no art. 40 do CDC, que estabelece, em seu “caput”, como elementos obrigatórios do orçamento: “valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.”

Vale destacar que, nos termos do § 1º do art. 40 “salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo **prazo de dez dias**, contado de seu recebimento pelo consumidor” e que, nos termos do §2º do mesmo dispositivo “uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.”

Portanto, o orçamento é peça essencial para o regular fornecimento de serviço, dada sua eficácia em conferir previsibilidade às partes em termos de análise do conteúdo contratual, em especial acerca do objeto e cláusula financeira. Se o fornecedor realiza o serviço sem elaborá-lo, comete prática abusiva e deve arcar com os ônus de sua desídia.

O STJ já entendeu que o serviço prestado sem prévia elaboração de orçamento corresponde a amostra grátis (Res. 332.869 / RJ).

1.7. REPASSE DE INFORMAÇÕES DEPRECIATIVAS RELACIONADAS A CONSUMIDOR

Segundo o inciso VII do art. 39 do CDC é prática abusiva repassar **informação depreciativa**, referente a **ato praticado pelo consumidor** no exercício de seus direitos. Trata-se de dispositivo que tutela a intimidade do consumidor e inviabiliza sua punição em decorrência do exercício regular de direitos.

O repasse de informações mencionado no inciso pode ocorrer de qualquer meio, inclusive o digital (ex: redes sociais, provedores de busca etc.), vedando-se ao fornecedor a



realização de qualquer tipo de represália pública em decorrência da formulação de reclamações por parte do consumidor.

1.8. INSERÇÃO NO MERCADO DE PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

O inciso VIII do art. 39 afirma que é abusiva a conduta de colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em **desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes**.

Como já mencionado em outras passagens, o legislador entende como parâmetro razoável para se analisar o atendimento de parâmetros de qualidade mínima as normas editadas pelos órgãos normativos competentes, dentre os quais se destaca a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

A inobservância das disposições estabelecidas por tais órgãos é, por si, prática abusiva, e pode gerar sancionamento administrativo e civil, independentemente da ocorrência de vício ou defeito do produto, hipóteses que, acaso ocorridas, também acarretarão as sanções previstas nos arts. 12 a 20 do CDC.

1.9. RECUSA DE VENDA DIRETA DE BENS E SERVIÇOS

Nos termos do inciso IX do art. 39, é prática abusiva a conduta de **recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente** a quem se disponha a adquiri-los mediante **pronto pagamento**, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.

Visa o legislador coibir a imposição de intermediários que, sem motivo razoável, encareçam o custo do produto ou serviço ao consumidor. Note-se que a recusa ao fornecimento direto só é abusiva quando o pagamento se der à vista, o que evidencia que o fornecedor não pode ser obrigado a aceitar outras formas de pagamento (ex: cheque – Resp 229.586 / SE).

Quanto à forma de pagamento, releva notar que a Lei nº 13.455/17 estabelece a legalidade da diferenciação de preços de acordo com ao prazo e forma de pagamento (ex: valores mais altos para pagamento mediante uso de cartão).

1.10. ELEVAÇÃO DE PREÇO SEM JUSTA CAUSA

Nos termos do inciso X do art. 39 do CDC, configura prática abusiva **eleva sem justa causa o preço** de produtos ou serviços. Visa o legislador coibir a prática de variação abusiva dos preços, assim entendida como a que deriva de fator que não se relaciona ao menos razoavelmente com o custo final do produto ou serviço oferecido.

A verificação de abusividade de preços dialoga com a microeconomia, que também é conhecida como “teoria dos preços”, de modo que a precificação de produtos e serviços em um mercado livre como o brasileiro está submetida a inúmeras variáveis, a demandar redobrada cautela do intérprete quando do reconhecimento de abusividade de majoração de preços.

A aplicação do inciso X do art. 39 do CDC ocorre em situações de aumento de volatilidade decorrente de situações extraordinárias como as que influenciam o abastecimento (ex: greves) e em mercados onde há possibilidade de prática de condutas ilícitas ligadas à formação de preço (ex: combustível). Não por outra razão, o inciso X foi incluído no CDC pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994, que cuidou do sistema antitruste nacional de sua publicação até a edição da Lei nº 12.529, de 2011.

1.11. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO FORNECEDOR

Segundo o inciso XII do art. 39, constitui prática abusiva **deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação** ou **deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo**



critério. Trata-se de prática que viola o equilíbrio das prestações avençadas entre as partes, colocando o fornecedor em vantagem exagerada, já que o tempo também tem valor econômico, o que implica em dizer que a possibilidade de adiamento do prazo para cumprimento pelo fornecedor acabaria por encarecer o serviço ou produto vendido sem a necessária anuência do consumidor.

Sobre o tema, recentemente se pronunciou o STJ no sentido de que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019 (Tema 996).

1.12. APLICAÇÃO DE FÓRMULA OU ÍNDICE DE REAJUSTE DIVERSO DO LEGAL OU CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO

O inciso XIII do art. 39 afirma que configura prática abusiva **aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido**. A hipótese diz respeito aos percentuais de reajuste para recomposição do valor monetário (ex: IPCA, INPC, INCC etc.) A escolha do índice de reajuste pode implicar na majoração ou redução do valor nominal pago pelo consumidor, o que implica em dizer que deve haver estrita observância ao contratado ou ao que dispõe a lei.

1.13. SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO

O inciso XIV do art. 39 foi incluído pela Lei nº 13.425 de 2017, passando a afirmar a abusividade da prática de “permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo”.

Em geral, o percentual máximo de lotação de estabelecimentos que recebem público é estabelecido no momento de obtenção de autorização administrativa para funcionamento (“alvará”). A desobediência a tal limitação é prática abusiva, para além de poder configurar o crime previsto no art. 65, § 2º do CDC.

2. PRODUTOS OU SERVIÇOS SUJEITOS AO REGIME DE CONTROLE DE PREÇOS

O art. 41 afirma que, **no caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de não o fazendo**, responderem pela **restituição da quantia recebida em excesso**, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha, o **desfazimento do negócio**, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

3. COBRANÇA DE DÍVIDAS

De acordo com o “caput” do art. 42 do CDC: “na cobrança de débitos, **o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.**”

Se é certo que a cobrança de valores efetivamente devidos é exercício regular de um direito pelo fornecedor, não é menos certo que a sua exacerbação, através da utilização de expedientes que exponham o consumidor a ridículo ou lhe causem constrangimento ou ameaça é nítida forma de abuso de direito, a qual deve ser reprimida e gera direito a reparação.

A cobrança abusiva poderá, também, conforme o caso, gerar consequências penais, nos termos do art. 71 do CDC, que afirma que é crime punido com detenção de três meses a um ano



e multa: “Utilizar, na cobrança de dívidas, de **ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas** ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou **interfira com seu trabalho, descanso ou lazer**”.

Logo, os arts. 42 e 71 se complementam no sentido de delinear, exemplificativamente, formas abusivas de cobrança que merecem repressão, sendo certo que as condutas previstas no tipo penal e não repetidas no art. 42, “caput” (uso de coação, afirmações falsas incorretas ou enganosas e procedimentos que interfiram com o trabalho, descanso ou lazer do consumidor) são, também, formas de cobrança abusivas, pois são tipos de constrangimento incompatíveis com o exercício regular do direito de cobrança, nos exatos termos do art. 42, “caput” do CDC.

A cobrança abusiva pode ser alvo de repressão administrativa (arts. 56ss do CDC), civil (indenização) e criminal (art. 71 do CDC).

Um exemplo de forma abusiva de cobrança é a suspensão de serviços públicos visando reprimir dívidas antigas (ex: no caso da energia elétrica as faturas que justificam o corte em caso de inadimplência são as referentes aos últimos 90 dias, conforme Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica - AgInt no REsp 1789030 / RS).

De outro lado, percebe-se que o art. 42 “caput” não veda a cobrança do consumidor em seu local de trabalho. Entretanto, a realização de tal procedimento de maneira que exponha o consumidor a situação constrangedora é sim foco de repressão civil (Ex: ligações incessantes ou aviso a colegas de trabalho que o consumidor está em débito).

Em todas as hipóteses, nos termos do art. 42-A do CDC: “Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente.”

4. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO CDC

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que “o consumidor **cobrado em quantia indevida** tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao **dobro do que pagou** em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de **engano justificável**.”

Visando desestimular a cobrança indevida e fomentar o exercício de rígido controle por parte dos fornecedores quanto às cobranças por eles realizada, o legislador estabeleceu o direito do consumidor de receber em dobro os valores que tenha eventualmente pago indevidamente.

Perceba-se que o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece três requisitos para que o consumidor faça jus à devolução em dobro: 1) **Cobrança**: O consumidor tem que ter sido efetivamente cobrado do valor indevido (não pode voluntariamente realizar o pagamento mediante impressão de boleto por exemplo); 2) **Pagamento**: A quantia indevidamente cobrada tem que ter sido efetivamente quitada pelo consumidor; 3) **Engano não justificável**: A cobrança tem que derivar de engano não justificável cometido pelo fornecedor. A jurisprudência do STJ tem divergido sobre o tema: A 1ª seção tem entendido que basta a ocorrência de culpa do concessionário para a devolução em dobro (ex: REsp 1.079.064 / SP); a 2ª seção entende, em geral, que a expressão “engano justificável” se identifica com a **má-fé** (ex: AgInt no REsp 1502471 / RS). A questão encontra-se, contudo, pendente de debate nos EAREsp nº 664888 / RS para pacificação dos entendimentos.

O STJ já decidiu ser cabível a devolução em dobro na hipótese de cobrança indevida por prestação de serviço de água e de esgoto que não existiu. Ora, uma coisa é cobrar a mais pelo serviço prestado. Mas se não foi sequer prestado o serviço, não haverá erro justificável.

O pagamento fundado em cláusula contratual posteriormente declarada nula não enseja devolução em dobro, pois o engano do fornecedor deve ser reputado como justificável (EREsp nº 328.338 / MG).

Há de se destacar, ademais, que a jurisprudência (REsp nº 1645589 / MS) tem afirmado que **a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC se restringe às hipóteses de cobrança**



extrajudicial de dívida consumerista, restando a cobrança judicial de dívida consumerista regida pela aplicação do art. 940 do CCB, a qual também encontra-se vinculada à comprovação de má-fé.

Questões comentadas

1) Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: TJ-MS Prova: FCC - 2020 - TJ-MS - Juiz Substituto

Renato, cliente de determinada operadora de telefonia, recebeu fatura cobrando valor muito superior ao contratado. Percebendo o equívoco, Renato deixou de pagar a fatura e contatou a operadora, requerendo o envio de outra, com o valor correto. No entanto, apesar de reconhecer a falha, a operadora enviou nova fatura cobrando o mesmo valor em excesso, razão pela qual Renato novamente se recusou a pagar. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Renato

- A) tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso na primeira fatura, apenas.
- B) tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso em cada uma das duas faturas.
- C) tem direito de receber o dobro do valor total da primeira fatura, apenas.
- D) tem direito de receber o dobro do valor total de cada uma das duas faturas.
- E) não tem direito de receber o dobro do valor cobrado em excesso ou do total de nenhuma das faturas.

Proposição correta é a letra E. O direito à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC depende da ocorrência de pagamento prévio. Como Renato não pagou, ele não faz jus à repetição em dobro.

2) Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-AC Prova: VUNESP - 2019 - TJ-AC - Juiz de Direito Substituto

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:

- A) estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a exclusivo critério do consumidor.

Incorreta. O art. 39, XII, do CDC afirma que é prática abusiva do fornecedor (e não o consumidor) deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

- B) elevar o preço de produtos e serviços, ainda que com apresentação de justo motivo.

Incorreta. É prática abusiva, segundo o inciso X do art. 39 do CDC, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

- C) inserir cláusulas contratuais que transfiram responsabilidades a terceiros.

Correta. Assertiva em conformidade com o art. 51, III, do CDC.



D) inserir cláusulas contratuais que determinem a utilização facultativa da arbitragem.

Incorreta. Apenas a imposição compulsória da arbitragem é cláusula abusiva, nos termos art. 51, VII, do CDC.



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



61 3033-3739



61 98442-2591

CAPÍTULO 10 — BANCO DE DADOS E CADASTRO DE CONSUMIDORES

O art. 43 do CDC afirma que: “o consumidor (...) terá acesso às informações existentes em **cadastros, fichas, registros e dados pessoais e dados de consumo arquivados** sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes dessas informações.”

Releva notar a diferença entre bancos de dados e cadastro de consumidores. Ambos são espécies de arquivo de consumo, sendo os **bancos de dados** repositórios de informação que são fornecidas pelos próprios fornecedores (ex: “ranking” de crédito e cadastros negativos - art. 2º, I da Lei nº 12.414/11). Já os **cadastros de consumidores** contêm dados e informações fornecidas pelos próprios consumidores (ex: informações pessoais fornecidas por consumidor para abertura de cadastro).

Em geral, a grande parte das discussões sobre o tema gira em torno dos bancos de dados de proteção ao crédito, que são responsáveis por controlar a inadimplência dos consumidores e fornecer os dados negativos acerca dos créditos não honrados.

Considera-se que o consumidor possui três direitos básicos com relação aos cadastros:

1. DIREITO A SER COMUNICADO PREVIAMENTE

Trata-se de direito consagrado no § 2º do art. 43, que afirma que “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo **deverá ser comunicada por escrito** ao consumidor, quando não solicitada por ele.” Nos termos da Súmula 359 do STJ, a obrigação da realização da notificação prévia do consumidor **é atribuída à entidade mantenedora do cadastro de proteção** ao crédito, sendo que tal comunicação escrita, conforme teor da Súmula 404 do STJ, **dispensa o envio de AR**. De todo modo, quando a informação já existe em cadastros públicos (ex: cartórios de protesto e de distribuição judicial) o consumidor não precisa ser comunicado do mero transporte de tais informações para os bancos de dados. (REsp 1.444.469/DF e REsp 1.344.352/SP)

2. DIREITO DE ACESSAR A INFORMAÇÃO

O CDC não veda que os fornecedores mantenham e tratem informações relativas aos consumidores, sejam elas positivas ou negativas, para efeito de traçar estratégias comerciais. Entretanto, o legislador deixa claro o direito do consumidor de **acesso amplo, integral e gratuito** às informações que lhe digam respeito, bem como o dever de **transparência e veracidade** imposto ao fornecedor, no sentido de que as informações armazenadas devem ser fidedignas e demonstráveis. Não por outra razão, o §6º do art. 43 do CDC afirma que “todas as informações (...) devem ser disponibilizadas em **formatos acessíveis**, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.” Ademais, ainda sobre a qualidade da informação, o §1º do art. 43 do CDC dispõe que “os cadastros e dados de consumidores devem ser **objetivos** (sem juízos de valor ou pessoais), **claros** (inteligíveis e facilmente verificáveis), **verdadeiros** e em **linguagem de fácil compreensão**”.

3. DIREITO À CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES

O descumprimento dos requisitos acima importa em ato ilícito, sendo o consumidor titular do direito de correção e obtenção de explicações detalhadas sobre seus dados, nos termos do §3º do art. 43, que afirma que “o consumidor, sempre que encontrar inexactidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua **imediata correção**, devendo o arquivista, **no prazo de 5 dias úteis**, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.” A correção deve ser realizada imediatamente, após constatado o equívoco, embora o procedimento para constatação seja de sete dias, conforme art. 5º, III da Lei nº 12.414/2011.

Acaso o consumidor seja surpreendido com **inscrição (“negativação”) falsa**, como a referente a dívida por ele não contraída, **ou que não obedeça os procedimentos de notificação prévia**, fara jus a reparação por **danos morais “in re ipsa”**, nos termos da jurisprudência pacífica



do STJ (Ag nº 1379761 / SP). Entretanto, o STJ tem entendido que se o nome do consumidor já estava inscrito por dívida anterior, a segunda ou posteriores inclusão/inclusões, ainda que equivocada(s) não gerará(ão) dever de indenizar por danos morais (**Súmula 385 do STJ**). Tal entendimento é fortemente criticado pela doutrina e o STJ tem demonstrado tendência em rediscuti-lo, havendo precedente recente flexibilizando o entendimento da súmula 385 para deferir danos morais quando também as inscrições anteriores estejam sendo questionadas e haja verossimilhança em tais questionamentos (REsp 1.647.795 e REsp 1.704.002).

Quanto à responsabilidade, o STJ tem entendido que a reparação deve ser suportada exclusivamente pelo fornecedor que solicitou a inclusão do nome do consumidor no banco de dados, não havendo solidariedade da entidade mantenedora do cadastro (REsp 748.561 / RS).

De acordo com o §4º do art. 43 do CDC, os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres **são considerados entidades de caráter público**. Tal tipificação legal independe da estruturação da pessoa jurídica responsável por gerir os cadastros, haja vista que grande parte das instituições que gerem tais bancos e cadastros são pessoas jurídicas privadas. A relevância da categorização dessas entidades como públicas é a viabilidade de se **ajuizar “habeas data”** para obtenção e correção de informações.

O §1º do art. 43 do CDC dispõe que as informações negativas referentes ao consumidor não podem permanecer inscritas por **período superior a cinco anos**, contados a partir do **dia subsequente ao vencimento da dívida** (REsp 1.316.117 / SC). A baixa da inscrição deve ocorrer após o transcurso dos cinco anos ou em caso de prescrição, se essa ocorrer antes, conforme § 5º do art. 43 do CDC. Conforme disposto no próprio dispositivo, a prescrição ali referida é a do ajuizamento da ação de cobrança e não da ação de execução, motivo pelo qual o STJ publicou a súmula de nº 323, que dispõe que “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Nos termos da Súmula 548 do STJ: “**Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis**, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” Dessa forma, cabe ao fornecedor que determinou a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes o dever de promover a baixa da inscrição, no prazo de cinco dias úteis. Entretanto, caso haja protesto de título, o STJ entende que a legislação aplicável é a especial, ficando a cargo do consumidor a promoção e custeio da baixa (REsp 959.114 / MS).

A **dívida discutida em juízo pode ser inscrita**, pois, no entendimento do STJ, o mero ajuizamento da ação pelo devedor não o torna imune à possibilidade de ser cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito (Resp 1.148.179 / MG). O consumidor poderá pedir tutela de urgência, pedindo a suspensão da negativação do nome. Para isso, é necessário preencher alguns pressupostos: A) Contestando da dívida integralmente ou parcialmente; B) Demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito (*fumus boni iuris*); C) Sendo a contestação de parte do débito, deverá depositar a parte incontroversa, ou prestação de caução idônea.

Por fim, é importante destacar que o sistema de “credit scoring” ou ranking de crédito é tido como válido pela jurisprudência (Súmula 550 do STJ) e legislação brasileiras (Lei nº 12.414/11). O “credit scoring” consiste na prática de análise de dados de consumidores para atribuição de nota com base no passado de pagamento de operações de crédito por eles contratadas. Nas palavras do STJ: “O sistema de crédito “scoring” é um método de desenvolvimento para avaliação dos riscos na concessão de créditos, a partir de dados estatísticos, considerando diversas variáveis com atribuição de uma pontuação do consumidor avaliado”. (REsp 1.419.697)

Inicialmente, a súmula 550 do STJ havia estabelecido a desnecessidade de consentimento do consumidor para sua inclusão no “credit scoring” (sistema de “opt out”), em especial diante dos efeitos positivos que dele advêm no que tange a concessão de crédito. Entretanto, com a publicação da Lei nº 12.414/11, o regulamento do cadastro positivo passou a



prever a expressa necessidade de assentimento expresso do consumidor para sua inclusão no ranking (sistema “opt in”).

Entretanto, tal situação se alterou com a nova redação do art. 4º da Lei nº 12.414/11, que foi dada pela Lei Complementar nº 166, de 2019, a qual expressamente dispensa o consentimento do consumidor para sua inclusão no “ranking”, bastando a comunicação ao consumidor de sua inclusão, no prazo de 30 (trinta) dias após a abertura (art. 4º, § 4º da Lei nº 12.414/11). Por outro lado, já na esteira do que o STJ decidiu, poderá o consumidor requerer da mantenedora do cadastro a retirada de seu nome ou a retificação e explicação de informações ali contidas (art. 5º da Lei nº 12.414/11).

De todo modo, a viabilidade de se abrir cadastros com dados pessoais sem anuência prévia do consumidor não autoriza que os fornecedores compartilhem dados pessoais ou os cataloguem de maneira pública sem a comunicação aos consumidores. Nesse sentido, o STJ se pronunciou recentemente, afirmando que: “Configura dano moral in re ipsa a ausência de comunicação acerca da disponibilização/comercialização de informações pessoais em bancos de dados do consumidor. Nessa toada, a gestão do banco de dados impõe a estrita observância das respectivas normas de regência – CDC e Lei n. 12.414/2011. Dentre as exigências da lei, destaca-se o dever de informação, que tem como uma de suas vertentes o dever de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele, consoante determina o § 2º do art. 43 do CDC. Embora o novo texto da Lei n. 12.414/2011 se mostre menos rigoroso no que diz respeito ao cumprimento do dever de informar ao consumidor sobre o seu cadastro – já que a redação originária exigia autorização prévia mediante consentimento informado por meio de assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada –, o legislador não desincumbiu o gestor de proceder à efetiva comunicação. (...) O fato, por si só, de se tratarem de dados usualmente fornecidos pelos próprios consumidores quando da realização de qualquer compra no comércio, não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados, na medida em que, quando o consumidor o faz não está, implícita e automaticamente, autorizando o comerciante a divulgá-los no mercado; está apenas cumprindo as condições necessárias à concretização do respectivo negócio jurídico entabulado apenas entre as duas partes, confiando ao fornecedor a proteção de suas informações pessoais. (REsp 1.758.799 / MG)”

Por fim, há também o cadastro de fornecedores nos termos do art. 44 do CDC: “os **órgãos públicos de defesa do consumidor** manterão cadastros atualizados de **reclamações fundamentadas contra fornecedores** de produtos e serviços, devendo divulgar essas informações de **maneira pública anualmente**. Essa divulgação **deverá indicar se a reclamação foi atendida ou não** pelo fornecedor. O §1º do art. 44 diz que “é facultado o acesso às informações constantes do cadastro para orientação e consulta por qualquer interessado”.

Questões comentadas

1) Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-PA Prova: CESPE - 2019 - TJ-PA - Juiz de Direito Substituto.

Acerca de bancos de dados e cadastros de consumidores, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do STJ.

A) O registro do nome do consumidor em bancos de dados deve ser precedido de comunicação escrita, na qual deve ser atestado o recebimento da notificação.

Incorreta. Em desconformidade com a Súmula 404 do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negatificação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”



B) A notificação que antecede a inscrição do nome do consumidor nos bancos de dados deve ser promovida pelo fornecedor que solicita o registro no órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.

Incorreta. Em desconformidade com a Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

C) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo estabelecido em lei, ainda que anteriormente ocorra a prescrição da execução.

Correta. Inspirada na redação da Súmula 323 do STJ: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

D) O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), é responsável por notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição nesse cadastro.

Incorreta. Em desconformidade com a Súmula 572 do STJ: “O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação.”

E) Efetuado o pagamento do débito pelo devedor, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a exclusão do registro da dívida no cadastro de inadimplentes.

Incorreta. Em desconformidade com a Súmula 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

2) Ano: 2019 Banca: MPE-GO Órgão: MPE-GO Prova: MPE-GO - 2019 - MPE-GO - Promotor de Justiça Substituto

Com o fim de limitar a atuação dos bancos de dados à sua função social - reduzir a assimetria de informação entre o credor/vendedor para a concessão e obtenção de crédito a preço justo o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabeleceu expressamente, em seu art. 43, § 1º, que os dados cadastrados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. À doutrina perfilha essa orientação ao afirmar que “a informação falsa ou inexata simplesmente não serve para avaliar corretamente a solvência da pessoa interessada na obtenção do crédito”. (BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 299). Acerca da temática e do atual posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a alternativa correta:

A) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

Correta. Em linha com a Súmula 323, STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.



B) A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitado por ele. Logo, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor após proceder à inscrição.

Incorreta. Em desconformidade com a Súmula 323, STJ: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

C) É indispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Incorreta. Contraria o entendimento da Súmula 404, STJ: “É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

D) Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, cabe indenização por dano moral, ainda quando preexistente legítima inscrição.

Incorreta. Em desconformidade com a Súmula 385, STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”



CAPÍTULO 11 — PROTEÇÃO CONTRATUAL

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Dentro da seção destinada à análise das práticas comerciais, o microssistema consumerista trata expressamente da proteção ao consumidor na seara contratual, buscando estabelecer normas especiais que ofereçam tratamento especial à parte vulnerável da relação de consumo.

Como já analisado no estudo dos princípios que regem o CDC, a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) existente nas relações consumeristas é atenuada pela **heteronomia** exercida pelo **caráter de ordem pública e interesse social** que emana das disposições do microssistema de direito de consumidor.

Isso implica dizer que os contratos regidos pelo CDC têm sua validade condicionada à observância dos princípios e regras contidos no microssistema consumerista, os quais são, em sua maioria, **irrenunciáveis** e submetidos uma **leitura constitucionalizada** da autonomia da vontade, que também exige o cumprimento de sua **função social** e a observância da **boa-fé objetiva**.

1.1. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E VINCULAÇÃO CONTRATUAL

O art. 46 do CDC estabelece que os contratos que regulam as relações de consumo **não obrigam os consumidores**, se:

- Não for dada a eles a oportunidade de tomar **conhecimento prévio** de seu conteúdo do contrato; ou
- Os respectivos instrumentos forem **redigidos de modo a dificultar a compreensão** de seu sentido e alcance.

Trata-se de implicação direta do **princípio da transparência**, que determina que a **informação no contrato deve ser clara, fácil, útil, completa e gratuita**, não se podendo aceitar a utilização de expedientes que deem margem a prejuízos à parte vulnerável da relação.

Entretanto, releva notar que as limitações contratuais, que restringem direitos do consumidor, são possíveis, desde que, para além de seguir as diretrizes da transparência e da boa-fé objetiva, sejam razoáveis e não abusivas.

1.2. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL

De acordo com o art. 47 do CDC: “As **cláusulas contratuais** serão interpretadas de **maneira mais favorável ao consumidor**.” Dessa forma, se o contrato submetido à disciplina do CDC possuir cláusula dúbia ou mal redigida, ou se houver conflito entre cláusulas ou dificuldade de se apurar seu âmbito de aplicação, a interpretação deverá ser dirigida favoravelmente ao consumidor.

Trata-se de disposição similar a prevista pelo art. 423 do CCB para o tratamento de contratos de adesão, dado o fato de que a grande maioria dos contratos previstos pelo CDC possui tal natureza, conforme se verá adiante, quando do estudo do art. 54 do CDC. Vale mencionar, contudo, que a regra do CDC é mais ampla e determina interpretação mais favorável também às cláusulas previstas em contratos que não sejam tidos como de adesão.

1.3. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR

O art. 48 do CDC estabelece que “as declarações de vontade constantes de **escritos particulares, recibos e pré-contratos** relativos às relações de consumo **vinculam o fornecedor**, ensejando inclusive execução específica.”

Trata-se de disposição que, em reforço aos comandos dos arts. 30 e 35 do CDC, prestigia a **boa-fé objetiva**, reconhecendo que o **princípio da confiança** influencia diretamente no ânimo da contratação, não compactuando com a frustração da expectativa razoavelmente gerada no consumidor.



A interpretação do art. 48 do CDC deve ser ampla, de modo a incluir como vinculantes todas as manifestações razoavelmente comprovadas, mesmo que implícitas, sendo de se notar que, por força do art. 34 do CDC e da já mencionada aplicação da teoria da aparência, a fonte de tais manifestações é ampla, sendo vinculantes aquelas que advêm de prepostos e representantes autônomos do fornecedor.

2. DIREITO DE REFLEXÃO OU DE ARREPENDIMENTO

O art. 49 do CDC estabelece que: “O consumidor pode **desistir do contrato**, no **prazo de 7 dias** a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer **fora do estabelecimento comercial**, especialmente por telefone ou a domicílio.”

Trata-se de **direito potestativo** conferido ao consumidor que possibilita prazo de reflexão, visando desestimular a adoção de práticas comerciais que estimulem a aquisição de produtos de maneira desmedida ou irracional, em contextos que favoreçam tal comportamento, como os que ocorrem nas transações realizadas fora do estabelecimento contratual.

Por se tratar de direito potestativo vinculado à proteção da parte vulnerável, o exercício da desistência **é incondicionado e não depende da existência de vício ou defeito do produto ou do serviço**, podendo ela ser imotivada. Portanto, basta o preenchimento dos dois requisitos básicos: aquisição fora de estabelecimento comercial e prazo de sete dias desde o recebimento, para que o consumidor faça jus a esse direito.

Note-se que a menção ao “telefone ou a domicílio” é meramente exemplificativa e ligada ao contexto social do momento de publicação do CDC, o que implica em dizer que o direito de arrependimento se estende a todas as compras não presenciais, **inclusive as realizadas pela internet**.

Caso o consumidor exercite o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Os gastos com a remessa de retorno do produto devem correr às expensas do fornecedor, não se podendo cogitar da sua transferência ao consumidor (REsp 1.340.604 / RJ).

Por fim, vale mencionar que o direito de arrependimento possui abrangência ampla e se aplica a contratos que envolvam todos produtos e serviços fornecidos no mercado de consumo. Entretanto, na aquisição de passagens aéreas, a Resolução 400/2016 da ANAC, em seu art. 11 estabelece que o prazo para desistência de passagem aérea adquirida pelo consumidor seria de 24 (Vinte Quatro) horas, o que, em tese, contraria o previsto no art. 49 do CDC.

Embora o STJ ainda não tenha se pronunciado sobre a matéria, o entendimento corrente na doutrina é o de que o ato infralegal citado não pode se sobrepôr à lei, em especial quando se tem em mente o caráter de ordem pública e interesse social do CDC, o que implica em dizer que a aquisição de passagem aérea online contaria sim com a garantia de sete dias prevista no art. 49 do CDC, reservando ao art. 11 da Resolução 400/2016 da ANAC a aplicação aos casos em que as passagens são adquiridas presencialmente.

3. GARANTIA CONTRATUAL

Como já analisado, o art. 24 do CDC estabelece a garantia legal de adequação do produto ou serviço, a qual independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Ademais, como também já ressaltado, a garantia legal corresponde aos regramentos dos arts. 12 a 20 do CDC, os quais podem ser acionados nos prazos extintivos previstos nos arts. 26 e 27 do mesmo diploma.



Entretanto, além da obrigação legal, o fornecedor poderá oferecer uma garantia contratual, a qual pode ser gratuita ou remunerada, conforme o caso. Conforme o art. 50 do CDC: **a garantia contratual é complementar à legal** e será conferida mediante **termo escrito**.

Portanto, **é a partir do término da garantia contratual que se inicia a contagem para a garantia legal**.

O parágrafo único do art. 50 afirma que o **“termo de garantia** ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada **em que consiste a mesma garantia**, bem como a **forma**, o **prazo** e o **lugar** em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

Mencione-se, ainda, que o art. 66 do CDC afirma ser crime “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”.

4. CLÁUSULAS ABUSIVAS

Transportando o conteúdo das garantias do microsistema consumerista à seara contratual, o legislador estabelece rol exemplificativo de cláusulas que reputa abusivas e, portanto, nulas. São consideradas abusivas as cláusulas que **desrespeitam os direitos e garantias estabelecidos pelo microsistema consumerista**.

Assim como ocorre com as práticas abusivas, o rol dos incisos do art. 51 do CDC é **exemplificativo**, como se pode aferir da expressão “entre outras” prevista no “caput” do dispositivo, bem como da redação dos incisos IV e XV do art. 51 do CDC, que estabelecem cláusulas gerais de controle da higidez das disposições contratuais. Nesse sentido, os arts. 12, 13 e 22 do Decreto nº 2.181/97 estabelecem extenso rol de práticas e cláusulas abusivas que servem como importante elemento de interpretação e integração das cláusulas abertas, valendo destacar que o art. 56 do Decreto nº 2.181/97 determina que “com o objetivo de orientar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor divulgará, anualmente, elenco complementar de cláusulas contratuais consideradas abusivas”.

No mesmo sentido da apuração das práticas abusivas, também a apuração da abusividade das cláusulas **independe da verificação de elemento subjetivo**, ou seja, também se submete à dogmática da responsabilidade objetiva, de modo que a simples existência de nexos de causalidade entre a atuação comercial do fornecedor e a disposição contratual reputada abusiva se mostra suficiente à apuração de nulidade.

Uma vez reconhecida a abusividade, **a cláusula será reputada nula**. Entretanto, nos termos do art. 51, § 2º do CDC: “A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes”. Portanto, aplica-se no microsistema consumerista o **princípio da conservação dos contratos**, devendo o contrato ser mantido na maior extensão possível após eventual declaração de nulidade de uma de suas cláusulas, salvo “ônus excessivo a qualquer das partes”.

Ademais, considerado o conteúdo do art. 1º, “caput” do CDC, é dever-poder do juiz o **reconhecimento de ofício** da nulidade das cláusulas que violam o microsistema consumerista, ressalvado o já mencionado caso enunciado na súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

O art. 51 diz que **são nulas de pleno direito**, entre outras:

4.1. INCISO I

As cláusulas contratuais que **impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios** de qualquer natureza dos produtos e serviços **ou impliquem renúncia**



(antecipada) ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o **fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada**, em situações justificáveis.

Este dispositivo traz **vedação à cláusula de não indenizar**, bem como a impossibilidade de atenuação da responsabilidade do fornecedor, em reforço ao que já estabelecido no art. 24 do CDC (“A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor”). No mesmo sentido, também as cláusulas que trazem renúncia antecipada de direitos são nulas de pleno direito quando submetidas ao microsistema consumerista.

A **única exceção** se dá em relação ao consumidor pessoa jurídica, caso em que a limitação será possível, desde que seja razoável esta limitação. Note-se que no caso de consumidor pessoa jurídica o que se permite é a limitação e não a completa exoneração e desde que haja situação justificável.

São exemplos de aplicação do art. 51, I do CDC as Súmulas 130 (“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”) e 638 (“É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil”) do STJ.

4.2. INCISO II

As cláusulas contratuais que **subtraíam ao consumidor a opção de reembolso** da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

Veda-se a cláusula de “decaimento”, garantindo ao consumidor o reembolso “nos casos previstos neste código”. No particular, o CDC aponta como hipóteses de reembolso: arts. 18, § 1º, II; 35, III; 42; 49; etc. Além dessas cláusulas, o CDC traz, em seu art. 53 afirma que: “Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.”

As cláusulas de decaimento serão melhor analisadas quando do estudo do art. 53.

4.3. INCISO III

As cláusulas contratuais que **transfiram responsabilidades a terceiros**;

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único e 25, § 2º do CDC, vige no microsistema consumerista o princípio da solidariedade na reparação dos danos, de modo que, tendo mais de um autor a ofensa, responderão solidariamente todos eles.

Tal principiologia inviabiliza a transferência de responsabilidades, o que, em última instância, implicaria em exoneração da responsabilidade do fornecedor. De todo modo, a leitura desse inciso não inviabiliza a inclusão solidária de outros responsáveis, como o que ocorre com o chamamento da seguradora (art. 101, II do CDC).

4.4. INCISO IV

As cláusulas contratuais que estabeleçam **obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada**, ou que sejam **incompatíveis com a boa-fé ou a equidade**;

Trata-se de **cláusula geral de verificação de abusividade**, dado o caráter aberto das disposições contidas em sua redação. Os incisos do § 1º do art. 51 do CDC trazem padrões interpretativos relevantes para a aplicação desta disposição:

O § 1º diz que **se presume exagerada**, entre outros casos, a vantagem que:

- **Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;**
- **Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;**



- Se mostra **excessivamente onerosa para o consumidor**, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Portanto, verifica-se que a margem interpretativa conferida ao intérprete é ampla para efeito de verificar a abusividade de cláusulas contratuais, permitindo o acompanhamento das evoluções das práticas comerciais, sempre em busca da tutela ideal da parte vulnerável, sem se descurar do equilíbrio contratual.

A plasticidade da cláusula geral em estudo tem ocasionado pronunciamentos de alta relevância pelo STJ, dentre os quais se destaca:

- 1) Súmula nº 302 do STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”;
- 2) Súmula nº 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”;
- 3) Súmula nº 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”;
- 4) Abusividade do cancelamento da passagem de retorno no caso de “No show” na ida (REsp 1595731/RO);
- 5) Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos. (EAREsp 793.323-RJ);
- 6) O teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, refere-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. (REsp 1.764.859-RS);
- 7) As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.⁴⁵ (REsp 1.712.163-SP);
- 8) Julgamento pelo STJ do tema repetitivo nº 958 sobre tarifas bancárias: Abusivas: 1) compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; 2) ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame; 3) ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 4) ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário. Válidas: tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato;
- 9) É vedada à operadora de plano de saúde a rescisão unilateral imotivada dos contratos de planos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários. (REsp 1.776.047-SP);
- 10) O critério de vedação ao crédito consignado – a soma da idade do cliente com o prazo do contrato não pode ser maior que 80 anos – não representa discriminação negativa que coloque em desvantagem exagerada a população idosa. (REsp 1.783.731-PR);
- 11) Ainda que a iniciativa pelo descredenciamento tenha partido de clínica médica, subsiste a obrigação de a operadora de plano de saúde promover a comunicação desse evento aos consumidores e à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência bem como de substituir a entidade conveniada por outra equivalente, de forma a manter a qualidade dos serviços contratados inicialmente. (REsp 1.561.445-SP);

⁴⁵ Note-se que o precedente foi firmado pela Segunda Seção do STJ, a indicar pacificação de entendimento no âmbito do STJ. Há de se destacar, ainda, que o RE-RG 657718, julgado pelo STF, que trata do mesmo tema (medicamento “off label”), trata apenas no poder público.



12) O rol de procedimentos de planos de saúde, fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constitui uma cobertura mínima obrigatória taxativa, e não exemplificativa, dos procedimentos.⁴⁶ (REsp 1.733.013/PR);

13) “É cabível o reembolso de despesas efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora ainda que a situação não se caracterize como caso de urgência ou emergência, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.” (REsp 1.760.955-SP);

14) O STJ tem se orientado no sentido de reconhecer a abusividade de previsões contratuais que estabeleçam cláusulas penais apenas em favor do fornecedor, admitindo, inclusive, a inversão de tais cláusulas no caso de mora do fornecedor. Nesse sentido: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1.498.484 / DF e REsp 1.631.485 / DF - Tema 971)

4.5. INCISO VI

As cláusulas contratuais que estabeleçam **inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor**;

Entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação dos seus direitos, permitindo a inversão do ônus da prova em seu benefício (arts. 6º, VIII, 12, § 3º, 14, § 3º, e 39, todos do CDC). O inciso V veda ao fornecedor o esvaziamento do conteúdo do direito básico previsto em benefício do consumidor, corroborando a irrenunciabilidade do direito de inversão de ônus probatório.

4.6. INCISO VII

As cláusulas contratuais que determinem a **utilização compulsória de arbitragem**;

De acordo com o inciso VI, **poderá haver arbitragem nas relações de consumo, mas não se pode obrigar o consumidor a se submeter ao juízo arbitral**, restando possível a submissão da contenda a este juízo se for de vontade do consumidor.

4.7. INCISO VIII

As cláusulas contratuais que **imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico** pelo consumidor;

Proíbe-se a cláusula-mandato, que viabiliza ao fornecedor agir como se fosse representante dos interesses do consumidor, contraindo obrigações e deveres em seu nome. Veda-se, por exemplo, que haja cláusula de mandato em contrato de abertura de conta corrente, a fim de possibilitar o banco a retirar valores da conta para quitar contratos inadimplidos com o banco, assim como emitir títulos de crédito tendo o devedor como sacado ou aceitante.

4.8. INCISO IX

As cláusulas contratuais que **deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor**;

A cláusula de desistência só pode constar no contrato submetido ao CDC se for mútua, ou seja, beneficie ambas as partes.

Inciso X) as cláusulas contratuais que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, **variação do preço de maneira unilateral**;

⁴⁶ Precedente firmado pela Quarta Turma.



No contrato submetido ao CDC, a cláusula que represente os valores pagos (cláusula financeira), deve ser definida ampla e de maneira exauriente no momento da assinatura do contrato, vedando-se alterações em sua definição no curso da avença, mesmo que indiretas.

Assim, não pode haver variação de quantidades no curso da relação contratual, nem de taxas de juros ou correção monetária, nem a inclusão de rubricas a título de reequilíbrio econômico-financeiro do pacto (ex: definição a posteriori da alíquota de comissão de permanência de acordo com uma “cesta” de índices – Súmula 472 do STJ na parte em que estabelece que a comissão de permanência deve ser cobrada “à taxa média de juros do mercado, limitada ao percentual previsto no contrato, e desde que não cumulada com outros encargos moratórios”).

4.9. INCISO X

As cláusulas contratuais que autorizem o fornecedor a **cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor**;

A rescisão unilateral, assim como a desistência, só pode ser conferida de maneira mútua. Entretanto, a disposição do inciso X do CDC não é a única que estabelece controle sobre a cláusula que admite cancelamento unilateral. Ao contrário, as disposições do microsistema consumerista não admitirão tal tipo de cláusula quando “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, nos termos do já estudado inciso IV do art. 51.

Dessa forma, especialmente quando se tratar de contrato relacional ou de duração prolongada, deve-se analisar com cautela a validade da cláusula de cancelamento unilateral (ex: “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a rescisão unilateral do acordo, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento.” - AgInt no AREsp 1406027 / SP)

4.10. INCISO XI

As cláusulas contratuais que **obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor**;

Também a cláusula de ressarcimento de despesas de cobrança encontra-se submetida à reserva de mutualidade. Ademais, a simples previsão de concessão de mesmo direito não reputa válida a cláusula de ressarcimento, devendo-se apurar, no caso concreto, se a cláusula “colo(ca) o consumidor em desvantagem exagerada, ou (é) incompatível(l) com a boa-fé ou a equidade”, nos termos do já estudado inciso IV do art. 51.

Sobre o tema, o STJ já considerou válida cláusula que permitia a cobrança de ressarcimento de honorários advocatícios em contrato bancário: “(...) 3. À luz do princípio restitutio in integrum, consagrado no art. 395 do Código Civil/2002, imputa-se ao devedor a responsabilidade por todas as despesas a que ele der causa em razão da sua mora ou inadimplemento, estando o consumidor, por conseguinte, obrigado a ressarcir os custos decorrentes da cobrança de obrigação inadimplida. 4. Havendo expressa previsão contratual, não se pode afirmar que a exigibilidade das despesas de cobrança em caso de mora ou inadimplemento, ainda que em contrato de adesão, seja indevida, cabendo à instituição financeira apurar e comprovar os danos e os respectivos valores despendidos de forma absolutamente necessária e razoável, para efeito de ressarcimento.(...)” (REsp nº 1361699 / MG)

4.11. INCISO XIII

As cláusulas contratuais que autorizem o fornecedor a **modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração**;

Valem aqui as mesmas orientações anteriores. Só é possível a cláusula de modificação contratual que contemple ambas as partes. Além disso, a simples observância do inciso XIII do



art. 51 não é suficiente à validação de eventual alteração promovida durante a execução contratual.

Ao contrário, a situação deve ser analisada tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor e tendo em vista que o art. 6º, V do CDC estabelece a prerrogativa de alteração contratual em benefício do consumidor. Portanto, admitir que o fornecedor altere unilateralmente as disposições contratuais fundando-se na mera possibilidade de o consumidor fazer o mesmo implicaria em indevida alteração do sistema consumerista, em flagrante proteção insuficiente à parte vulnerável da relação consumerista.

4.12. INCISO XIII

As cláusulas contratuais que **infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;**

Cuida-se de norma que alinha o sistema consumerista ao sistema de proteção ambiental constitucional (art. 225 da CRFB/88), reconhecendo a alta relevância da proteção do meio ambiente como direito constitucional difuso e, também, individual.

O microsistema consumerista contém normas de conteúdo individual e coletivo, determinando a proteção ampla dos direitos do consumidor mediante necessária interveniência do estado para consecução das políticas públicas e direitos fundamentais (art. 4º, II do CDC).

Dessa forma qualquer prática comercial ou disposição contratual que esteja em desalinho com o sistema de proteção ambiental deve ser rechaçada, mesmo que sob uma perspectiva imediatista possa aparentar benefício ao consumidor, haja vista que, em última instância, a violação ao meio ambiente termina por prejudicar toda a sociedade, inclusive as gerações vindouras.

4.13. INCISO XIV

As cláusulas contratuais que estejam em **desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;**

Como destacado no princípio da análise do dispositivo, o inciso XIV, ao lado do inciso IV e § 1º, ambos do art. 51, representa o caráter enumerativo do rol de cláusulas abusivas, na medida em que funciona como **cláusula geral de controle de validade** das cláusulas em contratos consumeristas. Tais alternativas permitem que o direito acompanhe a evolução da sociedade, sem necessidade de alteração legislativa e respeitando o caráter principiológico das normas consumeristas.

4.12. INCISO XV

As cláusulas contratuais que possibilitem a **renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.**

O conceito de benfeitorias necessárias encontra-se insculpido no art. 96, § 3º do CCB. A cláusula de renúncia antecipada de benfeitorias necessárias é fator que evidencia desequilíbrio na relação contratual. Embora comum nos contratos de locação urbana, o entendimento jurisprudencial de que não se aplica o CDC ao contrato de locação implica na validação de tais cláusulas quando inseridas neste tipo de avença (REsp 575.020 / RS).

5. CONTROLE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

O art. 51, §4º, estabelece que é facultado a qualquer **consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual** que contrarie o disposto no CDC ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Trata-se de disposição que estabelece importante canal para que Ministério Público atue para que seja declarada nulidade de cláusula contratual que contrarie os preceitos do CDC, ou mesmo o equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. A atuação do MP, nestas



hipóteses, é tida como espécie de **controle administrativo**, o qual pode se dar de maneira **abstrata** (denúncia realizada por consumidor que não aderiu ao contrato) ou **concreta** (quando o consumidor já aderiu ao contrato que contém as cláusulas abusivas).

Note-se que o exercício do controle das cláusulas contratuais se dá incidentalmente e por provocação do consumidor, de modo que não há de se falar em controle de ofício prévio e abstrato de cláusulas pelo MP na sistemática do CDC, tendo em vista, ainda, o veto ao disposto nos arts. 51, § 3º e 54, § 4º.

A atuação do MP depende da conformidade entre a situação jurídica e a sistemática coletiva presente nos arts. 81 e seguintes do CDC, aliada à demonstração de indisponibilidade do direito ou de interesse público ou relevância social do interesse, na esteira do que prevê o art. 127 da CRFB/88 (RE 500.879-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26-05-2011; RE 472.489-AgR, rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 29-08-2008 e REsp 1681690 / SP).

6. CONTRATOS QUE ENVOLVAM OUTORGA DE CRÉDITO OU FINANCIAMENTO

O art. 52 do CDC estabelece que: “no fornecimento de produtos ou serviços que envolva **outorga de crédito ou concessão de financiamento** ao consumidor, o fornecedor deverá informar, prévia e adequadamente, o consumidor sobre:

- **Preço** do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
- Montante dos **juros de mora** e da **taxa efetiva anual de juros**;
- **Acréscimos** legalmente previstos;
- **Número e periodicidade das prestações**;
- **Soma total** a pagar, com e sem financiamento.”

Trata-se de disposição que impõe padrão mínimo de transparência nos contratos que envolvam outorga de crédito. Busca-se conferir ao consumidor acesso a informação adequada, que lhe permita sopesar satisfatoriamente o custo do crédito que irá adquirir, visando coibir a prática de oferta abusiva que conduza ao **superendividamento**.

O **superendividamento** pode ser conceituado como um **estado da pessoa física**, que **contrai o crédito de boa-fé**, mas que no momento do adimplemento não consegue saldar todas as suas dívidas, tendo em vista que a **sua renda e o seu patrimônio são insuficientes para adimpli-las no termo estabelecido**.

Ele pode ser: **1) ativo**: quando o consumidor se endivida **voluntariamente**, utilizando-se do crédito pelo fato do **impulso e do apelo comercial** das empresas fornecedoras do crédito. Subdivide-se em **superendividado ativo consciente e inconsciente**: O **consciente (1.1)** ocorre quando o consumidor age de **má-fé** no momento que contrai as dívidas, ou seja, ele sabe que não conseguirá honrar com as suas contas, a sua intenção é não pagá-las. Neste caso, seguindo os requisitos para a caracterização do superendividamento anteriormente citados, o consumidor não receberá a proteção do Estado para poder recuperar-se devido ao fato de não possuir o requisito da boa-fé. Já o superendividado ativo **inconsciente (1.2)**, embora haja de maneira impulsiva e irresponsável, **não o faz propositalmente**, de forma maliciosa, endividando-se por pura inconseqüência ou ignorância, mas não com a intenção de não honrar com os compromissos assumidos. **2) Superendividamento passivo**: ocorre quando o consumidor se endivida devido a **fatores alheios a sua vontade**, os quais são **imprevistos**. Estes fatores não aconteceram pela má gestão, nem tampouco pela má-fé do consumidor, mas sim devido às fatalidades que o acometeram durante a sua trajetória, como exemplo: **o desemprego, as doenças, caso de morte na família, redução brusca de salário, divórcio** ou outro fator que torne a sua situação desfavorável.

Ainda sobre o tema dos contratos financeiros, o § 1º do art. 52 estabelece que “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser



superiores a **dois por cento** do valor da prestação.” Cuida-se de patamar máximo aplicável às cláusulas penais moratórias em contratos consumeristas. De acordo com a própria lógica do art. 411 do CCB, o dispositivo do § 1º do art. 52 destaca expressamente que o percentual moratório deve incidir apenas sobre o “valor da prestação”, vedando-se a incidência sobre o valor total do contrato.

Embora prevista no CDC apenas para contratos de concessão de crédito, o STJ entende que **a limitação da multa de mora a dois por cento da prestação se aplica a todos os contratos consumeristas** (REsp 436.224 / DF).

De outro lado, de acordo com o art. 52, §2º, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Ou seja, se o consumidor pagar antecipadamente a instituição financeira deverá reduzir os juros e demais acréscimos que incidiriam nas parcelas ainda não vencidas, proporcionalmente ao tempo de antecipação.

Por fim, o §3º diz que os contratos em prestações serão expressos em **moeda corrente nacional**. Entretanto, o STJ entende que “É válido o contrato celebrado em moeda estrangeira desde que no momento do pagamento se realize a conversão em moeda nacional.” (Afirmação 5 da EDIÇÃO N. 48 da “Jurisprudência em Teses” do STJ).

Rememore-se, no particular, que o STJ entende que o CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme **Súmula 297**. Sobre o tema, destaque-se os seguintes precedentes:

6.1. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A **Súmula 539 do STJ** dispõe que “**é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual** em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada”. Quanto à previsão contratual, destaque-se que a **Súmula 541 do STJ** afirma que “a previsão no contrato bancário de **taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente** para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

6.2. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

A comissão de permanência é um percentual cobrado pelas instituições financeiras no caso de inadimplemento contratual enquanto o devedor não quitar sua obrigação. Em outras palavras, trata-se de encargo cobrado por dia de atraso no pagamento de débitos junto a instituições financeiras. A comissão de permanência foi instituída por meio da Resolução 15/1966, do Conselho Monetário Nacional. Atualmente, rege o tema a Resolução 1.129/1986 do CMN. Para o fim de disciplinar a comissão de permanência o STJ editou a **Súmula 472** que afirma que: “a cobrança de comissão de permanência – cujo **valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato** – **exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual**. Dessa forma, ou se cobra a comissão de permanência, ou se cobra os demais encargos previstos no contrato. Portanto, são **inacumuláveis** a comissão de permanência com os seguintes encargos: Juros remuneratórios; Correção monetária; Juros moratórios; ou multa moratória.

Outras súmulas que tratam sobre o tema:

- **Súmula 30 do STJ:** “A comissão de permanência e a correção monetária são **inacumuláveis**”.
- **Súmula 294 do STJ:** “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, **calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato**”.
- **Súmula 296 do STJ:** “Os **juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência**, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.



6.3. JUROS: NOS TERMOS DA SÚMULA 382 DO STJ

"A estipulação de **juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade**", pois "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33)" (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 24).

Ademais, o STJ entende que "O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem **superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.**" (Afirmação 8 da EDIÇÃO N. 48 da "Jurisprudência em Teses" do STJ). Portanto, a abusividade das taxas de juros só pode ser reconhecida diante de flagrante discrepância entre a estipulação e a taxa média, nos termos do seguinte precedente: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em **situações excepcionais**, desde que caracterizada a relação de consumo e que a **abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada**, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C/1973 - Tema 27)". De todo modo, mesmo que reconhecida a abusividade, o STJ entende que "É **inviável a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC** como parâmetro de limitação de juros remuneratórios dos contratos bancários." (Afirmação 1 da EDIÇÃO N. 48 da "Jurisprudência em Teses" do STJ)

Ademais, quando ausente estipulação de taxa de juros, o STJ entende que: "nos contratos bancários, **na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada** - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, **aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen**, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula n. 530/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 233)". Sobre o tema da ausência de estipulação de taxas, ainda afirma o STJ que "São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 26)"

Entretanto, especificamente quanto às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, o STJ entende que "As cédulas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional - CMN o dever de fixar os juros a serem praticados; no entanto, havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura). (Afirmação 14 da EDIÇÃO N. 83 da "Jurisprudência em Teses" do STJ). Entretanto, a jurisprudência do STJ ressalta que "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 654)"

6.4. COBRANÇA INDEVIDA PELA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS

A cobrança pelos bancos de tarifa em razão de emissão de boleto bancário constitui enriquecimento indevido, pois os bancos já são remunerados pela tarifa interbancária (REsp 1568940 / RJ). Entretanto, no caso em que foi concedido ao consumidor a opção pela realização de pagamento pelo dinheiro, cartão ou boleto bancário, não é abusiva a cobrança do consumidor para a emissão do boleto, quando o valor que o fornecedor cobra para fornecer o boleto corresponder exatamente ao valor que o fornecedor pagou à instituição financeira pela emissão do boleto.

6.5. REPASSE DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

Em geral, a jurisprudência do STJ tem chancelado a realização de tais repasses: A) É legítima a incidência de **ISS** sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987. (Súmula n. 424 do STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 132); B) Podem as partes convencionar o pagamento **do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)** por meio de financiamento acessório ao mútuo



principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 621)

6.6. RETENÇÃO SALARIAL

O art. 1º, § 1º da Lei nº 10.820/03, na redação dada pela Lei nº 13.172/15, estabelece que o limite máximo de amortização de operações de crédito nos proventos e/ou benefícios dos servidores públicos federal, dos trabalhadores regidos pela CLT e dos aposentados do INSS, é de 35%, dos quais 5% exclusivamente para despesas e saques com cartão de crédito. Note-se que o STJ entende que tal limite não é aplicável aos descontos que o consumidor voluntariamente adere em sua conta corrente, conforme entendimento firmado no REsp nº 1555722 / SP, ocasião em que cancelada a súmula 603 do STJ.

6.7. EXCLUSÃO DE MORA E QUESTIONAMENTO JUDICIAL

Entende o STJ que “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual” (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 28). Entretanto, “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 29). De todo modo, “É possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalidam.” (Afirmação 10 da EDIÇÃO N. 83 da “Jurisprudência em Teses” do STJ)

6.8. INSTITUIÇÕES EQUIPARADAS

De acordo com o entendimento do STJ, são equiparadas às instituições financeiras para efeito de tratamento jurídico: A) “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” (Súmula n. 283/STJ); B) As cooperativas de crédito e as sociedades abertas de previdência privada são equiparadas a instituições financeiras, inexistindo submissão dos juros remuneratórios cobrados por elas às limitações da Lei de Usura. (Afirmação 16 da EDIÇÃO N. 48 da “Jurisprudência em Teses” do STJ)

7. CLÁUSULAS DE DECAIMENTO E CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

Afirma o art. 53 que: **“nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.”**

Tais cláusulas são doutrinariamente denominadas de **“cláusulas de decaimento”**, quando instituídas no sentido de conceder ao fornecedor o direito de retenção integral de pagamentos em caso de rescisão contratual promovida pelo consumidor, seja através de cláusula penal ou da combinação dela com a previsão de outras hipóteses, como a retenção de arras.

Em geral, a jurisprudência pátria não compactua com cláusulas penais que estabelecem a perda integral de valores como cláusula penal em caso de rescisão contratual efetivada pelo consumidor, tendendo a autorizar a retenção de apenas uma parcela dos valores pagos a título de punição (ex: item “6” da EDIÇÃO N. 110 da “Jurisprudência em Teses” do STJ: **“No caso de rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do comprador, é razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.”**)

Quanto a compra e venda de imóveis, a Súmula 543 do STJ afirma que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de



Defesa do Consumidor, deve ocorrer a **imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente**, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, **ou parcialmente**, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Portanto, mostra-se legítima a pretensão de resilição contratual do consumidor quanto ao compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, encontrando-se vedada a retenção integral de valores pela construtora. Entretanto, deve-se observar, quanto à compra e venda de imóvel, que a Lei nº 13.786, de 27 de Dezembro de 2018, denominada “Lei do Distrato”, alterou substancialmente o quadro delineado pelos precedentes supracitados, em especial quanto ao percentual de retenção, prazo para devolução e cláusulas penais, encontrando sua aplicação circunscrita aos contratos que foram firmados após a sua publicação, nos termos da jurisprudência do STJ.

Sobre as inovações da nova lei, destaque-se:

A) Regulamentação específica do “quadro-resumo” (Art. 35-A, Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964);

B) Legalização da Cláusula de Tolerância e Estabelecimento de Cláusula Penal Moratória em benefício do consumidor, a qual não é cumulável com lucros cessantes (Art. 43-A, Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964). A cláusula de tolerância já tinha sua legalidade chancelada pelo STJ (REsp 1.582.318 / RJ), enquanto a cláusula penal moratória em favor do consumidor vinha sendo obtida através da inversão (REsp 1.498.484 / DF e REsp 1.631.485 / DF - Tema 971);

C) Consequências do “Distrato” (Art. 67-A, Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964) = Consumidor Perde: 1) integralidade da comissão de corretagem; e 2) a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga (50% em caso de patrimônio de afetação); 3) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die em caso de imissão (O percentual da perda em caso de imóveis com patrimônio de afetação constituído sobeja o limite de 25% que o STJ admitia);

D) Prazos para restituição: 30 (trinta) dias após o habite-se se tiver patrimônio de afetação e 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato se não tiver. Entretanto, 30 (trinta) dias da revenda se esta ocorre (Cancela o entendimento de restituição imediata contido na Súmula 543 do STJ);

E) Regulamentação da taxa de ocupação de “0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die”, que deve ser paga pelo consumidor que promove a resilição do contrato após ocupar o bem (Art. 67-A, Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964). Tal reparação já vinha sendo deferida pelo STJ (item “7” da EDIÇÃO N. 107 da “Jurisprudência em Teses” do STJ);

F) Concessão de Direito de Arrependimento nos mesmos moldes do art. 49 do CDC, embora condicionado a envio de “carta registrada, com aviso de recebimento” (Art. 67-A, §§ 10º e 11º da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964).

De outro lado, quando há atraso da construtora, o consumidor pode pleitear a rescisão contratual com a devolução integral de valores, inclusive os pagos a título de correção monetária, ou manter o cumprimento contratual, valendo dizer que, se exigido o cumprimento contratual com reparação de perdas e danos, não é possível a compensação cumulada através de cláusula penal e lucros cessantes, conforme entendimento do STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Ademais, a doutrina amplamente majoritária anota a natureza eminentemente indenizatória da cláusula penal moratória quando fixada de maneira adequada.” (REsp 1.498.484-DF e REsp 1.631.485-DF - Tema 971).

Em optando o consumidor pela reparação de **lucros cessantes**, destaque-se que o STJ entende que “Há **presunção de prejuízo** do promitente comprador a viabilizar a condenação por lucros cessantes pelo descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda ou de compra e venda.” (item “4” da EDIÇÃO N. 107 da “Jurisprudência em Teses” do STJ) sendo que “A indenização deferida a título de lucros cessantes



em decorrência do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda será o **montante equivalente ao aluguel que o comprador deixaria de pagar ou que auferiria** caso recebesse a obra no prazo.” (item “3” da EDIÇÃO N. 110 da “Jurisprudência em Teses” do STJ).

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ: “Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a **correção monetária** do valor correspondente às parcelas pagas, para efeitos de restituição, **incide a partir de cada desembolso.**” (item “5” da EDIÇÃO N. 107 da “Jurisprudência em Teses” do STJ). Ainda, “Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, **os juros de mora** devem incidir **a partir do trânsito em julgado**, visto que inexistente mora anterior do promitente vendedor.” (item “5” da EDIÇÃO N. 110 da “Jurisprudência em Teses” do STJ).

Quanto ao financiamento dos contratos de compromisso de compra e venda imobiliária, releva notar que o STJ admite a incidência de “**juros no pé**”, conforme entendimento: “Não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidente em período anterior à entrega das chaves no contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária.” (item “6” da EDIÇÃO N. 107 da “Jurisprudência em Teses” do STJ). Entretanto, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel” (**Súmula nº 308 do STJ**).

Quanto aos encargos cobrados, entende o STJ que “É **abusiva a cobrança** pelo promitente-vendedor do **serviço de assessoria técnico-imobiliária ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel**” (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 938 - parte final). Entretanto, “É **válida cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem** nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 938 - segunda parte)

Destaque-se, por fim, que “A pretensão ao **recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel**, submete-se ao **prazo prescricional decenal** previsto no art. 205 do Código Civil/2002.” (item “3” da EDIÇÃO N. 110 da “Jurisprudência em Teses” do STJ). Ainda, sobre prazos prescricionais: “Incide a **prescrição trienal** sobre a pretensão de **restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI)**, ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC).” (Tese julgada sob o rito do art. 1036 do CPC/2015 - TEMA 938 - primeira parte).

8. CONTRATOS DE CONSÓRCIO

O art. 53, §2º, dispõe que: “nos contratos do **sistema de consórcio** de produtos duráveis, a **compensação ou a restituição** das parcelas quitadas terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os **prejuízos** que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.”

A norma consumerista atenta para as peculiaridades do sistema de aquisição por consórcio, regido pela Lei nº 11.795/08, em especial o prejuízo gerado por um dos integrantes do grupo no momento da desistência.

Sobre o tema, o STJ entende que: 1) É lícito condicionar a devolução das parcelas pagas pelo desistente ao prazo de até 30 dias do encerramento do grupo/plano (REsp 1.256.998 / GO); 2) “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio” (Súmula 35 do STJ); e 3) “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” (Súmula 538 do STJ)



9. CONTRATOS DE ADESÃO

O art. 54 do CDC estabelece regime protetivo relativo aos contratos de adesão que se submetam à disciplina protetiva do microssistema consumerista. Em seu “caput”, o dispositivo define tal contrato como “aquele cujas cláusulas tenham sido **aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor** de produtos ou serviços, **sem que o consumidor possa discutir ou modificar** substancialmente seu conteúdo.”

Portanto, a formação do contrato de adesão dispensa a fase pré-contratual, sendo tal tipo de contrato marcado por três principais características: A) **predeterminação**: seu conteúdo já é dado pelo fornecedor de antemão ao consumidor; B) **uniformidade**: as cláusulas e disposições do contrato de adesão são as mesmas para todos os consumidores; C) **rigidez**: não há margem para que o consumidor discuta o conteúdo contratual, visando colher melhores condições em seu benefício.

Note-se que, nos termos do § 1º do art. 54: “A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.” Ademais, o § 2º do art. 54 estabelece a legalidade das cláusulas resolutórias no contrato de adesão “desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor”. Lembre-se que o art. 51, XI estabelece a ilegalidade da cláusula resolutória aposta apenas em benefício do fornecedor.

Dado o potencial violador de direitos e a ausência de poder de barganha do consumidor, o § 3º do art. 54 determina que “os contratos de adesão escritos serão redigidos em **termos claros** e com **caracteres ostensivos e legíveis**, cujo tamanho da fonte não será inferior ao **corpo doze**, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.” Note-se que se trata de imposição que deriva dos princípios da transparência, da informação e da boa-fé objetiva, a qual, em linha com o art. 46 do CDC, impede que disposições obscuras e de cabeçalho restrinjam direitos do consumidor sem que seja ele informado adequadamente.

Destaque-se que o STJ já decidiu que a disposição relativa ao tamanho da fonte (corpo doze) não se aplica às peças publicitárias veiculadas pelos fornecedores (REsp 1.602.678 / RJ).

Por fim, há de se destacar que o simples fato de ser o contrato reputado como de adesão não implica na vedação de existência de disposições que restrinjam direitos do consumidor durante a execução contratual, sob pena de se inviabilizar a oferta de serviços e produtos no mercado. Nesse sentido, o § 4º do art. 54 afirma que: “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão **ser redigidas com destaque**, permitindo sua **imediata e fácil compreensão**.”

Logo, devem as cláusulas restritivas possuir destaque com relação às demais cláusulas contratuais, indicando com clareza quais os direitos alvo de limitação e a forma exata com que tal restrição acontece, tudo de maneira que permita imediata e fácil compreensão por parte do consumidor. Sobre o tema, o STJ já decidiu que não atende o disposto no § 4º do art. 54 a cláusula que é escrita em negrito quando outras cláusulas ordinárias do contrato também tomarem tal forma (REsp 774.035 / MG).

São nulas as cláusulas que não atendam aos comandos do art. 54, §§ 2º a 4º, tendo em vista sua notória desconformidade com o sistema de proteção ao consumidor, nos termos do art. 51, XV do CDC (REsp 814060 / RJ).

Questões comentadas

1) Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: TJ-MS Prova: FCC - 2020 - TJ-MS - Juiz Substituto (ADAPTADA)

Acerca das cláusulas abusivas, considere:

I. São nulas de pleno direito as cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, ainda que igual direito seja conferido ao consumidor.



Incorreta. Em contrariedade com o Art. 51, inciso XI, do CDC, que reputa abusivas as cláusulas que “autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor”.

II. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo poderão ser de, no máximo, quatro por cento do valor da prestação.

Incorreta. Em contrariedade com o art. 52, § 1º do CDC, que estabelece que “As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

III. Desde que expressamente previsto no contrato, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Incorreta. A faculdade de liquidação antecipada é assegurada pelo Art. 52, § 2º do CDC, independentemente de previsão contratual.

IV. Qualquer consumidor pode, individualmente, requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Correta. Alinha-se à redação do Art. 51, § 4º do CDC, que dispõe que “É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.”

V. São válidas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação se igual direito lhe for conferido contra o fornecedor.

Correta. O Art. 51, inciso XII do CDC reputa nulas as cláusulas que: “obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor”.

2) Ano: 2020 Banca: FCC Órgão: TJ-MS Prova: FCC - 2020 - TJ-MS - Juiz Substituto

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o contrato de adesão

A) não permite a supressão do direito do consumidor de discutir ou modificar substancialmente o conteúdo de cada uma das suas cláusulas.

Incorreta. É da própria natureza do contrato de adesão a ausência de discussão pelo aderente quanto ao conteúdo das cláusulas. É nesse sentido a definição do art. 54 do CDC: “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.”

B) perde essa natureza mediante a inserção, no formulário, de cláusula nova, resultante de discussão com o consumidor.



Incorreta. Contraria o disposto no art. 54, § 1º do CDC: “A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.”

C) admite cláusula resolutória.

Correta. De fato, o art. 54, § 1º do CDC estabelece que: “Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.”

D) deve ser redigido em termos claros e com caracteres de qualquer tamanho de fonte, desde que ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Incorreta. Em desconformidade com o art. 54, § 3º do CDC, que afirma que: “Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.”

E) não admite cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor.

Incorreta. Em desconformidade com o art. 54, § 4º do CDC, que afirma que: “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”



CAPÍTULO 12 — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O Capítulo VII do CDC trata das Sanções Administrativas, estabelecendo as consequências administrativas para o descumprimento das normas presentes no microsistema consumerista.

O controle e aplicação das normas que tutelam o sistema desenvolvido para a parte vulnerável da relação é realizado, entre outros, pelos **componentes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor**, que estão listados no art. 105 do CDC: “órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.”

Nos termos do art. 2º do Decreto nº 2.181/97, que regulamenta a aplicação das sanções administrativas: “Integram o SNDC a **Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça** e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.”

O sistema de tutela desenvolvido pelo CDC é de textura aberta, permitindo a integração ampla da rede de proteção por órgãos públicos de qualquer esfera federativa e por **entidades privadas (que dispõe dos poderes concedidos pelo art. 8º do Decreto nº 2.181/97)**, desde que voltados direta (ex: PROCONs; ONGs; Associações de Defesa de Consumidores; etc.) ou indiretamente (ex: Agências Reguladoras; CADE; etc.) à defesa do consumidor.

Percebe-se, portanto, que o legislador busca a criação de rede integrada e inclusiva de proteção e reafirmação do microsistema consumerista. Tal rede será, nos termos do art. 106 do CDC, coordenada pelo Departamento Nacional de Defesa do Consumidor (DNDC) ou órgão federal que venha substituí-lo, vinculado à Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ) e regulamentado pelo Decreto nº 2.181/97, cabendo a ele desempenhar as funções elencadas de maneira enumerativa nos incisos do art. 106 do CDC.

A função de órgão de coordenação vem sendo desempenhada pela Secretaria Nacional do Consumidor (SNC) do Ministério da Justiça desde 2012, quando houve a alteração do art. 3º do Decreto nº 2.181/97, sendo a SNC a atual responsável pelas atividades elencadas exemplificativamente nos incisos do art. 106 do CDC e repetida nos incisos do art. 3º do Decreto nº 2.181/97.

Em geral, a figura constantemente lembrada quando da análise da aplicação do CDC é o **PROCON**. Tais instituições são geralmente criadas sob a forma de autarquias ou fundações públicas e tem, basicamente, as seguintes **finalidades**: **orientação** (esclarecimentos ao consumidor); **mediação** (análise administrativa de conflitos entre consumidor e fornecedor que envolvam a aplicação do CDC, destacando-se o poder do art. 55, §4º do CDC); **encaminhamentos à fiscalização** (reportar a outros órgãos a violação de determinada regra consumerista); **fiscalização** (efetuar propriamente a fiscalização em caso de denúncias, dispondo de competência para processar e julgar administrativamente as infrações apuradas); realizar **estudos e pesquisas** (ex: elaboração de cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990)⁴⁷.

Nesse sentido, o art. 4º do Decreto nº 2.181/97 estabelece rol exemplificativo de funções exercidas pela autoridade administrativa local ou regional, valendo destacar que entre elas se encontra a de “funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto” (inciso IV).

2. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL EM MATÉRIA CONSUMERISTA

O art. 55 do CDC, na esteira do art. 24, V, da CRFB/88, trata da “**competência legislativa concorrente** da União, os Estados e o Distrito Federal, nas suas respectivas áreas de atuação

⁴⁷ ANDRADE, Adriano et. Al. Interesses Difusos e Coletivos Vol. 1. 9ª ed. Editora Método, 2019, P.757.



administrativa, **para baixar normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.**” Note-se que a competência legislativa **não inclui os Municípios.**

De outro lado, a **competência material , também de natureza concorrente, para fiscalização e controle** está prevista no §1º do art. 55 do CDC, que afirma que caberá à “União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios **fiscalizar e controlar a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo.**” Note-se que a competência material **inclui os Municípios.**

Embora seja claro o caráter concorrente da fiscalização administrativa, destaque-se que o parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 2.181/97 afirma que “Se **instaurado mais de um processo administrativo** por pessoas jurídicas de direito público distintas, para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual **conflito de competência será dirimido pela Secretaria Nacional do Consumidor**, que poderá ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor - CNPDC, levando sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica.”

Ou seja, a apuração e aplicação de sanções **não pode culminar com o sancionamento duplo pela mesma conduta (mesmos fatos e vítimas), também conhecido como “bis in idem”**, de modo que, constatada a existência de apurações relativas aos mesmos fatos, há de se definir a autoridade administrativa competente através de provocação da Secretaria Nacional do Consumidor. No particular, afirma o art. 15 do Decreto nº 2.181/97 que “Estando a **mesma empresa sendo acionada em mais de um Estado federado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa**, a autoridade máxima do sistema estadual poderá remeter o processo ao órgão coordenador do SNDC, que apurará o fato e aplicará as sanções respectivas.”

A fiscalização deve-se fazer, “no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, os entes políticos poderão baixar as normas que se fizerem necessárias”, podendo os órgãos administrativos de tutela dos direitos consumeristas lançar mão de “**compromissos de ajustamento de conduta** às exigências legais, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985”, conforme expressamente facultado pelo art. 6º do Decreto nº 2.181/97.

Visando reforçar e garantir o sistema de proteção, o §3º do art. 55 do CDC afirma que “Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão **comissões permanentes** para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo **obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.**”

Como ferramenta importante no exercício da tutela administrativa do direito do consumidor, o §4º do art. 55 do CDC afirma que “os **fornecedores poderão ser notificados pelos órgãos oficiais** para que, sob pena de desobediência, **prestem informações** sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.” A possibilidade de requisição de informações é poderoso instrumento posto à disposição dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (ex: PROCON) para que exerçam seu mister fiscalizatório.

3. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE

Diz o art. 56 que “as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, **sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:**”

- Multa;
- Apreensão do produto;
- Inutilização do produto;
- Cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- **Proibição de fabricação do produto;**



- Suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- **Suspensão temporária de atividade;**
- Revogação de concessão ou permissão de uso;
- Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- **Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;**
- **Intervenção administrativa;**
- **Imposição de contrapropaganda.**

A doutrina costuma dividir essas sanções em três modalidades: **A) Pecuniárias:** multas; **B) Objetivas:** que incidem diretamente sobre os produtos ou serviços fornecidos pelo infrator - apreensão; inutilização; cassação do registro; proibição de fabricação; e suspensão de fornecimento. **C) Subjetivas:** que recaem sobre a atividade do fornecedor - suspensão temporária de atividade; cassação de licença/alvará; interdição de estabelecimento; intervenção administrativa; e contrapropaganda⁴⁸.

Ademais, o art. 17 do Decreto nº 2.181/97 afirma que “As práticas infrativas classificam-se em: I - **leves:** aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias atenuantes; II - **graves:** aquelas em que forem verificadas circunstâncias agravantes.”

Conforme afirma o parágrafo único do art. 56, essas sanções **serão aplicadas “pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”**

Portanto, na esteira do §1º do art. 55 do CDC, a competência administrativa dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é **ampla e concorrente**, devendo cada órgão se ater à respectiva área de atuação e competência. Assim, se a infração for local ou estadual, por exemplo, é possível que o PROCON aplique multa à empresa pública federal, conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.103.826-RN), valendo lembrar, contudo, que se mostra vedado o “bis in idem”.

Entretanto, como destacado pelos §§ 2º e 3º do art. 18 do Decreto nº 2.181/97, as penas administrativas, quando impostas a fornecedor de serviço ou produto cuja atividade seja normatizada por agência reguladora, as penas de incisos IV a XI do art. 56 do CDC dependerão de “posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador”.

Ademais, é importante destacar que o a aplicação de sanção administrativa deve ser precedida de observância ao **devido processo legal** (Art. 5º, LIV da CRFB/88), com especial observância à **ampla defesa e ao contraditório** (Art. 5º, LV da CRFB/88), o que não impede, como visto, a aplicação cumulativa de sanções, inclusive cautelarmente.

Em geral, o procedimento administrativo de análise de infração e imposição de sanção segue o previsto no Decreto nº 2.181/97 (arts. 33 a 54) ou na Lei nº 9.784/99, salvo existência de disposição legislativa diversa editada pelo ente competente (Estado ou Município).

Ainda, nos termos do art. 18, § 1º do Decreto nº 2.181/97 e, bem observada a sistemática principiológica consumerista, a responsabilidade pelas infrações administrativas é **objetiva e independe de benefício ou prejuízo concreto, podendo as sanções administrativas ser aplicadas ao poder público** normalmente, em caso de violação aos direitos dos consumidores relativos aos serviços públicos (art. 20 do Decreto nº 2.181/97).

Seguindo a lógica do sancionamento administrativo, não há de se falar de tipicidade cerrada ou de tipificação e imputação de penas. Assim, a individualização das penas deverá ser realizada pela autoridade administrativa competente, de acordo com o caso concreto, podendo seguir, por exemplo, o previsto nos arts. 19 a 28 do Decreto nº 2.181/97, desde que adotada a regulamentação federal pelo ente estadual ou municipal.

⁴⁸ Idem Ibidem.



Nesses casos, a escolha da pena a ser aplicada deve observar especialmente o que prevê o art. 24 do Decreto nº 2.181/97: “Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados: I - as circunstâncias **atenuantes e agravantes**; II - os **antecedentes** do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.”

Sobre a reincidência, destaque-se que seu conceito se encontra no art. 27 do Decreto nº 2.181/97: “Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.” Ainda, o § 3º do art. 59 do CDC afirma que “Em caso de **pendente ação judicial**, na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, **não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença**.” Aqui, insta salientar que, embora se trate de instituição inspirada no direito penal, o conceito de reincidência para aplicação na seara administrativa não precisa, necessariamente, observar as diretrizes adotadas pelo arts. 63 e 64 do Código Penal Brasileiro.

3.1. PENA DE MULTA

O art. 57 do CDC estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com: 1) **Gravidade da infração**; 2) **Vantagem auferida**; e 3) **Condição econômica do fornecedor**. O art. 28 do Decreto nº 2.181/97 inclui, ainda, como baliza para o valor da multa, “a **extensão do dano causado aos consumidores**”. Os valores decorrentes de multas aplicadas pela União serão revertidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e os montantes recolhidos pelos Estados e Municípios revertidos aos Fundos Estaduais ou Municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Nos termos do art. 31 do Decreto nº 2.181/97: “Na ausência de Fundos municipais, os recursos serão depositados no Fundo do respectivo Estado e, faltando este, no Fundo federal.”

Quanto aos valores, o parágrafo único do art. 57 do CDC: “A multa será em montante **não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)**, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.” Entretanto, o STJ já admitiu a fixação de montante em reais, desde que observados os limites estabelecidos pelo parágrafo único do art. 57 do CDC (AgRg no REsp 1.466.104 / PE). Vale mencionar que o art. 32 do Decreto nº 2.181/97 afirma que, quando houve infração à norma consumerista de repercussão nacional ou em mais de um Estado, hipótese em que a apuração será realizada pelo órgão coordenador do SNDC, a multa eventualmente aplicada terá 80% de seu percentual destinado aos fundos dos Estados.

Para além da análise concreta do caso e averiguação da pena administrativa adequada, realizada pela autoridade administrativa competente, o art. 22 do Decreto nº 2.181/97 estabelece a aplicação de multa como sanção adequada à apuração de inserção de **cláusulas abusivas**.

3.2. PENAS DE APREENSÃO, DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS, DE PROIBIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS, DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE PRODUTO OU SERVIÇO, DE CASSAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO E REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO OU PERMISSÃO DE USO

Diz o art. 58 que “as penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, **mediante procedimento administrativo**, assegurada ampla defesa, **quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço**.”

O art. 21 do Decreto nº 2.181/97 destaca que a sanção de apreensão de produtos deve ocorrer “quando os produtos forem comercializados em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas em legislação própria”, determinando, em seu §1º, que “Os bens apreendidos, a critério da autoridade, poderão ficar sob a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado que responda pelo gerenciamento do negócio, nomeado fiel depositário, mediante termo próprio, proibida a venda, utilização, substituição, subtração ou remoção, total ou parcial, dos referidos bens.”



3.3. PENAS DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA, DE INTERDIÇÃO E DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA ATIVIDADE, BEM COMO A DE INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA

O art. 59 diz que “as penas de **cassação de alvará de licença**, de **interdição** e de **suspensão temporária da atividade**, bem como a de **intervenção administrativa**, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, **quando o fornecedor for reincidente** na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo”.

Conforme § 1º do art. 59: “A **pena de cassação** da concessão **será aplicada à concessionária de serviço público**, quando violar **obrigação legal** ou **contratual**.” Ainda, o §2º do art. 59 estabelece que “A pena de **intervenção administrativa** será aplicada sempre que **as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade**.” Portanto, a pena de intervenção administrativa possui caráter subsidiário.

§§ 2º e 3º do art. 18 do Decreto nº 2.181/97, as penas administrativas, quando impostas a fornecedor de serviço ou produto cuja atividade seja normatizada por agência reguladora, as penas de incisos IV a XI do art. 56 do CDC dependerão de “posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador”.

Ainda, a cassação da concessão de serviço público também deve observar o que previsto no art. 38, §1º da Lei nº 8.987/90, que trata dos serviços públicos e dispõe sobre a caducidade da concessão

3.4. IMPOSIÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA

O art. 60 afirma que “a imposição de **contrapropaganda** será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de **publicidade enganosa ou abusiva**, sempre às expensas do infrator”. Trata-se de sanção já analisada quando dos comentários acerca da publicidade, valendo mencionar que, nos termos do art. 19 Decreto nº 2.181/97, a prática de publicidade enganosas ou abusivas **também implica no pagamento de multa**.

A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, **de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva**.

Questões comentadas

1) Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RO Prova: VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias, assim como aplicando sanções administrativas aos fornecedores, em caso de desobediência por parte deles, ressaltando-se que

A) a suspensão temporária de atividade, a inutilização do produto e a intervenção judicial são espécies de sanções administrativas.

Incorreta. A intervenção judicial não se encontra no rol do art. 56 do CDC.

B) as várias espécies de sanções administrativas serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, vedando-se a cumulatividade.



Incorreta. Em desconformidade com o conteúdo do parágrafo único do art. 56 do CDC, que estabelece que “As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.” (Grifei)

C) a imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, devendo ser custeada, como regra, às expensas do infrator ou do poder público.

Incorreta. Em desconformidade com o conteúdo do art. 60 do CDC, que dispõe que “A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.”

D) a multa, quando aplicada, será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 2 (dois) milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Incorreta. Em desconformidade com o conteúdo do parágrafo único do art. 57 do CDC, que estabelece que “A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”. (Grifei)

E) os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Correta. É o que prevê o § 4º do art. 55 do CDC: “Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”

2) Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: TJ-AL Prova: FCC - 2019 - TJ-AL - Juiz Substituto (ADAPTADA)
Quanto às sanções administrativas previstas no CDC, considere os enunciados abaixo:

I. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

Correta. Alinha-se ao conteúdo do art. 58 do CDC, que dispõe que “As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.”

II. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no CDC e na legislação de consumo.



Correta. Alinha-se ao conteúdo do art. 59 do CDC, que dispõe que “As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.”

III. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público exclusivamente quando violar obrigação legal.

Incorreta. Desconforme do conteúdo do art. 59, § 1º do CDC, que afirma que: “A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.”

IV. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato aconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade.

Incorreta. Desconforme do conteúdo do art. 59, § 2º do CDC, que afirma que: “A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.”

V. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva sempre às expensas do infrator; a contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Correta. Alinha-se ao conteúdo do art. 60 do CDC, que dispõe que “A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.”



CAPÍTULO 13 — INFRAÇÕES PENAIS

Corroborando seu caráter de microsistema, o CDC estabelece disposições tipificando condutas violadoras dos direitos dos consumidores, evidenciando que o caráter de direito fundamental dos direitos consumeristas (art. 5º, XXXII da CRFB/88) merece tutela ampliada, através da aplicação da última “ratio” representada pelo Direito Penal.

Conforme destacado pelo art. 61 do CDC, as disposições previstas no título II não são as únicas que tipificam condutas que violam bens juridicamente vinculados ao consumidor, havendo disposições de tal natureza no Código Penal, na **Lei nº 8.137/90 (Art. 7º, I, III, IV e V), na Lei nº 1.521/51**, no Estatuto do Torcedor, etc.

Os tipos previstos no CDC (arts. 63 a 74) possuem características em comum: A) **São todos de menor potencial ofensivo** (pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa - art. 61 da Lei 9.099/95) e **afiançáveis por autoridade policial** (pena máxima não superior a quatro anos - art. 322 do CPP); B) São todos **dolosos, ressalvados os dos arts. 63 e 66 do CDC**; C) São todos punidos com **detenção**; D) São, em sua maioria, **de perigo abstrato**; e E) O CDC **não estabelece responsabilização da Pessoa Jurídica**.

Em geral, a análise dos crimes do CDC se resume ao conteúdo legal (letra de lei). São relevantes as seguintes peculiaridades:

1) Art. 63 do CDC: “**Omitir dizeres ou sinais ostensivos** sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade” - Possui modalidade **culposa** (§ 2º) e é crime omissivo próprio, **não admitindo tentativa**;

2) Art. 64 do CDC: “**Deixar de comunicar** à autoridade competente e aos consumidores a **nocividade ou periculosidade** de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado” - Hipótese que tutela e pune o descumprimento dos deveres do **art. 10, §§ 1º e 2º (periculosidade superveniente)**. Também é crime omissivo próprio e **não admite tentativa**.

3) Art. 68 do CDC: “Fazer ou promover **publicidade** que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o **consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa** a sua saúde ou segurança”. É crime **instantâneo e de perigo abstrato**. O art. 7º, VII, da Lei 8.137/90 traz delito semelhante, embora tenha por diferença a necessidade de induzir a erro. Além disso, o dispositivo da Lei 8.137/90 trata do consumidor individualmente considerado, não tutelando o direito coletivo à publicidade não abusiva e não enganosa.

4) Art. 72 do CDC: “**Impedir ou dificultar o acesso do consumidor** às informações que sobre ele constem em **cadastros, banco de dados, fichas e registros**”. O dispositivo apenas o descumprimento do art. 43, § 3º do CDC. É **crime próprio de mera conduta**, pois só pode ser praticado pela entidade mantenedora do banco de dados ou cadastro, batando o mero impedimento de acesso para sua tipificação.

5) Art. 74 do CDC: “**Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia** adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo”. Dispositivo que tutela o comando do art. 50 do CDC. É crime **instantâneo e de perigo abstrato** e sua aplicação é questionada diante do princípio da intervenção mínima.

6) Art. 75 do CDC: “Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o **diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar** o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.” Embora de redação confusa, o dispositivo **não estabelece hipótese de responsabilização da Pessoa Jurídica**. Trata-se de regra que se soma à regra de autoria prevista no art. 18 do CPB, especificando a possibilidade de imputação a agentes com poder de direção de pessoas jurídicas.

7) Art. 76 do CDC: “São **circunstâncias agravantes** dos crimes tipificados neste código: **grave crise econômica** ou por ocasião de **calamidade**; **grave dano** individual ou coletivo; dissimular-se a natureza ilícita; por **servidor público**, ou por pessoa cuja **condição econômico-social** seja manifestamente superior à da vítima; em detrimento de **operário ou ruralista**; de



menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas **portadoras de deficiência mental** interditadas ou não; envolvam **alimentos, medicamentos** ou quaisquer outros produtos ou **serviços essenciais**.” O CDC estabelece agravantes que se somam às agravantes previstas nos arts. 61 e 62 do CPB.

8) Art. 77 do CDC: “A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em **dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade** cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1º do Código Penal.” O CDC traz **regra especial de cálculo da multa penal**, adotando como parâmetro mínimo e máximo dos dias-multa a duração da pena privativa de liberdade.

9) Art. 78 do CDC: “Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, **cumulativa ou alternadamente**, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal: I - a **interdição temporária de direitos**; II - a **publicação em órgãos de comunicação** de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de **notícia sobre os fatos e a condenação**; III - a **prestação de serviços à comunidade**.” Diversamente do que ocorre no art. 44 do CPB, que estabelece penas restritivas de direitos que são autônomas e substituem as privativas de liberdade, o art. 78 do CDC estatui penas restritivas de direito que são **alternativas ou cumulativas às penas privativas de liberdade**.

10) Art. 80 do CDC: “No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, **poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária**, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.” Trata-se de ampliação da regra de assistência dos arts. 268 a 273 do CPB.

Questões comentadas

1) Ano: 2019 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-PI Prova: CESPE - 2019 - MPE-PI - Promotor de Justiça Substituto (ADAPTADA)

A respeito das normas de direito penal e processo penal previstas no CDC, julgue os itens a seguir.

I Omitir sinais ostensivos sobre a nocividade de produtos em embalagens constitui conduta delitiva punida quando praticada com dolo ou culpa.

Correta. Alinha-se ao conteúdo do art. 63 “caput” e § 2º do CDC.

II O diretor de pessoa jurídica que promover o fornecimento de produtos em condições proibidas incide nas penas cominadas aos crimes previstos no CDC, na medida de sua culpabilidade.

Correta. Alinha-se ao conteúdo do art. 75 do CDC, que dispõe que “Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.” (Grifei)

III É circunstância agravante dos crimes tipificados no CDC o cometimento em detrimento de menor de dezoito anos de idade, de maior de sessenta anos de idade ou de pessoas com deficiência mental, interditadas ou não.



Correta. Alinha-se ao conteúdo do art. 76, IV, “b”, do CDC, que dispõe que “São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código: (...) IV - quando cometidos: (...) b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não;”

IV Além das penas privativas de liberdade e de multa, pode ser imposta, cumulativa ou alternativamente, a pena de liquidação compulsória da pessoa jurídica.

Incorreta. A pena de liquidação compulsória da pessoa jurídica não consta do rol de penas alternativas prevista no art. 78 do CDC.

2) Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: DPE-MA Prova: FCC - 2018 - DPE-MA - Defensor Público

Em relação aos dispositivos penais previstos no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar:

A) Os legitimados para a propositura da ação civil pública, desde que pessoas jurídicas de direito público, podem ingressar como assistentes do Ministério Público nas denúncias oferecidas por seus membros.

Incorreta. Em desconformidade com o art. 80 do CDC, que aduz que “No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.” (Grifei)

B) São circunstâncias que agravam a pena o fato de o crime ser cometido em período de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade.

Correta. Alinha-se ao conteúdo do art. 76, I do CDC, que dispõe que “São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código: (...) I - serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade”.

C) Não há previsão de pena alternativa à privativa de liberdade, com exceção da prestação de serviços à comunidade.

Incorreta. Em desconformidade com o art. 78, I e II do CDC.

D) A fiança deve observar os limites previstos no Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser aumentada ou diminuída em atenção a capacidade financeira do sujeito ativo.

Incorreta. Em desconformidade com o art. 79, parágrafo único do CDC que estabelece que “Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser: a) reduzida até a metade do seu valor mínimo; b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.”

E) A pena de multa será fixada entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Incorreta. Os critérios citados pela assertiva são usados para a fixação de fiança e não de multa, conforme conteúdo do art. 79 do CDC.



CAPÍTULO 14 — DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO

1. INTRODUÇÃO

O título III do CDC trata da “Defesa do Consumidor em Juízo” e, embora consagre disposições que influenciam no tradicional processo civil (à época de sua publicação regido pelo CP/73), possui papel de relevo no ordenamento jurídico brasileiro por tratar de maneira destacada e pioneira de vários aspectos do **processo coletivo**.

A **massificação das relações de consumo** e a **amplitude das práticas consumeristas** indicam que o tratamento adequado dos direitos consagrados no microssistema consumerista CDC é fundamentalmente coletiva, pois a constatação de práticas abusivas e violações à teoria da qualidade, em geral, se espalha a diversas (centenas, milhares ou até milhões) relações travadas entre o fornecedor e o mercado.

Nesse sentido, o direito consumerista, com seu inegável caráter social, se enquadra no que se denominou de **terceira geração ou dimensão dos direitos humanos** e, por tal razão, não se mostra adequadamente tutelado pela tradicional lógica individualista de reconhecimento e processualização de direitos.

O potencial multiplicador das demandas consumeristas aliado à vulnerabilidade dos consumidores ressalta a relevância de se observar as lides submetidas ao CDC sob a perspectiva macro, conjugando casos ao invés de molecularizá-los, sempre em busca de uma tutela efetiva dos direitos consagrados no microssistema consumerista.

Dessa forma, a busca pela implementação do processo coletivo mostra-se diretamente vinculada à adequada tutela do direito do consumidor e, por tal motivo, o legislador consumerista dedicou importante título à definição de instituições relativas ao processo coletivo, fazendo com que o CDC seja parte relevante do **Microssistema de Direito Coletivo** (Arts. 21 da Lei nº 7.347/85 c/c 90 do CDC).

2. DIREITOS COLETIVOS *LATO SENSU*

De acordo com o art. 81 do CDC: “a defesa dos interesses e direitos **dos consumidores e das vítimas** poderá ser exercida em juízo **individualmente**, ou **a título coletivo**.”

O parágrafo único de tal dispositivo, quando lido em conjunto com o art. 21 da LACP, estabelece conceitos acerca do que se entende por **Direitos Coletivos “Lato Sensu”**, afirmando que a **defesa coletiva será exercida quando se tratar de:**

A) “Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os **transindividuais**, de **natureza indivisível**, de que sejam titulares **pessoas indeterminadas** e ligadas por **circunstâncias de fato**.

Perceba, os direitos difusos são: Indivisíveis; possuem titulares indeterminados; e são ligados por circunstâncias fáticas.

Ex.: quando é veiculado uma propaganda em canal de televisão, atinge-se um número indeterminado de pessoas, que poderão ser atingidas ou não, mas estão ligadas entre si por uma circunstância fática, visto que inexistente qualquer contrato. Essa propaganda é um direito indivisível, eis que ela será exibida ou não. Não há como ser exibida para algumas partes e para outras não.

Ex2: o dano ambiental também é tipo clássico de dano a direito difuso, pois atinge bem indivisível (meio ambiente equilibrado), com titulares indeterminados (toda a sociedade) ligados entre si por uma circunstância fática (serem moradores de um determinado local).

B) “Interesses ou direitos coletivos *strictu sensu*, assim entendidos, para efeitos deste código, os **transindividuais**, de **natureza indivisível** de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma **relação jurídica base**.”



Portanto, os direitos coletivos *strictu sensu* são: Indivisíveis; possuem titulares indeterminados; e seus titulares são ligados com a parte contrária por uma relação jurídica base. Logo, no direito difuso, há uma relação fática, enquanto no coletivo, há uma relação jurídica.

Ex.: o direito dos alunos de determinada faculdade à razoável qualidade de ensino é um direito transindividual indivisível para um grupo de pessoa determinada e que tenham uma relação jurídica com a parte contrária.

C) “Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de **origem comum**.

Os interesses ou direitos individuais homogêneo são: Divisíveis; possuem titulares determinados; e eles possuem origem comum.

Na verdade, ontologicamente, não se trata de um direito coletivo, e sim um direito individual tratado de forma coletiva.

Ex.: cobrança indevida de valores referentes a fretes de veículos novos, adquiridos de empresas concessionárias de veículos por inúmeros consumidores. Quem pagou, sofreu a lesão. Ou seja, várias pessoas sofreram a lesão em razão daquela cobrança.

É possível falar em simultaneidade de lesões a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? Sim. Nada impede que, diante de uma mesma situação, existam direitos difusos, coletivos ou individual homogêneo.

Ex.: um banco traz, em seus contratos, uma cláusula abusiva. Essa cláusula implica cobrança de multa exagerada e indevida. Supondo que 100 pessoas foram cobradas e já pagaram essa multa indevida. Cada uma delas foi lesada, tendo todas o direito a uma prestação divisível, que é o ressarcimento ao que pagaram (**direito individual homogêneo**).

Além das 100 pessoas que pagaram essa multa, existem milhares de outras pessoas que celebraram o contrato com o banco, mas que ainda não incorreram em mora e não pagaram a multa. No entanto, estão sujeitas a esse pagamento. Então, é importante que essa cláusula seja declarada nula para que essas pessoas não venham a incorrer em risco. Trata-se de um **direito coletivo**, pois anula-se a cláusula para todos ou não será anulada para ninguém.

3. LEGITIMADOS

Os arts. 5º da Lei nº 7.347/85 c/c 82 do CDC estabelecem os legitimados para a propositura da demanda coletiva. Trata-se de **sistema misto/pluralista (entes públicos e privados)**, sendo de se mencionar que, diferentemente do que ocorre no sistema de “class actions” americano, o direito pátrio presume a legitimação dos elencados no rol legal (**sistema “ope legis”**), admitindo apenas **excepcionalmente** e para alguns legitimados o chamado controle de legitimação adequada exercido pelo juiz (**“ope judicis”**), como por exemplo o que ocorre com as associações, que devem demonstrar **pertinência temática** entre o objeto social e a demanda proposta (REsp 1213614 / RJ e AgInt no REsp 1619154 / SC).

A legitimação para a propositura de demandas coletivas é **concorrente, disjuntiva e extraordinária** (STF RE 193.503/SP e STJ REsp 876.936/RJ), ressalvado o caso das associações, que, por força do art. 5º, XXI da CRFB/88 atuam por representação dos que a autorizam, mesmo minoritários.

Vejamos quais os legitimados elencados pela lei e a possibilidade de controle de legitimidade com relação a eles:

A) Ministério Público: O MP, se não propõe a demanda, sempre intervém (Arts. 5º, § 1º da LACP e 92 do CDC).

Considerando suas funções institucionais (art. 129 da CRFB/88), o MP **sempre será legitimado para propor demandas coletivas que versem direitos difusos e coletivos “strictu sensu”** (STF, RE 163231/SP e STJ, REsp 910.192/MG).

Com relação ao **direito individual homogêneo**, a jurisprudência vai dizer que a legitimidade para propor ação civil pública pelo Ministério Público se fará presente quando estivermos diante de caso em que se tutela: **Direito Indisponível ou Direito Disponível de**



relevante interesse social ou repercussão no interesse público. (RE 500.879-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26-05-2011; RE 472.489-AgR, rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 29-08-2008).

São exemplos de hipóteses em que o MP foi reconhecido como legitimado: direito do consumidor (REsp 856.378); Súmula 643 do STF: O MP tem legitimidade para promover ACP cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares; Tratamento médico ou entrega de medicamentos com beneficiários individualizados (REsp 1.682.836-SP); Serviços Públicos (Súmula 601 do STJ); contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas pretensamente abusivas; Revogação da Súmula 470 do STJ = DPVAT; Anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público (RE 409356); Objetivando a liberação do saldo de contas PIS/PASEP de incapazes (REsp 1.480.250-RS); O Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública que visa à anulação da tramitação de Projeto de Lei do Plano Diretor de município = MPE (REsp 1.687.821-SC).

ATENÇÃO para o art. 1º, P.U. da LACP, que afirma que não é possível ajuizar ação coletiva, inclusive o MP, sobre “Tributos, Contribuições Previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional”. Entretanto, o STF, no RE 576.155/DF admitiu o ajuizamento de ação civil pública pelo MP visando combater isenção tributária.

O art. 5º, § 3º, LACP estabelece o **princípio da disponibilidade motivada** no âmbito da ação coletiva, afirmando que “Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.” Note-se que o MP e os demais legitimados não são obrigados a assumir o polo passivo, devendo, contudo, justificar sua postura. O STJ já entendeu que o dispositivo não vale para outra associação assumir o polo ativo (REsp 1.405.697-MG).

Entretanto, quando da execução de eventual sentença coletiva vige o **princípio da obrigatoriedade da execução** pelo MP (Art. 15 da LACP).

Derradeiramente, destaque-se que o STJ já entendeu ser possível a **inversão do ônus da prova em favor do MP** em demanda coletiva que versava direito consumerista (EResp 1134957/SP).

B) Defensoria Pública (art. 5º, II da LACP): A defensoria Pública é legitimada ativa para propositura da demanda coletiva que busque a **tutela dos “necessitados”** (art. 134 da CRFB/88), **mesmo que beneficie outras pessoas** (RE 733433). A interpretação do termo “necessitados” deve se dar de forma ampliativa, incluindo, para além dos necessitados sócio-econômicos, as minorias (Ex: STF, RCL 22614 = Quilombolas) e outros setores sociais desfavorecidos socialmente. Há, também, hipóteses de legitimação legal por matéria atinentes à Defensoria Pública, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o ECA, o Estatuto do Idoso, etc. (EResp 1192577 / RS).

C) Administração Direta e Indireta: No caso dos órgãos da Administração Direta tem-se exigido vinculação institucional com o direito discutido, enquanto no caso da Administração Indireta deve-se apurar a pertinência temática. As Fundações Privadas encontram-se englobadas no conceito de administração indireta (AR 497/BA).

D) Conselho Federal da OAB e Órgãos Seccionais da OAB (Art. 54, XIV EOAB): O STJ já decidiu que o CFOAB e as seccionais não precisam de demonstrar pertinência temática (REsp 1351760/PE).

E) Associações de Direito Privado (art. 5º, V da LACP e 82, IV do CDC): As associações de direito privado devem demonstrar **Pertinência Temática/Objetiva/Finalística** entre o direito discutido e sua finalidade estatutária. Entretanto, o STJ tem entendido que não se faz necessária previsão expressa do direito defendido no Estatuto, admitindo-se interpretação extensiva dos termos previstos (REsp 876.931/RJ).

Além disso, o STF entende que o ajuizamento de ação coletiva por associação depende de **autorização assemblear específica** e de apresentação de lista de beneficiários no momento de ajuizamento da demanda, conforme previsão dos arts. 5º, XXI da CRFB/88 e 2º, Lei nº



9.494/97 (RE-RG 612043), de modo que o direito eventualmente concedido na sentença só beneficiará quem era filiado no momento do ajuizamento da demanda (REsp 1.468.734 / SP).

O STJ entendeu que Associação de Municípios não é legitimada a propor demanda coletiva em benefício de seus associados (REsp 1.503.007 / CE) e que associação com fins específicos de proteção ao consumidor não possui legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de tutelar interesses coletivos de beneficiários do seguro DPVAT (REsp 1.091.756-MG).

O requisito de pré-constituição da associação poderá ser dispensado, conforme se verifica no art. 82, §1º. Segundo o dispositivo, o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, quando haja **manifesto interesse social** evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela **relevância do bem jurídico a ser protegido**.

F) Sindicatos (Art. 8º, III da CRFB/88): Os sindicatos não precisam de registro no MTE para propor demandas coletivas (RE 370834/MS) e a demanda proposta não precisa de autorização prévia dos sindicalizados, pois se trata de hipótese de substituição processual constitucionalmente autorizada (RE 193.503/SP), de modo que o benefício pode ser para a categoria toda, mesmo os não sindicalizados.

G) Cooperativas (art. 21, XI e 88-A da Lei nº 5.764/71): As cooperativas podem propor demanda coletiva em benefício de seus cooperados, desde que haja previsão estatutária e autorização assemblear.

Nos termos do art. 5º, §§ 2º e 5º da LACP pode haver **litisconsórcio entre legitimados**, inclusive entre MPS de diferentes âmbitos institucionais (STJ, REsp 1444484/RN e STF, ACO 1020/SP).

4. ESTÍMULO À EFETIVIDADE

O art. 83 do CDC destaca que, para a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo CDC, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Trata-se, do **princípio da amplitude do processo ou da absoluta instrumentalidade**, que é reforçado pelos arts. 12 e 21 da LACP c/c Arts. 83 e 90 do CDC c/c Art. 5º XXXV da CRFB/88.

De outro lado, o art. 84 do CDC afirma que: “na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a **tutela específica** da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Portanto, o objetivo da ação coletiva e do processo que tutela os direitos do consumidor é dar **preferência à tutela específica**, o que dá ensejo ao reconhecimento do **princípio da maior coincidência entre o direito e a realização**, de modo que fica claro que as perdas e danos são subsidiárias.

Inclusive o §1º do art. 84 assenta que a conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se: o autor da ação optar por essa medida; a tutela específica se tornar impossível; o resultado prático correspondente ao adimplemento se tornar impossível.

Ainda, o §2º do art. 84 estabelece que a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. Isso significa dizer que será possível aplicar as **astreintes**, ainda que haja indenização por perdas e danos e pelo inadimplemento. Não há qualquer relação entre a multa diária e a indenização pelo inadimplemento.

O §3º do art. 84 do CDC afirma, a seu turno, que, “sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.” Ou seja, se houver *periculum in mora* e *fumus boni iuris*, o juiz poderá conceder a tutela liminarmente. O direito básico do consumidor é a **prevenção e a reparação dos danos**.

Visando reforçar o comando anterior, o §4º do art. 84 do CDC afirma que “o juiz poderá, na hipótese de concessão da tutela liminar ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, o juiz



fixará multa diária e fixará um prazo razoável para o cumprimento do preceito, sob pena de incidência daquela.”

Ainda, o §5º do art. 84 afirma que, para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como: Busca e apreensão; Remoção de coisas e pessoas; Desfazimento de obra; Impedimento de atividade nociva; Requisição de força policial.

Por fim, há de se destacar que, como forma de busca pela efetividade, vige no processo coletivo o **princípio da primazia do conhecimento do mérito** (art. 4º c/c art. 139 c/c § 2º do art. 282, IX c/c art. 317, “caput” e § 2º c/c § 2º do art. 319 c/c art. 321 c/c art. 352 c/c §§ 1º e 7º do art. 485 c/c art. 488, todos do NCPC), que demanda do julgador o emprego do maior esforço possível para avaliar o mérito da demanda, evitando a sua extinção sem resolução do mérito.

5. CUSTAS, EMOLUMENTOS, DESPESAS E HONORÁRIOS

O art. 87 do CDC estabelece que “nas ações coletivas do CDC, **não haverá adiantamento de custas**, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, **nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.**” A previsão é reforçada pelos arts. 17 e 18 da LACP.

A ideia é facilitar o acesso ao poder judiciário para os legitimados, buscando a obtenção de ampla e efetiva tutela dos direitos do consumidor. O dispositivo é claro acerca da inexistência de exigência de adiantamento de honorários periciais, o que vem sendo debatido na jurisprudência, pois o STJ entende que o MP não pode ser obrigado a antecipar tais honorários (REsp 1253844 / SC), enquanto o STF entendeu, com base no art. 91, §§ 1º e 2º do NCPC, que o MP deve realizar tal adiantamento a custa de sua dotação orçamentária (ACO 1560).

De todo modo, não há isenção de custas no caso de execução individual de sentença coletiva, valendo mencionar que, por aplicação do princípio da reciprocidade, o STJ vem entendendo que não há ônus sucumbenciais na hipótese de procedência da ação coletiva (EResp nº 1531504 / CE).

6. AÇÃO DE REGRESSO DO COMERCIANTE

O art. 88 do CDC dispõe que “na hipótese do art. 13, parágrafo único do CDC, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, **vedada a denunciação da lide.**”

Esse dispositivo veda a denunciação à lide nas demandas consumeristas, como já destacado anteriormente, como já destacado no capítulo relativo à teoria da qualidade. Por se tratar de dispositivo que assegura proteção ao consumidor, eventual denunciação à lide realizada e deferida não pode ser contestada pelo denunciado com base na vedação do art. 88 do CDC, pois o consumidor pode entender que a integração do terceiro lhe beneficia em termos de ampliação de garantias.

7. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC E DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Segundo o art. 90: “aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, **naquilo que não contrariar suas disposições.**”

De fato, considerando as especificidades dos direitos coletivos, o sistema estabelecido pelo Código de Processo Civil somente pode ser aplicado ao processo coletivo quando com ele compatível, em especial quando se tem em mente que o CPC traz regras que foram pensadas para a tutela individual.



8. COMPETÊNCIA

O art. 93 do CDC, em conjunto com o art. 2º da LACP, preceitua que: “**ressalvada a competência da Justiça Federal**, é competente para a causa a justiça local: “I - **no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano**, quando de **âmbito local**; II - **no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal**, para os **danos de âmbito nacional ou regional**, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.”

Cuida-se de hipótese excepcional de **competência territorial funcional/absoluta** definida de acordo com a extensão do dano, devendo as regras de prevenção do NCPC ser aplicadas na hipótese em que houver mais de um juízo competente.

9. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E *RIGHT TO OPT IN*

O art. 94 afirma que: “proposta a ação, será **publicado edital no órgão oficial**, a fim de que os **interessados possam intervir no processo como litisconsortes**, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.”

O dispositivo é responsável por traçar as diretrizes do **princípio da ampla divulgação da demanda**, que se conecta diretamente ao **princípio do acesso à justiça** (art. 5º, XXXV da CRFB/88) e ao **princípio da universalidade da jurisdição** (amplo acesso).

O legislador busca garantir, na maior exatidão possível, seja oportunizado aos consumidores o exercício do *right to opt in*, ou seja, o se integrar à demanda para acompanhar a análise do direito que podem ser titulares. Entretanto, o STJ entende que a não publicação do edital previsto no art. 94 do CDC **não gera nulidade** (REsp 205.481/MG).

Entretanto, de acordo com a lógica adotada pelo CDC, o art. 104 afirma que “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, **não induzem litispendência para as ações individuais**, mas os **efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes** a que aludem os incisos II e III do artigo anterior **não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias**, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Portanto, de acordo com a lógica inicialmente pensada pelo legislador, o ingresso do consumidor na demanda coletiva que versa direito que julga ser titular seria opcional, podendo o indivíduo ajuizar ação autônoma se assim o quiser, tendo em vista a ausência de litispendência.

Entretanto, o STJ passou a entender ser possível a **suspensão de todas as ações individuais pelo juiz nas hipóteses em que ajuizada demanda coletiva versando a mesma causa de pedir** (REsp nº 1.243.887 / PR e REsp nº 1.525.327 / PR), o que acaba por destituir de eficácia o comando do art. 104 do CDC.

10. SENTENÇA NO PROCESSO COLETIVO

O art. 95 estabelece que: “Em caso de procedência do pedido, a **condenação será genérica**, fixando a **responsabilidade** do réu pelos danos causados.”

É decorrência direta do processo coletivo a inviabilidade de se fixar minuciosamente toda a extensão da condenação. Assim, a adequação da sentença ao caráter coletivo do direito discutido se dá através da permissão de que ela seja proferida de maneira genérica, mediante apenas o reconhecimento da responsabilidade do réu, sem que seja necessário identificar os beneficiados e o tipo exato de direito a ser deferido, relegando-se tal apuração para momento posterior.

Tal momento é denominado **liquidação imprópria**. De acordo com o art. 97 do CDC: “a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.” É o que se chama de **transporte “in utilibus”** da coisa julgada, o qual é expressamente previsto no art. 103, § 3º do CDC para os



direitos individuais homogêneos, embora também seja pacífica a possibilidade de sua realização no caso de direitos difusos e direitos coletivos “strictu sensu”.

A liquidação na demanda coletiva é denominada imprópria porque é necessário que o **liquidante comprove a sua condição de titular** daquele direito, dispondo de procedimento similar ao ordinário no processo coletivo, onde poderá postular **provas de qualquer natureza**, de acordo com o direito discutido, de forma similar ao procedimento previsto no art. 509, II do NCPC (antigo procedimento de liquidação por artigos).

Portanto, o titular de direito individual certificado em sentença coletiva deve propor demanda autônoma de liquidação imprópria, ocasião em que deverá demonstrar a **existência e extensão** de seu direito (ex: após o reconhecimento de fraude financeira por parte de empresa de “marketing” digital pela justiça de um Estado, os consumidores que tiveram prejuízos em decorrência da fraude, ocasião em que devem juntar documentação comprovando abertura de conta e pagamentos em benefício da empresa).

Além disso, o próprio art. 97 do CDC destaca a possibilidade de **liquidação e execução pelos legitimados coletivos**, sendo reforçado pelo art. 98 que assenta que “a **execução poderá ser coletiva**, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as **vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas** em sentença de liquidação, **sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções**.” Nos termos do §1º do art. 98: “a execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.”

Portanto, o que se percebe é que a execução coletiva pode ser realizada pelos legitimados tanto em benefício de pessoas que tenham sido expressamente contempladas na sentença coletiva, quanto com relação a danos coletivos ali reconhecidos (ex: sentença coletiva que reconhece danos ambientais em um rio, a ocorrência de dano moral coletivo e afirma o direito de pensionamento de piscicultores pode ser executada pelo legitimado que a propôs para recebimento do valor dos danos morais coletivos e para o recebimento do pensionamento para posterior divisão entre os piscicultores).

Sobre o tema, destaque-se que o STF admitiu em repercussão geral o fracionamento de precatórios para que a execução dos créditos individuais de beneficiários da demanda coletiva seja feita através de RPVs (RE 568.645-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/2014).

Quem será o juízo competente para execução?

Nos termos do art. 98, § 2º do CDC, o juízo competente **para a execução** será:

- O Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória: nos casos de execução individual;
- O Juízo da ação condenatória: nos casos de execução coletiva.

Entretanto, o STJ entende que à liquidação individual de sentença coletiva consumerista também se aplica o comando do art. 101, I do CDC, que faculta a propositura da demanda no domicílio do consumidor (REsp 1243887 / PR).

Portanto, a execução da sentença coletiva, caso seja feita individualmente, poderá ser proposta:

- **Juízo da ação condenatória;**
- **Juízo de domicílio da vítima (que é onde foi feita a liquidação);**
- **Juízo de domicílio do réu.**

Esse entendimento acaba por jogar por terra as disposição sobre limites territoriais da coisa julgada estabelecidas pelo art. 16 da LACP (“A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (...)”) e art. 2º-A, “caput” da Lei nº 9.494/95 (“A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os

substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”).

Tais dispositivos já eram reputados pela doutrina como inconstitucionais, em razão de ferirem os princípios da Igualdade e do devido processo legal substantivo, e ineficazes, pois confundiam conceitos de jurisdição e competência, além de contrariarem o art. 103, III do CDC.

De outro lado, o art. 99 do CDC vai estabelecer que: “em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei 7.347/85 (LACP) e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento.”

Em outras palavras, havendo indenizações fixadas a título coletivo e indenizações fixadas a títulos individuais, resultantes do mesmo evento danoso, **as execuções a título individual terão preferência de pagamento.**

O parágrafo único diz ainda que “a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas”.

Ainda tratando da execução da sentença coletiva, o art. 100 do CDC estabelece que: “decorrido o prazo de **um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano**, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.”

O dispositivo trata da “**fluid recovery**”, a qual visa assegurar a integralidade da reparação do dano e evitar a criação de situação em que o descumprimento da lei seja lucrativo ao violador. Nesse caso, o produto da indenização devida reverterá para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos e a execução se submete ao **princípio da obrigatoriedade**, ou seja, os legitimados, em especial o MP, são obrigados a promover a “fluid recovery”.

11. COISA JULGADA

Visto que a sentença coletiva deve ser genérica e que a sua execução depende de ajuizamento de liquidação imprópria, na qual o beneficiário deve comprovar a existência e extensão de seu direito, cumpre analisar o regime especial da coisa julgada aplicável ao processo coletivo, visando, em especial, definir os beneficiários e o regime de sua formação.

Nesse sentido, o art. 103 do CDC estabelece que: “nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada”:

- **erga omnes**, caso se trate de **direitos difusos, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas**, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova: Trata-se de **coisa julgada secundum eventum probationis**, ou seja, se o pedido for julgado improcedente por falta de provas, será possível a propositura de nova ação por outro o pelo mesmo legitimado ou por qualquer pessoa, desde que fundada em novos elementos de provas.
Veja, se o direito é difuso e o pedido foi julgado procedente, então a sentença vai fazer coisa julgada *erga omnes*. Da mesma forma, se o pedido for julgado improcedente, também fará coisa julgada *erga omnes*, atingindo a todos legitimados e pessoas.
- “**ultra partes**”, no caso de **direitos coletivos, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo se julgado improcedente o pleito por insuficiência de provas**:
No caso de direito coletivo e o pedido for julgado procedente, então a coisa julgada será “ultra partes”. Se foi julgado improcedente o pedido, também fará coisa julgada “ultra partes”.
No entanto, não fará coisa julgada, no caso de o pedido ser improcedente por insuficiência de provas. Neste caso, poderá ser proposta nova ação, desde que



fundada em novo elemento de prova, pois a coisa julgada nos direitos coletivos *strictu sensu* também se forma *secundum eventum probationis*.

- ***erga omnes***, no caso de **direitos individuais homogêneos**, apenas no caso de **procedência** do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores:

Julgado procedente o pedido, a sentença fará coisa julgada *erga omnes*. Por outro lado, se for julgado improcedente o pedido, não haverá coisa julgada *erga omnes*, ficando apenas os legitimados impedidos de propor nova demanda.

A coisa julgada, nos direitos individuais homogêneos, é *secundum eventum litis*. Isto é, so se forma em caso de procedência.

O §1º do art. 103 estabelece que os efeitos da coisa julgada para os direitos difusos e para os direitos coletivos não prejudicarão os direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. O legislador parte da diferenciação entre direitos individuais e coletivos *lato sensu*.

O §2º, a seu turno, aduz que na hipótese de direitos individuais homogêneos, caso haja a improcedência do pedido, os interessados que não tiverem participado do processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual, partindo do pressuposto de que a coisa julgada coletiva somente atingirá o particular que exercer o *right to opt in* previsto no art. 94 do CDC.

No mesmo sentido, de acordo com o art. 104, as ações coletivas que discutem os direitos difusos e direitos coletivos, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada *erga omnes* ou *ultra partes* dos direitos coletivos e dos direitos individuais homogêneos não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Entretanto, como visto anteriormente, o entendimento do STJ de que o juiz pode suspender forçadamente o curso das demandas eventuais para aguardar julgamento de demanda coletiva que versa a mesma causa de pedir (REsp nº 1.243.887 / PR e REsp nº 1.525.327 / PR) acaba por destituir de eficácia os comandos dos arts. 103, §§ 1º e 2º e 104 do CDC.

12. PRESCRIÇÃO

O STJ tem entendido que o **prazo prescricional para o ajuizamento de demandas coletivas é de cinco anos**, mediante aplicação integrativa do art. 21 da Lei de Ação Popular - Lei nº 4.717/65 (AgRg nos EAREsp 119.895/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe de 13/09/2012).

A **citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual**, independentemente de “opt in”. (AgRg nos EDcl no REsp 1426620 / RS). Portanto, o ajuizamento da demanda coletiva por qualquer legitimado interrompe o prazo prescricional relativo à causa de pedir ali discutida, inclusive com relação às eventuais demandas coletivas.

Interrompido, o prazo prescricional se reinicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90 para tanto (REsp nº 1.388.000 / PR).

ATENÇÃO: A Terceira Turma do STJ tem aparentado se alinhar ao entendimento de que o silêncio do legislador ao não fixar prazo específico para a prescrição da demanda coletiva foi eloquente, o que lhe daria caráter imprescritível. Nesse sentido o seguinte precedente: “O prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação popular não se aplica às ações coletivas de consumo.” (REsp 1.736.091 / PE).

13. DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS ESPECÍFICAS DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA

O art. 101 do CDC traz as seguintes normas processuais específicas da demanda consumerista:



- **A ação pode ser proposta no domicílio do autor;**
Cuida-se de direito assegurado em benefício do acesso do consumidor à justiça, nos termos do art. 6º, VII do CDC. Trata-se de **opção do consumidor**, que também pode ajuizar a ação no domicílio do fornecedor se assim lhe convier. Portanto, a regra do art. 101 do I do CDC encerra hipótese de **competência relativa** (AgInt no AREsp 814539 / PR).
O STJ entende que a **cláusula de eleição de foro** contida no contrato firmado entre o consumidor e o fornecedor **nem sempre será tida como abusiva**, devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, se a sua observância implicará em violação do direito do consumidor de **acessar livremente a justiça** e de promover sua defesa ou se há **hipossuficiência**, caso em que ela deve ser anulada (REsp 1.675.012 / SP).
Portanto, apenas nas hipóteses em que houver hipossuficiência ou barreira ao acesso à justiça é que o magistrado estará legitimado a, mesmo de ofício, declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos dos arts. 6º, VIII e 51, XV do CDC c/c art. 63, §3º do NCPC.
- O réu que houver contratado **seguro de responsabilidade** poderá **chamar ao processo o** segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.
Quando se promove uma ação contra o fornecedor, pode ser que ele tenha celebrado um seguro de responsabilidade. Ex.: cirurgião plástico faz um seguro de responsabilidade. Neste caso, se um dia esse médico é acionado por um consumidor, poderá “chamar ao processo” a seguradora. Na hipótese, os dois irão integrar a lide e a sentença condenará ambos. A hipótese, em geral, seria de denúncia da lide (art. 125, II do NCPC). Entretanto, dada a vedação a tal incidente pelo art. 88 do CDC, o legislador optou por criar a exceção através de regime especial de intervenção de terceiro que denominou “chamamento”.
Além disso, a segunda parte do inciso II do art. 101 do CDC aduz que “se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denúncia da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.”

Por fim, o art. 102 do CDC estabelece que “os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal.”

Questões comentadas

1) Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RJ Prova: VUNESP – 2019 – TJ-RJ – Juiz Substituto

Em conformidade com o que disciplina o Código de Defesa do Consumidor sobre os interesses ou direitos individuais homogêneos, assinale a alternativa correta.

A) O Ministério Público não é parte legítima para atuar em defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores.

Incorreta. Com relação ao direito individual homogêneo, a jurisprudência vai dizer que a legitimidade para propor ação civil pública pelo Ministério Público se fará presente quando estivermos diante de caso em que se tutela: Direito Indisponível ou Direito Disponível de



relevante interesse social ou repercussão no interesse público. (RE 500.879-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26-05-2011; RE 472.489-AgR, rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 29-08-2008).

B) A respectiva coisa julgada terá efeitos ultra partes, com a reparabilidade indireta do bem cuja titularidade é composta pelo grupo ou classe.

Incorreta. Nos termos do art. 103, III do CDC, a coisa julgada nas demandas que versam direitos individuais homogêneos tem efeitos “erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores”.

C) A marca de seu objeto é a indivisibilidade e a indisponibilidade, ou seja, não comportam fracionamento e não podem ser disponibilizados por qualquer dos cotitulares.

Incorreta. Os direitos individuais homogêneos são divisíveis e tem titulares identificáveis. Além disso, há direitos coletivos dessa natureza que são disponíveis.

D) São interesses na sua essência coletivos, não podendo ser exercidos em juízo individualmente.

Incorreta. Os direitos individuais homogêneos são também conhecidos como acidentalmente coletivos. Seu tratamento coletivo se dá em benefício da otimização da atividade jurisdicional, bem como de sua racionalidade, evitando-se provimentos contraditórios. Não por outra razão, o art. 104 do CDC dispõe que “As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

E) A origem comum exigida para a configuração dos interesses individuais homogêneos pode ser tanto de fato como de direito.

Correta. Esse entendimento é perfilhado por Kazuo Watanabe.

2) Ano: 2019 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: MPE-MG Prova: FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2019 - MPE-MG - Promotor de Justiça Substituto

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a jurisprudência do STJ:

A) A liquidação e a execução individual de sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.

Correta. Cuida-se do entendimento delineado no REsp 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/10/2011.

B) O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para promover a execução de sentença proferida em ação coletiva que envolva interesses individuais homogêneos, na hipótese de os interessados lesados se desinteressarem do seu cumprimento individual, sendo os valores apurados revertidos ao Fundo de Interesses Difusos.



Correta. Trata-se da aplicação do “fluid recovery, previsto no art. 100 do CDC.

C) O termo inicial para a contagem dos juros de mora, decorrentes de sentença proferida em ação coletiva sujeita à liquidação, tem início a partir da citação do devedor na fase de conhecimento, quando a ação se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Correta. Cuida-se do entendimento delineado no REsp 1370899-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 21/5/2014

D) A divulgação ampla, pelos meios de comunicação social impressos, da sentença de procedência proferida em ação coletiva de consumo relacionada a interesses individuais homogêneos é a forma mais adequada e efetiva para garantir aos eventuais beneficiados pela decisão o acesso à jurisdição.

Incorreta. Discrepa do entendimento delineado no REsp 1.821.688, onde a Exma. Ministra Relatora afirmou que "Sob a égide do CPC/2015, o meio mais adequado, eficaz e proporcional de divulgação da sentença da ação coletiva é a publicação na rede mundial de computadores, nos sites de órgãos oficiais e no do próprio condenado". Para a relatora, a publicidade por meio dos tradicionais jornais impressos de ampla circulação, "além de não alcançar o desiderato devido, acaba por impor ao condenado desnecessários e vultosos ônus econômicos".

